



Conseiller le Client dans la gestion de son
patrimoine Privé (CCP)



Natacha FAUCHIER

Responsable scientifique AUREP
Coresponsable pédagogique CCP
Diplômée Notaire

AUREP

Les régimes matrimoniaux

2025

Propriété intellectuelle

L'AUREP et le formateur sont seuls titulaires des droits de propriété intellectuelle de l'ensemble des formations que l'Aurep propose à ses Clients. À cet effet, l'ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu'en soit la forme (papier, électronique, numérique, oral, ...) utilisés par l'AUREP et le formateur pour assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de ces derniers. À ce titre, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation sans accord exprès de L'AUREP. En particulier, le Client s'interdit d'utiliser le contenu des formations en dehors de l'action de formation concernée par la convention qui le lie à l'Aurep et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée. Toute représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations en ce compris, les module(s) E-Learning, ainsi que des bases de données figurant le cas échéant sur la plateforme digitale de l'AUREP, sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. En tout état de cause, L'AUREP demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l'occasion de l'exécution des prestations chez le Client.



TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	3
Partie I – DÉTERMINATION DU RÉGIME MATRIMONIAL.....	9
Chapitre I – En présence d'élément(s) d'extranéité : droit international privé, convention de La Haye et règlements européens.....	9
Section 1 – Mariages et conventions matrimoniales conclus avant le 1 ^{er} septembre 1992 : règles de droit commun	9
A – Époux mariés sans contrat.....	9
B – Époux mariés avec contrat.....	10
C – Changement de régime matrimonial.....	10
Section 2 – Mariages et conventions matrimoniales conclus entre le 1 ^{er} septembre 1992 et le 29 janvier 2019 : application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.....	10
A – Époux mariés sans contrat.....	10
B – Époux mariés avec contrat.....	11
C – Changement de régime matrimonial.....	11
Section 3 – Mariages et conventions matrimoniales conclus depuis le 29 janvier 2019 : application du règlement européen (UE) du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux....	13
A – Époux mariés sans contrat.....	13
B – Époux mariés avec contrat.....	14
C – Changement de régime matrimonial.....	14
Chapitre II – En l'absence d'élément d'extranéité : le droit interne français	15
Section 1 – Les époux n'ont pas fait de contrat de mariage et n'ont jamais modifié leur régime matrimonial.....	15
Section 2 – Les époux ont fait un contrat de mariage et/ou une convention modificative	15
Chapitre III – Choisir et aménager le régime matrimonial en droit français.....	16
Section 1 – Principe de liberté des conventions matrimoniales et limites.....	16
A – Principe de liberté des conventions matrimoniales	16
B – Limites.....	16
Section 2 – Formalisme applicable.....	19
A – Changement de régime réalisé avant le 1 ^{er} janvier 2007	19
B – Changement de régime réalisé entre le 1 ^{er} janvier 2007 et le 25 mars 2019	19
C – Changement de régime réalisé à compter du 25 mars 2019	20
Partie II – RÉGIME PRIMAIRE IMPÉRATIF ET RÉGIME LÉGAL	23

Chapitre I – Le régime primaire impératif	23
Section 1 – Contribution des époux aux charges du mariage	23
A – Objet de la contribution.....	23
B – Répartition entre les époux.....	24
C – Exécution de la contribution.....	25
Section 2 – Régime des dettes ménagères	26
Section 3 – Autonomie des époux dans la vie quotidienne	27
Section 4 – Protection du logement de la famille	28
Section 5 – Autonomie des époux dans la vie professionnelle.....	30
Section 6 – Mesures de crise	30
A – Représentation judiciaire d'un époux par son conjoint (C. civ., art. 219).....	31
B – Autorisation judiciaire donnée à un époux pour passer seul un acte (C. civ., art. 217)	31
C – Place de ces mesures parmi les protections juridiques des personnes vulnérables	32
Chapitre II – Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts	33
Section 1 – Le patrimoine des époux.....	33
A – Les actifs.....	33
B – Le passif.....	51
Section 2 – Les pouvoirs sur les biens	62
A – Biens propres	62
B – Biens communs.....	62
C – La distinction du titre et de la finance	67
Section 3 – La dissolution du régime	69
A – Méthodologie	69
B – Les récompenses et les créances entre époux.....	70
C – Droits des parties dans la communauté.....	75
D – Distinction entre liquidation et partage.....	76
Partie III – RÉGIMES CONVENTIONNELS COMMUNAUTAIRES	77
Chapitre I – Aménagements relatifs à la composition des masses commune et propres.....	77
Section 1 – Choisir un modèle communautaire proposé par le Code civil.....	77
A – Communauté réduite aux acquêts.....	77
B – Communauté de biens meubles et acquêts	77
C – Communauté universelle	80
Section 2 – Aménager ponctuellement la nature d'un bien.....	83

A – Apport à communauté (ou « ameublement »).....	83
B – Stipulation de propre (ou clause d'exclusion de communauté).....	84
Chapitre II – Aménagements relatifs à la dissolution et au partage	86
Section 1 – Modifier les règles relatives aux récompenses ou créances entre époux.....	86
A – Les récompenses	86
B – Les créances entre époux.....	86
Section 2 – Favoriser le survivant en modifiant la règle de répartition par moitié des biens communs.....	87
A – Le préciput.....	87
B – La stipulation de parts inégales ou l'attribution intégrale.....	89
Section 3 – Favoriser le survivant en le soustrayant à l'aléa du partage	93
A – Le prélèvement moyennant indemnité.....	93
B – La « clause commerciale » : faculté d'attribution ou d'acquisition.....	94
Chapitre III – Quid à la fin du mariage	96
Section 1 – Notion d'avantage matrimonial et sort des avantages matrimoniaux en cas de dissolution par divorce.....	96
A – Notion d'avantage matrimonial	96
B – Sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce.....	96
C – La clause de reprise ou clause alsacienne	97
Section 2 – En cas de décès : attention à l'action en retranchement des avantages matrimoniaux	98
A – Définition de l'action en retranchement.....	98
B – Titulaires de l'action en retranchement.....	99
C – Le calcul de l'action en retranchement	99
Section 3 – L'indignité matrimoniale.....	102
Partie IV – AUTRES RÉGIMES CONVENTIONNELS	103
Chapitre I – Séparation de biens.....	103
Section 1 – Séparation de biens « pure et simple »	103
A – Le patrimoine des époux.....	103
B – Les pouvoirs sur les biens.....	105
C – La dissolution du régime.....	106
Section 2 – Aménagements divers en séparation de biens.....	106
A – Modification des règles relatives aux créances entre époux.....	106
B – La « clause commerciale » : faculté d'attribution ou d'acquisition.....	106
C – La contribution aux charges du mariage.....	106

Section 3 – Séparation avec société d’acquêts.....	111
A – Définition et composition de la société d’acquêts	111
B – Aménagements relatifs à cette société d’acquêts	113
Chapitre II – Participation aux acquêts.....	115
Section 1 – Modèle proposé par le Code civil français	115
A – Le patrimoine des époux.....	115
B – Les pouvoirs sur les biens.....	115
C – La dissolution du régime.....	116
Section 2 – Modèle franco-allemand	118
A – Champ d’application	118
B – Principales différences avec la participation aux acquêts du Code civil français.....	118
Section 3 – Liquidation alternative en régime de participation aux acquêts.....	120
Corrigés des exercices.....	127

Introduction

Le droit des régimes matrimoniaux est l'un des piliers du droit patrimonial de la famille. Il trouve sa place aux côtés du droit des libéralités et des successions.

Le choix du régime matrimonial constitue souvent l'un des premiers actes patrimoniaux du couple et c'est aussi un point stratégique.

La matière offre beaucoup de souplesse et une grande liberté dans la rédaction de la convention matrimoniale, ce qui permet de construire un contrat sur mesure avec le couple. Le droit des régimes matrimoniaux est important tant pendant le mariage à plusieurs points de vue : quel contrat d'association pour le couple ? Quel degré d'autonomie ou de cogestion dans les décisions ? Quel degré d'indépendance ou de mise en commun dans la constitution du patrimoine ? Quelle protection vis-à-vis des créanciers ?

Autant de questions à se poser avant de choisir.

Mais ce n'est pas tout. La convention matrimoniale est importante également en ce qui concerne la transmission du patrimoine. Dans l'hypothèse d'un décès, quels droits puis-je assurer à mon conjoint ? Que laisserai-je alors à mes enfants ?

Enfin, il ne faut jamais oublier que le mariage peut s'achever par un divorce. Les statistiques nous y invitent. Et notre devoir de conseil également. Nous évoquerons donc les effets d'un divorce sur les mesures mises en place dans la convention matrimoniale.

Les possibilités sont nombreuses mais encore faut-il les connaître et maîtriser également leurs limites.

Nous pouvons d'ores et déjà indiquer sommairement ce qu'est un régime matrimonial. Le régime matrimonial est un ensemble de règles de droit applicables à un couple qui présente une communauté de vie et une communauté d'intérêts. Ces règles régissent les relations pécuniaires et patrimoniales entre les époux eux-mêmes, d'une part ; et entre le couple et les tiers d'autre part.

Connaître le régime matrimonial d'une personne est primordial car cela a diverses incidences en matière patrimoniale.

D'abord, il faut se pencher sur la qualification des biens appartenant à une personne mariée : le bien lui appartient-il exclusivement ou le bien est-il commun au couple ?

Ensuite, il convient de regarder les pouvoirs de dispositions sur un bien : l'époux propriétaire peut-il vendre seul son bien ? S'agit-il du logement de la famille ?

Puis vient la question du financement du bien et de ses éventuelles améliorations : quel patrimoine a réellement supporté les travaux d'amélioration sur tel bien immobilier par exemple ? Y a-t-il lieu à récompense ? Existe-t-il des créances entre époux ?

Il n'est pas possible de répondre à toutes ces questions sans connaître au préalable le régime matrimonial du client. L'établissement d'un audit patrimonial nécessite ainsi des connaissances approfondies en la matière.

L'objectif de ce cours est de vous permettre d'acquérir les connaissances nécessaires pour être en capacité de faire des préconisations en matière de régime matrimonial.

Cela nécessite de connaître les aménagements conventionnels possibles ainsi que les conséquences et les limites de ces aménagements selon que l'union prendra fin par un divorce ou un décès.

Et tout cela devra se faire de concert avec le notaire des clients, seul professionnel à pouvoir établir une convention matrimoniale.

Partie I – DÉTERMINATION DU RÉGIME MATRIMONIAL

Chapitre I – En présence d'élément(s) d'extranéité : droit international privé, convention de La Haye et règlements européens

En présence d'éléments d'extranéité, la détermination du régime matrimonial applicable aux époux est fonction de plusieurs paramètres : date du mariage, existence d'un choix de loi, modification apportée au régime initial. Il faut ajouter à cela que parfois le régime matrimonial a pu changer sans aucune initiative juridique de la part des époux ; il s'agit de la mutabilité automatique.

L'ambition n'est pas ici d'étudier le droit international privé mais simplement de donner quelques repères et éléments clés permettant de créer un réflexe d'alerte sur la possible application d'une loi étrangère dans certaines circonstances.

Section 1 – Mariages et conventions matrimoniales conclus avant le 1^{er} septembre 1992 : règles de droit commun

La loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye est déterminée par le droit commun alors applicable.

Les règles en sont résumées dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 1991¹ :

« selon la règle française de conflit de lois, la loi applicable au régime matrimonial est celle choisie par les époux qui, à défaut de manifestation expresse de volonté, sont présumés avoir soumis leurs relations pécuniaires à la loi de leur premier domicile conjugal ».

A – Epoux mariés sans contrat

A défaut de contrat de mariage, il convient donc de rechercher qu'elle était la volonté implicite des époux. A défaut de pouvoir déterminer cette volonté implicite, la loi applicable au régime sera celle du lieu de leur premier domicile matrimonial².

A défaut de contrat de mariage, les époux sont alors soumis au régime légal ainsi déterminé, et ce, pour l'ensemble de leur patrimoine.

En cas de difficultés pour déterminer le premier domicile matrimonial, peuvent être pris pour indices la fixation du centre des intérêts pécuniaires des époux ou la localisation des intérêts du ménage³.

Enfin, lorsque la situation ne permet pas de déterminer avec certitude la loi applicable (changement fréquent de domicile et pas de centre des intérêts pécuniaires), les époux ont la possibilité d'introduire une action déclaratoire en détermination de la loi applicable au régime légal. Il convient alors d'assigner le Ministère public sur requête conjointe des époux. Attention toutefois, le jugement qui sera rendu est en principe inopposable aux tiers.

¹ CA Paris, 31 oct. 1991, *JDI* 1992. 373, note L. Idot, *D.* 1991, IR 285.

² Cass. 1^{re} civ., 28 mars 2012, n°11-12.940 et 11-12.995.

³ Jurisprudences précitées.

B – Époux mariés avec contrat

Les règles de droit commun applicables aux époux mariés avant le 1^{er} septembre 1992 reposaient sur le principe de l'autonomie de la volonté. Les époux avaient alors toute latitude pour choisir la loi applicable à leur régime matrimonial.

Il semblerait que ni la pratique notariale ni la jurisprudence n'aient eu à connaître d'époux qui auraient choisi d'une manière arbitraire une loi sans aucun rapport avec leur situation juridique. Dans les rares situations où la jurisprudence a traité d'époux qui avaient expressément choisi la loi applicable, on relève que le choix avait porté sur la loi nationale d'un des époux¹.

C – Changement de régime matrimonial

Le changement de régime matrimonial est régi par la loi applicable. Il sera donc possible ou non, selon que la loi applicable connaît ou non le principe d'immutabilité.

De la même manière, il conviendra de s'en référer à la loi applicable pour savoir si la modification du régime est soumise ou non à un formalisme particulier.

Enfin, la modification du régime matrimonial est en principe sans effet rétroactif.

Section 2 – Mariages et conventions matrimoniales conclus entre le 1^{er} septembre 1992 et le 29 janvier 2019 : application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux

La convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est entrée en vigueur en France le 1^{er} septembre 1992.

Cette convention s'applique aux régimes matrimoniaux mais ne s'applique pas aux obligations alimentaires entre époux ni aux droits successoraux du conjoint survivant.

La convention s'applique entre les États qui l'ont ratifiée et dans les rapports entre les États signataires et les États tiers.

Les États signataires sont : la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche et le Portugal.

A – Époux mariés sans contrat

En l'absence de choix volontaire, la convention de La Haye fixe de manière hiérarchisée les facteurs de rattachement pour déterminer la loi applicable, à savoir :

- ✓ Loi de l'État dans lequel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage
- ✓ À défaut de résidence habituelle commune, la loi de la nationalité commune des époux,
- ✓ À défaut de résidence habituelle dans le même État et de nationalité commune, la loi de l'État « avec lequel, compte tenu des circonstances, il présente les liens les plus étroits ».



Attention

Si les époux sont de même nationalité, c'est la loi de leur nationalité commune qui sera applicable notamment lorsqu'ils établissent leur première résidence commune dans un État non signataire de la convention de La Haye et dont le droit international privé prescrit également l'application de la loi de la nationalité commune des époux.

¹ Dalloz, Rép. Droit international, n°12.

B – Époux mariés avec contrat

En présence d'un élément d'extranéité, les époux pouvaient choisir **la loi applicable** à leur régime matrimonial. Le choix de loi n'est ici pas complètement libre puisque l'article 3 (al. 2) de la Convention de la Haye, prévoit que seules peuvent être désignées :

- ✓ la loi d'un État dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation,
- ✓ la loi de l'État sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation,
- ✓ la loi du premier État sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.

Soit au total six options éventuelles si les nationalités ou les résidences des futurs époux étaient distinctes.

Précisons qu'il convient alors non seulement de choisir la loi applicable mais également le régime matrimonial suivant les possibilités offertes par cette loi.

C – Changement de régime matrimonial

1 – Mutabilité volontaire

Comme pour les époux mariés avant le 1^{er} septembre 1992, le changement de régime matrimonial est régi par la loi applicable.

La convention de La Haye introduit néanmoins dans son article 6 une possibilité intéressante pour les époux de procéder à un changement de loi applicable.

Cette possibilité est offerte à tous les époux, qu'ils aient fait ou non un contrat de mariage, et même s'ils se sont mariés avant le 1^{er} septembre 1992.

L'article 6 de la Convention concernant la mutabilité volontaire de la loi applicable au régime matrimonial n'est applicable que lorsque les époux désirent désigner une loi autre que celle jusqu'alors applicable. L'article 6 ne peut être utilisé que pour opérer un changement et non une confirmation de loi déjà applicable.

Il faut un élément d'extranéité.

Les époux peuvent alors choisir de désigner pour nouvelle loi applicable à leur régime matrimonial :

- ✓ La loi de l'État dont l'un d'eux a la nationalité au moment de cette désignation
- ✓ La loi de l'État sur le territoire duquel l'un d'eux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation
- ✓ Pour tout ou partie des immeubles, leur lieu de situation (même si les époux n'ont pas fait de choix de loi applicable à l'ensemble de leurs biens)

Attention



En pratique, cette dernière possibilité était fréquemment proposée pour faciliter la transmission du patrimoine au survivant. Il était notamment recommandé à des couples étrangers faisant une acquisition immobilière en France de prévoir que pour ces biens, les époux désignaient la loi française applicable et se soumettaient par exemple au régime de la communauté universelle de droit français avec clause d'attribution intégrale au profit du survivant des époux. Cela était particulièrement intéressant pour les époux dont la loi nationale était peu ou moins protectrice pour le conjoint, par exemple les couples anglais.

Attention toutefois, cette désignation de loi applicable doit être faite sous la forme d'un contrat de mariage et ne peut donc pas résulter de l'acte d'acquisition.

Ce changement de loi volontaire doit être fait dans un écrit dans la forme des contrats de mariage (sans homologation judiciaire). Le formalisme est donc moins lourd que la procédure de changement de régime de droit français même si celle-ci tend à se simplifier (C. civ., art 1397). L'article 6 de la convention de La Haye permet ainsi un changement de régime simplifié, à condition toutefois de changer de loi applicable et non seulement de régime matrimonial dans une même loi.

En principe, ce changement de loi s'applique rétroactivement à compter du mariage, sous réserve des droits des tiers. Mais il est possible d'écarter cette rétroactivité.

2 – Mutabilité involontaire

Attention : pour les époux mariés sans contrat après le 1^{er} septembre 1992, il existe des hypothèses de « mutabilité automatique ».

A partir du moment où les époux fixent leur résidence habituelle dans l'État dont ils ont tous les deux la nationalité (où qu'ils acquièrent cette nationalité) alors la loi de cet État se substitue à la loi qui était antérieurement applicable à leur régime matrimonial.

Illustration



Des époux, français, mariés sans contrat au France en 1993 et dont la première résidence habituelle est en Angleterre seront soumis à la loi anglaise et donc régime légal anglais de la séparation de biens.

S'ils déménagent en France pour y fixer leur résidence habituelle, alors la loi applicable à leur régime matrimonial sera la loi française dès leur établissement et sans effet rétroactif. Ainsi, et sans doute sans le savoir, ces époux passeront d'un régime de séparation de bien de droit anglais à un régime de communauté réduite aux acquêts de droit français.

De la même manière, lorsque les époux s'établissent dans un autre État et y fixe leur résidence habituelle pendant plus de 10 ans, c'est la loi de cet État qui s'applique à leur régime matrimonial.



Illustration

Des époux marocains, mariés sans contrat en France en 1996, où ils ont leur première résidence habituelle. En 1998, ils s'installent au Portugal, où ils vivent toujours. Initialement soumis à la loi Française, ils seront soumis à la loi portugaise à compter de 2008, soit après 10 ans passé au Portugal.

Section 3 – Mariages et conventions matrimoniales conclus depuis le 29 janvier 2019 : application du règlement européen (UE) du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux

Les règlements européens du 24 juin 2016 n° 2016/1103 et 2016/1104 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés sont entrés en vigueur le 29 janvier 2019.

Ils concernent la détermination de la loi applicable aux rapports patrimoniaux mais également la juridiction compétente en cas de conflit.

Ces règlements sont applicables dans les 18 États membres de l'Union européenne qui avaient demandé l'instauration d'une coopération renforcée pour l'adoption de ces règlements : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Slovaquie et Suède.

Ne sont pas concernés à ce jour les États suivants : Danemark, Estonie, Hongrie, Irlande, Royaume-Uni, et Pologne. Ces pays continuent à appliquer leurs règles de droit international privé en la matière.

Précisons toutefois que le règlement a un caractère universel et que la loi désignée comme loi applicable par le règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre (art. 20).

La loi applicable au régime matrimonial régit l'ensemble des biens des époux, quelle que soit leur nature et leur localisation. Il n'est pas possible de déroger à cette unité de loi applicable au régime matrimonial. Le règlement est en cela différent de la convention de La Haye qui permettait une sorte de morcellement en prévoyant que les époux pouvaient choisir spécifiquement pour les biens immobiliers une loi applicable suivant leur lieu de situation (art. 6 de la convention de La Haye).

Sont donc concernés les époux mariés à compter du 29 janvier 2019, mais aussi tous les époux qui désignent une nouvelle loi applicable à leur régime matrimonial postérieurement à cette date la loi.

A – Époux mariés sans contrat

A défaut de choix de loi, l'article 26 fixe de manière hiérarchisée les facteurs de rattachement pour déterminer la loi applicable, à savoir :

- La loi de l'État sur le territoire duquel les époux fixent leur première résidence habituelle commune après la célébration du mariage.
- A défaut, la loi de la nationalité commune au moment du mariage. Ce critère ne peut pas être utilisé lorsque les époux disposent de plusieurs nationalités communes.

- A défaut, la loi de l'État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.

À titre exceptionnel et à condition qu'un des époux le demande, l'autorité judiciaire compétente peut décider que la loi d'un autre État que celui de la première résidence habituelle commune après la célébration du mariage s'applique (art. 22.3).

B – Époux mariés avec contrat

En présence d'un élément d'extranéité, les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial au moment de leur mariage et désigner soit :

- la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention; ou
- la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention.

Soit au total quatre options éventuelles si les nationalités ou les résidences des futurs époux sont distinctes.

Une fois la loi applicable choisie, les époux devraient pouvoir choisir le régime matrimonial légal ou un régime conventionnel. Le règlement n'indique pas clairement ce dernier choix (entre régime légal ou conventionnel) mais cela pourrait résulter de l'interprétation du considérant 18 ainsi que de la réponse apportée à la même question lors de l'entrée en vigueur de la convention de La Haye (soutenu que l'article 1397-3 du Code civil permet de choisir non seulement la loi applicable mais également le régime matrimonial).

C – Changement de régime matrimonial

Suivant les règles antérieures et habituelles, le changement de régime matrimonial est régi par la loi applicable.

Le règlement européen reprend la possibilité de changer la loi applicable introduite par La Haye Il restreint toutefois le choix de la loi qui peut être désignée, à savoir :

- La loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'un des époux au moment de cette désignation
- La loi de la nationalité de l'un des époux au moment de cette désignation.

La désignation de la loi applicable doit résulter d'un écrit satisfaisant aux conditions de forme prévues par la loi applicable au régime matrimonial et par la loi de l'État membre dans lequel les époux ont leur résidence habituelle.



Important : il n'existe plus de mutabilité automatique pour les époux mariés à compter du 1^{er} 29 janvier 2019.

Chapitre II – En l’absence d’élément d’extranéité : le droit interne français

Section 1 – Les époux n’ont pas fait de contrat de mariage et n’ont jamais modifié leur régime matrimonial

Les époux qui n’ont jamais fait de contrat de mariage et n’ont jamais modifié leur régime matrimonial sont soumis au régime légal.

Deux régimes légaux se sont succédé en France : d’abord le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, puis celui de la communauté réduite aux acquêts, devenue régime légal suite à la loi du 13 juillet 1965.

Les époux mariés sans contrat avant le 1^{er} février 1966 (date d’entrée en vigueur de la loi de 1965) sont donc soumis à l’ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts.

Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, ces époux ont eu la possibilité d’adopter le nouveau régime légal par déclaration devant notaire.

Les époux mariés sans contrat à partir du 1^{er} février 1966 sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Section 2 – Les époux ont fait un contrat de mariage et/ou une convention modificative

Les futurs époux ont la possibilité de conclure un contrat de mariage avant leur union, qui prendra effet au jour de la célébration devant l’officier d’état-civil.

Les personnes mariées, avec ou sans contrat, ont également la possibilité modifier leur régime matrimonial suivant un formalisme spécifique étudié ci-après.

Réflexe pratique : mes clients ont-ils fait un contrat de mariage ou un changement de régime ?



Pour s’assurer qu’aucun contrat de mariage ou changement de régime matrimonial n’a été fait, il convient de demander aux clients une copie intégrale de leur acte de mariage récent (moins de 3 mois). Ils peuvent en faire la demande par internet si la commune de leur lieu de naissance le permet, sur le site service-public.fr. À défaut, ils devront faire la démarche auprès de la mairie où a été célébrée leur union.

Pour les Français mariés à l’étranger, s’ils ont fait la demande transcription à l’état civil français, il est également possible d’obtenir les documents le site service-public.fr.

Réflexe pratique : quelles sont les règles du régime matrimonial de mes clients ?



S’il a été fait un contrat de mariage ou un changement de régime, il est impératif de demander la copie de ces actes aux clients pour connaître les règles du jeu : si la référence à un modèle-type du Code civil est un élément clé connu des clients (« *nous sommes mariés en communauté universelle* »), beaucoup de variantes et d’aménagements sont possibles. *Le contrat est la loi des parties* : c’est la convention matrimoniale qui compte. Conseiller sans contrat, c’est renseigner à l’aveugle !

Chapitre III – Choisir et aménager le régime matrimonial en droit français

Section 1 – Principe de liberté des conventions matrimoniales et limites

A – Principe de liberté des conventions matrimoniales

C'est dès le premier article du Titre V du Code civil consacré au contrat de mariage et aux régimes matrimoniaux que le législateur énonce le principe de liberté des conventions matrimoniales.

Article 1387 du Code civil :

« La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent. »

Ainsi les époux peuvent choisir parmi les cinq régimes proposés par le Code civil. Mais il leur est également possible de combiner plusieurs régimes, comme dans l'hypothèse de l'adjonction d'une société d'acquêts à un régime de séparation de bien (étudié infra).

Il est même loisible de construire un régime complètement sur mesure pour un couple.

Le texte annonce cependant quelques limites que nous abordons ci-après.

B – Limites

1 – Limites générales relevant du Code civil

Première limite énoncée dès l'article 1387 précité : le respect des **bonnes mœurs**. Il s'agit de la transposition de la disposition générale prévue par l'article 6 du Code civil (*« on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »*)

Les bonnes mœurs et l'ordre public matrimonial sont difficiles à définir car ils sont tributaires de l'évolution de l'institution du mariage. On constate globalement l'application de l'ordre public de protection au service de l'égalité entre l'homme et la femme, et du respect des libertés individuelles.

Il est notamment impossible de renoncer à l'irrévocabilité des donations de biens présents prenant effet pendant le mariage ou encore de prévoir quoi que ce soit sur la prestation compensatoire en cas de divorce.

Les époux ne peuvent pas non plus déroger aux **droits ni aux devoirs qui résultent du mariage**, ni aux **règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle** (C. civ., art. 1388)

Aucune clause du contrat de mariage ne peut donc déroger aux règles du régime primaire qui s'imposent dans tous les régimes matrimoniaux.

Ainsi les époux ne peuvent déroger ni à l'article 212 imposant aux époux respect, fidélité, secours et assistance mutuels ; ni à l'article 213 sur l'éducation des enfants ; ni à l'article 215 protégeant le logement de la famille.

Serait également prohibée la clause qui priverait un époux de demander la séparation de biens judiciaire ou le divorce ou encore les clauses qui établiraient un nouveau régime des dettes ménagères (art. 220) ou qui réduiraient les pouvoirs des époux avec les tiers (art. 221, 222) ou sur leurs biens personnels (art. 225).

EXERCICE N°1

Géraldine et Nicolas vont bientôt se marier. Ils envisagent de faire un contrat de mariage pour adopter la séparation de biens. Ils n'ont pas encore d'enfant mais veulent prévoir que Nicolas aura seul pouvoir pour exercer l'administration légale quant aux biens de leurs enfants durant leur minorité.

Question :

Cela est-il possible ?

Réponse :

2 – Principe de corrélation actif/passif

S'ils prévoient le partage inégal d'une communauté les époux sont tenus au respect du principe dit de "corrélation de l'actif et du passif". Exprimé à l'article 1524 al.2 en ce qui concerne l'attribution intégrale, à 1526 alinéa 2 pour l'adoption de la communauté universelle, mais aussi à l'article 1521 alinéa 2 pour toutes les stipulations de parts inégales, quelle que soit la communauté à laquelle elles sont destinées à s'appliquer.

Est prohibée, la clause qui prévoirait l'attribution intégrale au conjoint survivant et le dispenserait de prendre en charge le passif.

Est également prohibée la clause qui prévoirait un partage inégal de la communauté avec une quote-part de passif inférieure ou supérieure à cette répartition (ex : le survivant sera attributaire de 60% de la communauté mais à charge pour lui de supporter 40% ou 70% des dettes). De la même façon, sont prohibées les clauses qui feraient supporter tout ou partie des dettes afférentes aux biens meubles à l'attributaire des biens immeubles, ou inversement.

Il en va de même des clauses qui, prescrivant un partage inégal de l'actif, mettent à la charge d'un époux, non pas une quotité de passif, mais une dette déterminée dont le montant ne serait pas en concordance avec la part active de cet époux.

3 – Principe d'immutabilité du régime matrimonial

Originellement, le régime matrimonial (légal ou conventionnel) ne pouvait pas être modifié après la célébration du mariage.

Ce principe a depuis été largement assoupli au point que l'on s'accorde aujourd'hui à parler de mutabilité contrôlée plutôt que d'immutabilité.

La règle d'immutabilité était fondée sur plusieurs raisons.

Le droit coutumier prohibait les donations entre époux. Cette prohibition reposait sur la crainte qu'un époux n'exerce des pressions sur l'autre. Permettre une modification du régime matrimonial aurait permis de contourner cette prohibition.

Seconde raison :

Puis l'idée qui a pris plus de force est que ce principe d'immutabilité peut être fondé sur la protection des tiers. La mutabilité du régime risquerait d'induire constamment ceux-ci en erreur sur les pouvoirs des époux et par suite sur la validité des contrats par eux conclus.

En vertu de ce principe d'immutabilité, devenu en réalité un principe de mutabilité contrôlée, une modification du régime matrimonial ne peut résulter que de la procédure de changement matrimonial édictée aux articles 1397 et suivants du Code civil.

Ce principe interdit d'apporter toute modification au régime matrimonial sans respecter le formalisme de l'article 1397 du Code civil mais plus subtilement, nous attirons votre attention sur des exemples pratiques pouvant porter atteinte à ce principe :

- Il n'est pas possible de liquider une communauté pendant le mariage : c'est seulement à la fin du régime, sa dissolution, que cette liquidation sera possible. Il est ainsi prohibé de renoncer, d'aménager, voire de procéder aux règlements des récompenses pendant le cours du régime.
- Il n'est pas possible de modifier la nature propre ou commune d'un bien sans respecter le formalisme de l'article 1397. Pour cette raison, les ventes entre époux communs en biens sont considérées comme nulles par la doctrine majoritaire si elles se traduisent par un changement de nature du bien (une épouse qui vendrait un bien propre à son époux lequel paierait avec des deniers communs).

Enfin, notons que le principe d'immutabilité ne s'impose pas aux tiers.

Le donateur peut ainsi prévoir expressément que le bien donné entrera en communauté si le donataire est marié sous un régime de communauté ou, à l'inverse, sera exclu de toute communauté existante ou qui pourrait exister à l'avenir.

Précisons que cette faculté est offerte au donateur par l'article 1405, alinéa 2 du Code civil. Il ne lui est pas permis d'aller au-delà, et notamment de prévoir une entrée en communauté conditionnelle (ex : le bien donné fera partie de la communauté de biens existant entre le donataire et son conjoint, à la condition qu'ils ne divorcent pas).

EXERCICE N°2

Il y a 4 ans, Stéphane a utilisé des deniers propres pour faire les travaux de réfection complète de la toiture de la résidence principale qu'il détient en communauté avec son épouse Marion. La toiture était déjà en mauvais état lorsque le couple a acquis cette maison ; il s'agit de travaux qui vont bien au-delà d'un simple entretien. Stéphane est donc créancier d'une récompense à ce titre. Le couple pensait financer cette dépense avec l'épargne salariale de Marion mais elle était indisponible. Aujourd'hui Marion peut débloquer son épargne et ils se sont entendus pour que cet argent soit affecté au remboursement de la somme avancée sur des fonds propres par Stéphane.

Question :

Que pouvez-vous leur conseiller ?

Réponses :

Section 2 – Formalisme applicable



Attention : ce formalisme s'impose qu'il s'agisse de changer de régime « type » (ex : passer d'une communauté à une séparation de biens), mais également en cas de modification moins radicale (ex : ajout d'une clause de préciput). C'est donc toute modification apportée aux règles du régime matrimonial, quelle que soit son ampleur, qui oblige à respecter le formalisme de l'article 1397 du Code civil.

La modification du régime matrimonial emprunte nécessairement la forme authentique, à peine de nullité.

Des formalités subséquentes sont nécessaires pour donner effet à l'acte.

Ces formalités ont été considérablement allégées ces dernières années, l'homologation judiciaire qui était systématique avant 2007 est devenue exceptionnelle en 2019.

A – Changement de régime réalisé avant le 1^{er} janvier 2007

Après deux années au moins d'application de leur régime matrimonial, les époux pouvaient convenir de modifier leur régime matrimonial par acte notarié soumis à l'homologation du TGI. La requête près le tribunal devait être faite par ministère d'avocat.

B – Changement de régime réalisé entre le 1^{er} janvier 2007 et le 25 mars 2019

Après deux années au moins d'application de leur régime matrimonial, les époux pouvaient convenir de modifier leur régime matrimonial par acte notarié :

- En l'absence d'enfant mineur, il convenait ensuite :
 - A la diligence du notaire, de faire publicité de l'acte sur un support habilité à recevoir des annonces légales (JAL), destinées à l'information des créanciers (annonce indiquant que tels époux avaient apporté une modification à leur régime matrimonial suivant acte reçu par tel notaire) ;
 - A la diligence du notaire, d'informer les enfants majeurs du couple.

Créanciers comme enfants majeurs disposaient alors d'un délai de trois mois pour se manifester auprès du notaire, contraignant ainsi les époux à faire homologuer leur changement de régime par le juge.



Précision : bien que l'article 1397 indique que les enfants majeurs et les créanciers disposent d'un droit à « s'opposer » au changement de régime matrimonial, ils sont en réalité impuissants à mettre un quelconque veto. Leur « opposition » oblige simplement les époux à requérir l'homologation judiciaire.



Attention : ce délai de trois mois est incompressible. Il n'est pas possible par exemple de demander aux enfants de renoncer à ce délai pour accélérer la procédure.

- En présence d'au moins un enfant mineur, il fallait nécessairement demander l'homologation au juge.

En cas de requête en homologation, le juge pouvait refuser d'homologuer, ce qui rendait l'acte caduc, ou décider d'homologuer l'acte, qui déployait alors ses effets.

C – Changement de régime réalisé à compter du 25 mars 2019

La loi de programmation pour la justice 2018-2022 est venue simplifier encore la modification du régime matrimonial :

- En supprimant le délai minimal de deux ans à respecter entre le mariage ou le précédent aménagement, et la modification ;
- En mettant un terme à l'homologation judiciaire en présence d'un enfant mineur. Désormais, le notaire chargé de la rédaction de la convention peut saisir le juge des tutelles s'il estime que l'acte compromet manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou que la situation est de nature à porter un préjudice grave à celui-ci. (C. civ., art. 387-3 sur renvoi de 1397 du même Code). Il s'agit ici du devoir d'alerte qui s'impose à tout tiers, et notamment les banques, pour les faits décrits en présence d'un mineur.

La loi de programmation a également apporté des solutions aux problèmes rencontrés par les notaires en pratique. Notamment, la loi prévoit désormais qu'en cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit (en exerçant le droit « d'opposition » ou en s'abstenant) sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.

La modification du régime matrimonial prendra effet :

- Entre les époux :
 - A la date de l'acte s'il n'est pas soumis à l'homologation ;
 - A la date du jugement d'homologation dans le cas contraire.
- Vis-à-vis des tiers : trois mois après que la mention de ce changement ait été portée sur l'acte de mariage des époux. Mais l'acte leur est opposable avant cette date si les époux les en ont informés lorsqu'ils ont passé un acte avec eux.

Apport à communauté suivi d'une donation

Il arrive que des époux décident de modifier leur régime matrimonial pour changer la nature d'un bien préalablement à une donation de ce même bien à un enfant du couple.

L'intérêt est *notamment* fiscal : le bien propre ne peut être donné que par le parent propriétaire, avec un abattement parent/enfant, actuellement 100.000 euros. Le bien propre devenu commun peut être donné par les deux parents : fiscalement chaque parent est réputé donner la moitié du bien commun, il y a donc deux donations distinctes avec, pour chacune, un abattement parent/enfant.

Évidemment, la prudence s'impose au plan fiscal en ce qui concerne la notion d'abus de droit. Si une telle opération ne peut être proscrite en principe, il faudra veiller à ce que le changement de régime ne soit pas réalisé dans un but *exclusivement* ou *principalement* fiscal.

Au plan civil, la donation ne pourra intervenir qu'après que le changement de régime ait pris effet soit, après l'homologation ou bien après l'écoulement du délai de trois mois. En effet, on ne peut jamais être sûr qu'aucun créancier ou enfant majeur ne « s'opposera » et renverra les époux à l'homologation judiciaire. Cela signifie que pendant le délai de trois mois, on ne connaît pas la nature du bien (propre ou commune).

Au fait, ça coûte combien de changer de régime matrimonial ?

Il y a autant de réponses que de dossiers. Les composantes du coût sont les suivantes :

✓ Les émoluments du notaire :

L'acte comportant changement de régime matrimonial (comme le contrat de mariage) est passé par acte authentique à peine de nullité. Les émoluments du notaire sont fonction des formalités à faire, de la nécessité ou non de liquider le régime matrimonial précédent, etc. Rappelons que les tarifs ne sont pas libres en la matière mais règlementés par décret. Pour des cas particuliers, un honoraire de conseil peut être à prévoir. En bref, le seul à pouvoir répondre, c'est le notaire !

✓ Les honoraires de l'avocat en cas d'homologation par le juge (voir *infra*), honoraires libres

✓ L'enregistrement aux impôts :

Il existait une exonération temporaire qui a pris fin le 31 décembre 2019 (art. 1133 bis anc. du CGI, abrogé par la Loi de Finances 2019, avec effet au 1^{er} janvier 2020). Depuis le 1^{er} janvier 2020, les apports sont de nouveau soumis à taxation (droit fixe de 125€ ainsi que, sur les immeubles, la Taxe de Publicité Foncière à 0,715 % et la Contribution de Sécurité Immobilière à 0,10 %).



Passer d'un régime communautaire à un régime séparatiste : faut-il partager les biens ?

Si des époux mariés sous un régime communautaire veulent adopter un régime séparatiste, alors il convient de faire une liquidation de la communauté. En effet, ce changement de régime entraîne dissolution de la communauté. A partir de ce moment-là, naît une indivision : les biens qui étaient communs deviennent indivis entre les époux.

Mais faut-il nécessairement aller plus loin et procéder au partage ?

Avant toute chose, précisons que **liquider n'est pas partager**. Une confusion est souvent faite entre ces deux termes. Pourtant l'article 1397 n'impose qu'une simple liquidation du régime.

La liquidation permet la détermination des droits des parties (évalués en euros), alors que le partage, qui est une opération postérieure, consiste à mettre fin à l'indivision en répartissant les biens entre les époux pour les remplir de leurs droits.

Suivant les termes de l'article 1397, le partage n'est pas obligatoire. En revanche, dans bien des hypothèses, il s'avèrera opportun pour optimiser le changement de régime.

Partie II – RÉGIME PRIMAIRE IMPÉRATIF ET RÉGIME LÉGAL

Chapitre I – Le régime primaire impératif

Le régime primaire est un corps de règles applicables à tout époux marié, et ce, quel que soit son régime matrimonial. Pour cette raison, il est souvent défini comme le socle commun à tous les régimes matrimoniaux.

Ces règles sont, dans leur grande majorité, impératives comme l'énonce l'article 226 du Code civil.

Certains textes du régime primaire prévoient toutefois que la convention matrimoniale peut déroger.

Parmi les lignes directrices du régime primaire, l'on retrouve l'idée que le mariage, quel que soit le régime, implique une certaine association entre les époux sans sacrifier l'indépendance de chacun.

Il s'agit pour l'essentiel de règles d'application quotidienne et dont la mise en œuvre peut ainsi être appréhendée concrètement par les époux : autonomie et présomption de pouvoirs pour la gestion de comptes bancaires, pour la perception des gains et salaires, pouvoirs exclusifs sur les biens propres, etc. Elles sont donc d'une grande importance pratique.



Le mal nommé

La dénomination « régime primaire » est malheureuse en ce qu'elle pourrait laisser penser qu'il s'agit d'un *régime matrimonial* de base. Or, s'il s'agit bien d'un ensemble de règles, d'une part elles sont impératives et non susceptibles d'aménagement par convention matrimoniale (contrairement à celles du *régime légal*), et, d'autre part, elles sont insuffisantes à constituer un véritable régime matrimonial dans son entier.

Section 1 – Contribution des époux aux charges du mariage

L'article 214 du Code civil impose aux époux de contribuer aux charges du mariage.

A – Objet de la contribution

Les charges du mariage peuvent être définies comme les dépenses ménagères.

Elles se distinguent nettement du simple devoir de secours qui s'impose aux époux et qui relève de l'obligation alimentaire.

Le devoir de secours peut en effet être défini comme le devoir de chaque époux de subvenir aux besoins matériels de l'autre en cas de nécessité.

Alors que l'obligation alimentaire recouvre, comme son nom l'indique, les seuls besoins *alimentaires*, le domaine des charges du mariage est beaucoup plus étendu.

En pratique, pendant le mariage, l'obligation pour les époux de se fournir réciproquement des aliments est comprise dans leur contribution aux charges du ménage dont les dépenses forment un ensemble indivisible.

Le périmètre des charges du mariage s'étend concrètement au train de vie la famille. Les charges du mariage comprennent les dépenses d'entretien du ménage et d'éducation des enfants, incluant la nourriture, le logement, les assurances de dommage, l'habillement, la santé

ou encore les frais de scolarité¹. Elles comprennent également toutes les dépenses d'agrément ou de loisirs : vacances, activités sportives ou culturelles, etc.



Ne pas confondre pension alimentaire et prestation compensatoire

En pratique c'est lorsque le couple va mal que l'on en revient à l'obligation alimentaire résultant du devoir de secours et notamment à travers le versement d'une pension alimentaire au profit du conjoint. Le versement d'une pension alimentaire entre époux ne peut intervenir que dans certaines hypothèses : séparation de corps ou instance en divorce. Elle cesse lorsque le mariage est dissout. Une fois le divorce effectif, il n'existe plus de devoir de secours et aucune pension alimentaire ne peut être due à ce titre².

Le divorce peut causer le versement d'une autre indemnité entre ex-conjoints : la prestation compensatoire. Elle trouve son fondement dans l'article 270 du Code civil. Notons en revanche que le parent qui assure la garde des enfants mineurs peut percevoir *pour leur compte* la pension alimentaire due par l'autre parent au profit desdits enfants. Dans ce cas, le créancier de l'obligation alimentaire est l'enfant et c'est en raison de sa minorité et de son hébergement chez l'autre parent que ce dernier va la percevoir en pratique.

EXERCICE N°3

Nadège et François divorcent. Nadège revendique une indemnisation de la communauté en raison des dépenses importantes supportées par la communauté pour assouvir la passion de François : le sport automobile.

Question :

La demande de Nadège est-elle juridiquement justifiée ? Pourquoi ?

Réponses :

B – Répartition entre les époux

La loi impose à chaque époux de contribuer aux charges du mariage.

Concernant la contribution respective de chacun, l'article 214 prévoit qu'à défaut de convention matrimoniale contraire, les époux participent à proportion de leurs facultés respectives.

S'agissant de couvrir les charges périodiques liées au train de vie des époux, la clé de répartition est généralement déterminée par les revenus respectifs des époux.

¹ J. Flour et G. Champenois, *Les régimes matrimoniaux*, Armand Colin, 2^e éd., n°62 ; F. Terré et Ph. Simler, *Droit civil, Les régimes matrimoniaux*, Dalloz, 2^e éd., n°51.

² Depuis le 1^{er} janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, dans tous les cas, le divorce met fin à l'obligation de secours entre ex-époux (C. civ., art. 270).

Il n'est cependant pas exclu de prendre en compte également les ressources des époux en capital, notamment lorsque les revenus s'avèrent insuffisants.

C – Exécution de la contribution

Les époux conviennent librement de la manière dont ils exécutent leur obligation de contribuer aux charges du mariage.

Cette contribution n'est pas exclusivement pécuniaire. Elle est également constituée de l'activité fournie par chaque époux dans le travail au foyer, les tâches domestiques, ou encore l'aide apportée au conjoint dans l'exercice de son activité professionnelle. On la nomme exécution en industrie.

Enfin, elle peut également avoir lieu en nature, par exemple par la mise à disposition à titre gratuit d'un bien immobilier personnel d'un époux au profit de la famille à titre de résidence principale ou secondaire.



Attention : *quid* en cas de séparation

La contribution aux charges du mariage oblige les époux pendant toute la durée du mariage. Ce n'est qu'une fois l'union dissoute que chacun reprend son autonomie et son indépendance sur ce plan.

En cas de divorce, la période de séparation qui précède ne fait pas exception. Quand bien même les époux ne cohabiteraient plus, ils doivent assumer, en principe à proportion de leurs facultés respectives, le train de vie de la famille.



Qu'est-ce que le délit d'abandon de famille ?

Les obligations familiales prévues par le Code civil peuvent se matérialiser par l'obligation de verser une pension ou une prestation à un proche (enfant mineur ou majeur, ascendant, conjoint). Le versement peut avoir été prévu par une décision judiciaire, une convention homologuée par le juge ou encore une convention de divorce par consentement amiable, extra-judiciaire (« divorce sans juge »).

Celui qui refuserait d'exécuter cette obligation s'expose à des sanctions. Il peut être condamné par le juge au paiement de sa dette suivant le Code de procédure civile mais il encourt également des sanctions pénales. Le refus d'exécuter le versement constitue un délit d'abandon de famille (passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende : C. pénal, art. 227-3).

Ainsi, le délit d'abandon de famille condamne le non-versement :

- D'une contribution aux charges du mariage au conjoint (non divorcé, non séparé de corps),
- D'une pension alimentaire due au titre du devoir de secours à un conjoint en instance de divorce ou séparé de corps,
- D'une prestation compensatoire à l'ex-conjoint,
- D'une pension alimentaire due à un descendant ou un ascendant.

De surcroît, si le débiteur organise frauduleusement son insolvabilité, notamment en dissimulant des biens ou des revenus, il encourt une sanction pénale supplémentaire (C. pénal, art. 314-9 et 314-7).

Section 2 – Régime des dettes ménagères

L'article 220 du Code civil édicte deux règles :

- Chacun des époux a pouvoir pour contracter seul certaines dettes,
- Celles-ci obligent l'autre époux solidairement.

Ainsi, pour éviter d'entraver la bonne marche quotidienne de la vie familiale, le législateur évite aux époux d'avoir à être deux pour engager certaines dettes/dépenses en les autorisant à les contracter seuls et, en contrepartie, prévoit pour le cocontractant que, malgré la signature d'un seul, les deux époux sont tenus solidairement. La loi donne ainsi du « crédit » à chaque époux agissant séparément, quel que soit son régime matrimonial. Ce texte, impératif, déroge aux règles habituelles en matière d'obligation au passif (étudiées infra).

Il s'agit ici des dépenses/dettes contractées pour les besoins élémentaires de la famille, celles « qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ». Entrent dans ce champ notamment : les dépenses alimentaires, les frais de scolarité, les dépenses d'habillement, le loyer du logement de la famille, les dépenses de chauffage et autres fournitures, de transports ou encore les frais de santé.

En revanche, n'entrent pas dans cette notion les dettes liées à des opérations d'investissement.

Le texte exclut également la solidarité des époux si les dépenses concernées ont bien pour objet des dettes ménagères mais qu'elles apparaissent comme « *manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.* »

Enfin, la solidarité n'a pas lieu non plus en cas d'achat à tempérament (crédit-vendeur) ou d'emprunt, sauf :

- s'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante,
- et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts¹, n'est pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

EXERCICE N°4

Marine et Loïc divorcent. Ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Marine est associée dans un important cabinet comptable et Loïc, juriste d'entreprise. La télévision du couple était hors service, alors, sans en informer Marine, Loïc avait souscrit un prêt à la consommation pour acquérir un ensemble hifi-TV-home cinéma pour 4.000 €. Loïc étant aujourd'hui sans ressources (il avait démissionné pour changer de voie professionnelle), l'organisme prêteur a adressé à Marine une mise en demeure de payer.

Question :

Marine doit-elle supporter cette dette ?

¹ Ce texte a été modifié par la loi [n°2014-344 du 17 mars 2014](#) pour adapter cette règle au développement des crédits à la consommation et au crédit revolving.

Réponse :

Section 3 – Autonomie des époux dans la vie quotidienne

L'article 225 du Code civil édicte une exclusivité de gestion de chaque époux sur ses biens propres ou personnels¹. Il n'est pas possible de déroger à cette règle pour confier, par exemple, au mari le pouvoir de disposer des biens propres de sa femme ou en prévoyant une gestion conjointe des époux sur ces mêmes biens. Chaque époux exerce seul les pouvoirs sur ses biens propres ou personnels.

Évidemment, le mandat de droit commun est toutefois possible entre époux (C. civ., art. 218).

Les articles 221 et 222 du Code civil, édictent quant à eux de présomptions de pouvoirs destinés à faciliter le quotidien.

Ainsi, suivant l'article 222, chaque époux peut agir seul sur un bien meuble dont il se présente comme seul détenteur, que ce soit pour faire un acte d'administration ou de disposition. Le tiers est dispensé d'avoir à rechercher si l'époux concerné a bien le pouvoir pour passer l'acte. Ce texte est à rapprocher de la présomption de l'article 2276 du Code civil (« En fait de meubles, la possession vaut titre. »).

Notons que cela n'est pas applicable aux meubles garnissant le logement de la famille qui sont protégés par une disposition spécifique (voir infra).

Enfin, l'article 221 édicte une présomption de pouvoirs mise en œuvre quotidiennement par tous les époux. Chacun des époux peut se faire ouvrir un compte de dépôt ou compte titres en son nom personnel sans avoir à solliciter son conjoint. L'époux est ensuite réputé avoir la libre disposition des fonds et titres. Il peut donc effectuer seul et librement des versements, des retraits, des paiements ou encore des virements.

Dit autrement, quel que soit son régime matrimonial, et qu'il s'agisse de deniers propres ou communs, chaque époux dispose d'une autonomie bancaire. Le dépositaire n'a donc pas à s'inquiéter du régime matrimonial de l'époux déposant. Le banquier est dégagé de toute responsabilité à ce sujet.



Attention : il s'agit bien ici d'une présomption de *pouvoir* et non de *propriété*. Le fait qu'un compte soit ouvert au nom personnel de l'un seul des époux lui permet d'en disposer librement mais ne permet aucunement d'affirmer qu'il a la propriété exclusive des fonds ou les détient à titre de bien propre.

¹ On utilise le terme de « propre » pour les époux mariés en communauté et de « personnel » pour les autres.



Un banquier averti en vaut deux

Lorsque le compte que souhaite ouvrir un époux commun en biens permet un découvert, le banquier doit s'inquiéter de son droit de gage. L'article 1415 du Code civil (qui sera étudié infra) pose comme règle que l'emprunt signé par l'un seul des époux communs en biens n'engage que ses biens propres et ses revenus mais non les biens communs. Dans un arrêt du 6 juillet 1999¹, la Cour de cassation considère comme applicable au découvert bancaire l'article 1415 du Code civil. En l'espèce, cela empêchait la banque, suite au défaut de paiement, d'obtenir une hypothèque sur un bien commun alors que seul un époux était intervenu pour l'ouverture du compte.

Ce point entrave donc parfois en pratique la liberté voulue par le législateur en édictant la présomption de l'article 221. L'ouverture d'un compte qui autorise un découvert peut en effet inciter l'établissement bancaire à demander l'intervention du conjoint si les époux sont mariés sous un régime communautaire.

EXERCICE N°5

Les époux MARTIN, mariés en séparation de biens pure et simple, souhaitent modifier leur régime matrimonial pour adopter une communauté réduite aux acquêts. À cette occasion, ils veulent prévoir que le consentement de Monsieur sera nécessaire en ce qui concerne les actes de disposition sur les biens propres de Madame.

Question :

Que pouvez-vous leur conseiller ?

Réponse :

Section 4 – Protection du logement de la famille

La protection du cadre de vie et notamment du toit familial est une des préoccupations majeures du droit de la famille.

Suivant l'article 215 du Code civil, le logement de la famille est choisi d'un commun accord des époux et ce choix ne peut être remis en question par la volonté unilatérale de l'un seul d'entre eux.

L'alinéa 3 de ce texte érige une protection spéciale du logement de la famille, interdisant à un époux de disposer seul des droits par lesquels sont assurés le logement de la famille. Cela signifie que, quand bien même le logement de la famille serait la propriété exclusive d'un seul des époux (à titre de bien personnel/propres), il ne pourra pas agir seul pour conclure certains

¹ Cass. civ. 1^{re}, 6 juill. 1999, n° [97-15.005](#).

actes relatifs à ce bien. Il lui faudra obtenir le consentement de son conjoint. Il s'agit d'une entorse forte au droit de propriété de l'époux.

L'article 215 protège ainsi les droits par lesquels le logement de la famille est assuré.

Il peut s'agir d'un droit réel : droit de propriété bien sûr, mais également droit d'usufruit ou encore droit d'habitation.

Il peut également s'agir d'un droit personnel : le droit au bail (et ici l'article 215 recouvre en partie le domaine de l'article 1751 évoqué ci-avant) ou encore le droit de jouissance attaché aux parts d'une société civile.

Sont également visés par cette mesure de protection, les meubles garnissant le logement de la famille.



Attention : *quid* 215 et détention indirecte du logement de la famille ?

Dans un arrêt du 14 mars 2018, la Cour de cassation est venue préciser que l'article 215 alinéa 3 peut être applicable à la cession de parts de société civile à la condition que la SCI ait conféré un droit au logement au profit des époux, par la conclusion d'un bail ou d'une convention de mise à disposition ou en vertu d'une décision des associés les y autorisant.

Dans cette affaire, des époux étaient associés d'une SCI dont l'époux était le gérant et détenait 99 parts sur 100. La famille occupait à titre de logement de la famille un appartement qui était la propriété de la SCI. En qualité de gérant autorisé par l'assemblée générale, l'époux passe l'acte de cession de l'appartement par la SCI au profit d'un tiers. L'épouse n'ayant pas consenti à cette vente, elle en demande la nullité sur le fondement de l'article 215 alinéa 3 du Code civil.

Elle est déboutée de sa demande au motif qu'elle ne pouvait justifier d'un droit à occuper le bien. En l'espèce, il n'existait aucun bail ni aucune convention de mise à disposition. Il n'y avait donc pas de « *droits par lesquels est assuré le logement de la famille* » à protéger.

Les actes visés par le texte sont les actes de dispositions, sans distinguer entre acte à titre onéreux ou gratuit. Il s'agit notamment des aliénations (vente, apport à société, donation, etc), de la constitution de droits réels au profit de tiers (hypothèque conventionnelle, gage d'un meuble meublant, etc), ou encore de la constitution d'un droit personnel à un tiers (comme un bail).

En revanche, les actes de dispositions à cause de mort ne sont pas concernés. Texte du régime primaire, l'article 215 alinéa 3 du Code civil n'a plus vocation à s'appliquer après le mariage, or le décès met fin au mariage.

La vente ou la donation avec réserve d'usufruit ne devrait pas non plus nécessiter le consentement du conjoint. Seule l'hypothèse d'une réserve d'usufruit au profit du donateur et sans constitution d'usufruit successif pour son conjoint paraissait incertaine. Mais pour les mêmes raisons qu'évoqué en matière de dispositions à cause de mort, il conviendrait de

retenir que le consentement du conjoint n'est pas à requérir. C'est ce qui a été retenu dans une décision du 22 mai 2019¹.

En cas de non-respect des dispositions de l'article 215 alinéa 3, la sanction est la nullité de l'acte, qui peut être demandée par le conjoint dans l'année suivant le jour où il a eu connaissance de l'acte passé irrégulièrement par son conjoint, sans pouvoir dépasser un an après la fin du mariage).



Attention : 215 al. 3 est applicable pendant la séparation

La protection du toit de la famille dure autant que dure le mariage.

En cas de divorce, la période de séparation qui précède ne fait pas exception. Quand bien même les époux ne cohabiteraient plus, le logement qui a constitué le toit de la famille demeure protégé. L'existence d'une ordonnance de non-conciliation autorisant l'un ou l'autre à vivre ailleurs que dans ce logement est sans incidence sur cette question². Il convient donc de savoir si les époux sont ou non divorcés et si ce divorce a pris force de chose jugée le cas échéant. Tant que le divorce n'est pas effectif, le consentement du conjoint sera nécessaire.

À titre complémentaire, indiquons que lorsque le toit est assuré par un bail à usage exclusif d'habitation, et même s'il a été conclu avant le mariage, l'article 1751 du Code civil prévoit que les époux en sont cotitulaires. Cela signifie qu'en cas de divorce, le droit au bail peut être attribué à l'un ou l'autre des époux sans égard au signataire initial. En cas de décès, le survivant est toujours titulaire exclusif du droit au bail (sauf s'il y renonce).

Ces dispositions sont applicables même si le contrat de bail est antérieur au mariage. Pour en bénéficier, ils devront toutefois informer leur bailleur de leur mariage.

On rappellera qu'au surplus, le conjoint marié bénéficie, en de de décès de son époux, d'un droit temporaire d'un an au logement suivant les dispositions de l'article 763 du Code civil.

Section 5 – Autonomie des époux dans la vie professionnelle

Suivant l'article 223 du Code civil, chaque époux est libre de choisir une profession et la manière de l'exercer. Chacun dispose d'une totale liberté et indépendance professionnelle. Chaque époux perçoit également en toute indépendance ses revenus professionnels, qu'il s'agisse de salaire ou d'autres modalités de rétributions (primes, indemnités, etc) et a le pouvoir d'en disposer seul après s'être acquitté des charges du mariage.

Section 6 – Mesures de crise

Le régime primaire est également le siège de mesures dites mesures de crise, dont l'objectif est de pallier l'inertie, l'absence ou l'éloignement, la défaillance ou encore l'incapacité d'un époux.

En effet, la participation des deux époux requise pour certains acte entraîne, de fait, un risque de dysfonctionnement voire de paralysie.

¹ Cass. 1^{re} civ., 19 mai 2019, n° [18-16.666](#).

² Cass. 1^{re} civ., 26 janv. 2011, n°09-13.138.

Ainsi, c'est dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale que naissent certaines dispositions¹, afin de remédier à l'éloignement de nombreux époux.

Aujourd'hui deux textes ont vocation à régir ces situations de crise : les articles 217 et 219 du Code civil.

A – Représentation judiciaire d'un époux par son conjoint (C. civ., art. 219)

L'article 219 du Code civil prévoit la possibilité de recourir à une représentation judiciaire d'un époux par son conjoint s'il est hors d'état de manifester sa volonté. L'impossibilité de manifester sa volonté peut tenir à plusieurs causes comme l'incapacité, l'absence ou l'éloignement. En revanche, il n'est pas possible d'agir sur le fondement de l'article 219 pour passer outre le refus d'un conjoint à passer un acte.

Dans ces circonstances, si un acte doit être passé et relève en principe du pouvoir de l'époux « empêché », son conjoint peut s'adresser au juge pour se faire habilité en justice à passer l'acte à sa place. On parle alors de mandat judiciaire. Comme tout mandat, il peut être délivré en vue de passer un ou plusieurs actes particuliers (qu'ils soient d'administration ou de disposition) ou pour représenter l'époux de manière générale (mais alors seuls les actes d'administration sont autorisés). La durée de ce mandat n'est pas légalement enfermée dans un délai mais le juge peut en fixer un. La disparition de la cause (incapacité, éloignement ou autre empêchement) devant de toute façon y mettre fin.

Le recours à ce texte peut, par exemple, être utilisé lorsque l'un époux, devenu insane d'esprit, est propriétaire à titre personnel d'un bien immobilier auquel il ne peut plus se rendre en raison de son état de santé et du coût des déplacements et dont la vente apparaît en conséquence comme raisonnable au plan patrimonial².

B – Autorisation judiciaire donnée à un époux pour passer seul un acte (C. civ., art. 217)

L'article 217 du Code civil prévoit quant à lui une autorisation judiciaire délivrée au profit d'un époux pour passer seul un acte pour lequel le concours de son conjoint est nécessaire et si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou s'il oppose un refus qui n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

Cette fois il s'agit d'un acte pour lequel les deux époux doivent intervenir, mais la signature de l'un ne peut être obtenue.

Les causes sont ici élargies : à l'impossibilité de manifester la volonté, il est ajouté la situation de l'époux récalcitrant. Ce texte permet ainsi de passer outre le refus du conjoint si celui-ci n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

Le recours à ce texte peut être utilisé pour la vente d'un bien immobilier commun lorsque l'un des époux est devenu insane d'esprit ou lorsqu'il s'y oppose pour des raisons fallacieuses.

¹ Loi du 22 septembre 1942.

² Cass. 1^{re} civ., 18 févr. 1981, n°[80-10.403](#).



Conseil pratique

Cette mesure peut permettre de remédier à la paralysie causée par la mésentente des époux, notamment durant la période de séparation qui précède le divorce effectif, en ce qui concerne la cogestion applicable aux biens communs par exemple ou encore la vente du logement de la famille protégé par les dispositions de l'article

251 alinéa 3.

C – Place de ces mesures parmi les protections juridiques des personnes vulnérables

Si ces mesures semblent peu connues du grand public, il est important de souligner qu'elles ont une place importante dans l'arsenal législatif lié à la protection des personnes vulnérables. Les mesures de protection judiciaires que sont la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle ou encore l'habilitation familiale sont tenues pour subsidiaires. Le principe de subsidiarité posé par l'article 428 du Code civil signifie qu'aucune mesure de protection ne peut être ouverte si l'intéressé est marié et que le recours à l'article 217 ou 219 est suffisant pour pallier aux difficultés de l'espèce.



Attention : nouveauté !

Ajoutons que, la loi de programmation pour la justice 2018-2022¹ a modifié la rédaction de l'article 428 suite aux demandes des praticiens. Dans sa rédaction antérieure, le texte prévoyait la primauté des règles du régime matrimonial sur toutes les mesures de protection. En cas de conclusion d'un mandat de protection future, le mandant n'était donc pas certain que ses choix seraient mis en œuvre, voire que le mandataire choisi soit « évincé » par son conjoint sur le fondement de l'article 219 du Code civil.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article 428 place désormais le mandat de protection future à la première place. Si un mandat de protection future a été rédigé, il s'impose.

Un argument supplémentaire pour y recourir !

Enfin, l'intérêt pratique des dispositions étudiées peut résider dans le fait qu'elles sont généralement moins lourdes et moins longues à mettre en place qu'une tutelle ou curatelle, lorsque l'on veut confier la mission de protection au conjoint de la personne vulnérable.

En pratique, pour obtenir un mandat judiciaire (219) ou une autorisation judiciaire (217), l'époux adresse sa requête au juge (CPC, art. 1286 et s.), accompagnée de tous les éléments permettant de la justifier et de préférence avec un certificat d'un médecin spécialiste ou du médecin traitant lorsqu'il s'agit d'une hypothèse d'incapacité ou de discernement. L'époux demandeur sera entendu par le juge, qui doit également convoquer ensuite son conjoint. Le magistrat rend ensuite sa décision, qui est susceptible d'appel.

En revanche, ces mesures sont moins efficaces que l'habilitation familiale si l'on souhaite une représentation générale car dans ce cas, les actes de dispositions ne sont pas permis (à l'inverse de l'habilitation familiale).

¹ LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Chapitre II – Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts

Ce régime a été instauré par la loi du 13 juillet 1965 et s'applique aux époux mariés sans contrat à compter du 1^{er} février 1966. Il remplace l'ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts.

Le régime de la communauté réduite aux acquêts est défini aux articles 1400 et suivants du Code civil.

Ce régime comporte 3 masses de biens : les biens propres de l'un, les biens propres de l'autre, les biens de la communauté.

Section 1 – Le patrimoine des époux

A – Les actifs

1 – Biens communs

L'article 1401 du Code civil précise la composition de la communauté. Elle se compose des acquêts faits pendant le mariage par les époux ensemble ou séparément, avec des fonds provenant de leurs gains et salaires, des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres non consommés, des biens communs par la volonté du donateur ou du testateur. Les acquêts comprennent tous les biens meubles ou immeubles, acquis à titre onéreux par l'un des époux ou les deux pendant le mariage.

Les revenus sont la généralement la plus importante source d'alimentation de la communauté, qu'il s'agisse des revenus du travail ou des revenus des biens communs ou propres.

a – Gains, salaires et substituts

Sont communs tous les revenus professionnels des époux, issus de leur industrie personnelle. La jurisprudence admet de longue date leur caractère commun¹. Ils revêtent d'ailleurs la qualification de biens communs *ab initio*, soit dès avant leur perception de sorte que la créance de salaire est commune².

- Retraite

Lorsque l'époux est retraité, les primes et pensions de retraite versées pendant l'union à un époux commun en biens dépendent de la communauté. Dit autrement, lorsque l'époux a atteint l'âge de la retraite et fait valoir ses droits, les sommes reçues sont des substituts de revenus et constituent donc des biens communs.



Attention : la question de la nature de la retraite surcomplémentaire lorsque l'époux n'a pas encore fait valoir ses droits à retraite reçoit une réponse différente en jurisprudence (voir *infra*, biens propres par nature pages et 43 suivante).

- PEE, intéressement et participation

¹ Cass. Civ 1^{ère} 8 février 1978 Bull civ I n°53 ; Civ 1^{ère} 31 mars 1992 Bull civ I n°95

² Cass. Civ. 13 oct 1993 JCP 1994.I.3785 n°2 ; Cass civ 1^{ère} 3 févr. 2010 n°09-65345 D. 2010 442; Cass civ 1^{ère} 5 mars 2008 AJ fam 2008.215; Cass. Civ. 1^{ère} 29 juin 2011 n°10.20322 RTDCiv 2011.577

Sont également communes les sommes versées sur un Plan d'Épargne Entreprise : intéressement, participation et abondement de l'employeur.

Selon l'article L. 3332-1 du Code du travail, « *Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières* ».

Il constitue l'une des modalités de l'épargne salariale, figurant au titre III du livre III du Code du travail relatif au *Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale*.

S'agissant de l'épargne salariale, notamment des PEE, plusieurs décisions lui ont conférée le caractère de bien commun dès lors que les deniers investis trouvent leur origine dans l'activité salariée de l'époux durant le mariage¹.

▪ Stocks options

Un certain nombre de sociétés gratifient notamment leurs cadres de *management packages* s'ajoutant au salaire. On trouve dans ces *packages* des stocks options. En clair, des droits d'option offerts au salarié et lui permettant d'acquérir à une date et un prix déterminés à l'avance (et en principe inférieur au marché) des actions de la société dans laquelle il travaille. Ces options d'achat ne sont ni plus ni moins qu'une rémunération de leur travail. Arrivé à la date prévue, le salarié pourra lever l'option pour devenir propriétaire d'actions de sa société. Depuis une importante décision de la Cour de cassation rendue en 2014, les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature mais les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent en communauté lorsque l'option est levée durant le mariage². La jurisprudence distingue donc l'option de l'action.

Ainsi les options acquises pendant le mariage sont des propres par nature. Mais si elles servent à acquérir des actions avant la dissolution de la communauté, ces dernières sont des biens communs.

A contrario, si les actions sont acquises, par l'exercice du droit d'option, après la dissolution de la communauté, elles appartiennent personnellement à l'époux concerné.

Elles risquent alors d'échapper complètement à la communauté. L'on imagine aisément que l'époux détenteur d'options qui est sur le point de divorcer a tout intérêt à attendre le prononcé du divorce pour lever l'option !

Cette décision est critiquée par une partie de la doctrine, dite patrimonialiste, qui continue de défendre l'idée que le fait que le droit d'option soit attaché à la personne du salarié est insuffisant à caractériser un propre par nature et que par ailleurs le caractère incessible de ce droit ne signifie pas qu'il n'a pas de valeur. Pour cette doctrine, au contraire, il s'agit bien d'un droit patrimonial. Au surplus, il s'agirait simplement d'un mode particulier de rémunération de l'industrie qui, à ce titre, ne peut échapper à la communauté.

▪ Actions gratuites

L'attribution se déroule en plusieurs temps :

- Période d'acquisition (minimum 1 an) : les actions sont attribuées sous condition d'être toujours salarié (ou mandataire) dans l'entreprise, de réaliser des critères de performance, ou de niveau de cours de bourse atteint par exemple.
- Attribution effective

¹ Par exemple : CA Toulouse, 24 nov. 2015, n° 15/990 ; CA Dijon, 4 juin 2014, n°14/00118 ; CA Amiens, 11 oct. 2012, n° 11/O2796 ; CA Orléans, 22 janv. 2013, n° 11/O2657.

² Cass. 1^{re} civ., 9 juil. 2014, n° 13-15948.

- Période de conservation (facultative) : il est possible de prévoir une période de conservation, qui, cumulée avec la période d'acquisition, ne peut excéder 2 ans.

Contrairement aux stocks options, il n'y a pas une option dont la levée par le bénéficiaire se traduit par la propriété d'actions mais une rémunération conditionnelle par l'attribution d'actions gratuites.

Ainsi, l'attribution pendant le mariage à un salarié commun en biens d'actions gratuites constitue un mode de rémunération et ces actions sont communes¹.

b – Indemnités diverses

En régime de communauté, pour connaître la nature propre ou commune d'une indemnité versée pendant le mariage à l'un des époux, il convient de tenir compte de son fait générateur et de la cause de son versement.

Très souvent l'indemnité a vocation à réparer un préjudice économique lié à une perte de revenus. Dès lors, l'indemnité prend la même nature que le revenu auquel elle se substitue.

Dans ce régime matrimonial, seules seront exclues de la masse les sommes qui réparent un préjudice personnel.

- Indemnité de licenciement

La Cour de cassation affirme depuis longtemps le caractère commun de toute indemnité qui serait versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail². Cette solution se justifie par le fait que l'indemnisation résulte de l'activité professionnelle d'un époux mais surtout par sa vocation à réparer un préjudice essentiellement économique, à compenser une perte de revenus.

Cependant, il n'est pas rare que les indemnités de licenciement réparent à la fois un préjudice économique et un préjudice moral personnel. Dans un tel cas, la jurisprudence considère qu'à défaut de faire apparaître une ventilation dans la transaction, ces indemnités sont communes pour le tout³.

En présence d'une ventilation, la partie de l'indemnité allouée au titre d'un préjudice moral ou corporel sera qualifiée de propre.

Attention : le cas échéant, le juge a le pouvoir de restituer l'exacte qualification à des faits litigieux, notamment dans l'hypothèse où l'époux salarié et son employeur ont déclaré que l'indemnité visait à réparer un préjudice moral alors qu'il s'agissait en réalité d'un préjudice économique⁴.

De la même manière, les indemnités versées au titre d'une police d'assurance « perte d'emploi » souscrite pour garantir un prêt immobilier constituent un bien commun dans la mesure où leur objet est de compenser une perte de revenu liée à un licenciement⁵.

Suivant le même raisonnement, la jurisprudence qualifie de bien commun l'indemnité transactionnelle de rupture, cette dernière n'ayant pas été allouée au titre de dommages-intérêts en vue de réparer un préjudice moral personnel, mais en réparation de la perte d'emploi et des revenus que cette dernière générerait⁶.

¹ CA Paris, 10 févr. 2016, n° 15/00988.

² Cass. Civ. 1^{ère} 5 nov 1991, n°90-13.479 ; Cass. Civ. 1^{ère} 27 nov. 2001, n°99-16.380.

³ Cass. Civ. 1^{ère} 16 juillet 1997 n°95-16.977 ; Cass. Civ. 1^{ère} 29 juin 2011, n°10-23.373.

⁴ Cass. 1^{ère} civ., 3 janv. 2006, n° 04-13.734.

⁵ Cass. 1^{ère} civ., 3 févr. 2010, n°08-21.054.

⁶ Cass. Civ. 1^{ère} 26 sept. 2007 n°06-18.252.

- Indemnités compensatrices dans les hypothèses de maladie ou d'accident

Constituent également des substituts de rémunération du travail toutes les indemnités pouvant être versées pour compenser une perte de revenus consécutive à une maladie ou à un accident. Une indemnité versée à un salarié victime d'un accident du travail en réparation le préjudice professionnel, caractérisé par une incapacité à reprendre toute activité économique est destinée à compenser une perte de revenus » ; dès lors, elle entre dans la communauté « comme les salaires dont elle constituait un substitut.

La distinction entre les indemnités réparant un dommage corporel ou moral, propres par nature, et celles visant à compenser la perte d'un emploi, communes en tant que substituts de salaires, se trouve ainsi clairement affirmée. Une incertitude peut subsister en présence d'une indemnisation d'un dommage corporel qui compenserait à la fois le dommage corporel ou moral, mais aussi la perte d'activité. La présomption de communauté conduit à privilégier la communauté.

c – Revenus de biens communs et revenus de biens propres

Tous les revenus du couple sont communs dès le mariage, et les revenus provenant des biens propres des époux n'échappent pas à cette règle.

Conformément aux dispositions de l'article 1403 du Code civil, la jurisprudence tient pour acquis que les revenus des biens propres tombent en communauté depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 mars 1992¹ qui a jugé que « *la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens* ». Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 20 février 2007² rappelant le principe selon lequel « *les fruits et revenus de propres ont le caractère de biens communs* ».

En contrepartie du caractère commun des revenus générés par les biens propres, c'est à la communauté, qui profite de ces revenus, d'assumer les charges de jouissance.

Ainsi, les biens propres qui sont frugifères enrichissent la communauté de leurs fruits : loyers des biens immobiliers propres et autres intérêts ou dividendes perçus.

Titres de société propres et notion de revenus

Les bénéfices sociaux ne sont pas des fruits par essence. Ils ne le deviennent au regard du régime matrimonial des époux que lorsqu'une décision de distribution a été prise. Les dividendes distribués sont alors communs. Si les bénéfices sociaux sont affectés à la constitution de réserves, ils ne sont à aucun moment sortis du patrimoine de la société. Ce n'est pas le résultat comptable qui est le fruit, mais le bénéfice distribué.

Ainsi, les bénéfices d'une société ne deviennent fruits ou revenus de biens propres, susceptibles de constituer des acquêts que dès lors qu'ils sont distribués.

¹ Defrénois 1992, p.1121 ; RTD civ 1992, p.401 ; JCP 93, II, 22003 et 22041

² Civ. 1^{ère}, 20 fév. 2007, D. 2007, Jur. 1578 ; AJ Fam. 2007, 230

Illustration

De plus en plus de futurs époux ont commencé à se constituer un patrimoine personnel avant de se marier. Il n'est pas rare que l'un d'eux, ou les deux, ait acquis un bien immobilier locatif.

Pour ces époux, le mariage en communauté change l'économie de cet investissement : généralement, l'acquisition est financée par un prêt dont les échéances sont acquittées au moyen des loyers encaissés. A compter du mariage, le bien immobilier et la dette sont des propres (voir *infra*) mais les loyers ont la nature de bien commun. Le paiement des échéances sera alors générateur d'une récompense !

A défaut de modification du régime matrimonial, la solution réside dans la mise en société du bien et de la dette. Cela permet à l'époux d'être propriétaire en propre des parts sociales ou actions et de laisser dans la société les revenus affectés au remboursement. Les loyers sont alors encaissés par la société propriétaire qui, par ailleurs, rembourse le prêt. Ce ne sera qu'en présence d'un résultat comptable positif et si l'assemblée des associés en décide la distribution, qu'alors ces dividendes profiteront à la communauté.

d – Acquisition pendant le mariage

Tout bien acquis à titre onéreux pendant le mariage est commun, qu'il soit acquis par l'un des époux seulement ou par les deux conjointement.

Les deux éléments déterminants sont la date et le mode d'acquisition.

▪ Date d'acquisition

Pour être commun, le bien doit être acquis pendant le mariage. S'il est acquis avant, il est propre ; s'il est acquis après, il est également propre.

La question n'est pas anodine lorsque le processus d'acquisition n'est pas instantané mais s'échelonne dans le temps. Quid lorsque cde processus est initié avant mariage et achevé durant le mariage ? ou, au contraire, lorsqu'il est initié pendant mariage et achevé post-divorce ?

La doctrine majoritaire fait prévaloir la date du transfert de propriété et conclue que le bien est commun dès lors que la propriété est transférée durant le mariage¹.

Avant-contrat et condition suspensive

Une promesse synallagmatique de vente, ou compromis de vente entre le vendeur et l'acquéreur, est généralement signée sous condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire par l'acquéreur. Une fois le prêt obtenu, les parties réitèrent leur engagement dans l'acte de vente. Au plan juridique, la réalisation d'une condition suspensive produit un effet rétroactif. C'est la raison pour laquelle, même si l'obtention du prêt (et la signature de l'acte de vente) est postérieure au mariage, le bien pourrait échapper à la communauté si l'avant contrat avait été signé avant le mariage par l'un des époux.

Contrats avec option : location-vente, location-accession ou crédit-bail

¹ Gabriel Marty & Pierre Raynaud, *Droit civil – Les régimes matrimoniaux* – Sirey 1978, n°179 – Jacques Flour et Gérard Champenois, *Les régimes matrimoniaux* – Armand Colin 2001, 2^{ème} éd., n°277 – Raymond Le Guidec, *Communauté légale – Biens propres* – J.-Cl. Civil code, art. 1404 à 1408 (éd. 2013), n° 38.

Dans un arrêt de 1992¹, la Cour de cassation a considéré qu'un appartement acquis par deux époux au moyen d'un contrat de location-attribution, stipulant que le transfert de propriété interviendrait sans effet rétroactif n'a jamais été commun si le transfert de propriété est opéré postérieurement au prononcé du divorce.

Dans un arrêt rendu en 1997², dans une affaire de crédit-bail portant sur un bateau, souscrit pendant le mariage mais pour lequel l'option avait été levée par l'époux postérieurement à l'assignation en divorce³, la Cour de cassation a considéré que le bateau appartenait exclusivement à l'ex-époux, à charge pour lui d'indemniser la communauté qui avait assumé les redevances.

Fonds de commerce

En la matière c'est la date de création du bien qu'il convient de prendre en compte.

S'agissant d'un fonds de commerce, la clientèle étant l'élément primordial, doctrine et jurisprudence retiennent comme date de création du fonds celle de l'ouverture au public.

Il en a par exemple été jugé ainsi en matière de pharmacie. Alors que le processus peut être long et complexe, qu'à la date de l'obtention de l'autorisation préfectorale de création de l'officine de pharmacie, la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, n'existait que de manière potentielle, et que seule l'ouverture au public entraînait la création d'une clientèle réelle et certaine⁴.

▪ Mode d'acquisition

Dès lors qu'il est acquis à titre onéreux pendant le mariage, le bien commun sauf les hypothèses réservées par la loi dans lesquelles ce bien peut être propre (voir infra).

La notion d'acquisition est à prendre au sens large : sont notamment concernés, outre les biens corporels, incorporels, mobiliers ou immobiliers, toutes les créances ou placements financiers.

La notion d'acquêts comprend non seulement les biens *acquis* mais également les biens *fabriqués* (maison édifée par un époux), les biens *créés* (fonds de commerce) ou encore les biens *gagnés* à l'occasion de jeux ou compétitions.

Et les contrats d'assurance-vie ?

La nature d'un contrat d'assurance-vie alimenté de deniers communs et non dénoué, a suscité par le passé de grandes discussions doctrinales.

Pour les uns, la valeur de rachat devait être qualifiée de propre par nature en raison des prérogatives attachées exclusivement à la personne du souscripteur (et notamment le droit de désigner le bénéficiaire) conformément à l'article 1404 du Code civil.

Pour les autres, ce contrat d'assurance-vie était un placement presque comme un autre, des économies appartenant à la communauté suivant l'article 1401 du Code civil.



¹ Cass. civ. 1^{ère}, 17 mars 1992, n°90-14.279 – Bull. civ. I, n°83 ; JCPN 1992, II, p. 377, obs. P. Simler ; RTD Civ. 1992, pp. 635 & 810, obs. F. Lucet & B. Vareille.

² Cass. 1^{re} civ., 1^{er} juill. 1997, n°95-17.058.

³ L'assignation en divorce marquait ici la fin de la communauté, l'assignation étant alors retenue comme date des effets du divorce entre les époux.

⁴ Civ 1^{re}, 4 déc. 2013, n°12-28.076.

En 1992, la jurisprudence *Praslicka*¹ tranche : seule la *valeur* de ce contrat fait partie de la masse commune. Il faudra en comprendre que l'époux souscripteur a l'exclusivité des *pouvoirs* mais l'*avoir* est commun. Il s'agissait d'un divorce et l'enjeu était la valeur de la communauté à se partager...

e – Présomption de communauté

L'article 1402 énonce que tout bien du couple « est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. ». Il s'agit de la présomption de communauté, présomption simple².

Cette présomption est d'une grande importance en pratique.

Présomption de communauté et fongibilité

Lorsqu'ont été déposés sur un même compte tant des deniers propres que des deniers communs, la question se pose de savoir si les deniers propres demeurent identifiables et conservent leur nature propre – ce qui permettrait à l'époux concerné d'en exercer la reprise – ou si la confusion des fonds propres et des fonds communs confère un caractère commun au solde du compte, par l'effet combiné de la présomption de communauté et de la fongibilité de la monnaie, imposant le recours au mécanisme des récompenses ?

Pour une majorité d'auteurs³, la fongibilité des deniers entrés en compte exclurait toute distinction, au sein du compte, entre les deniers propres et les deniers communs. En vertu de la présomption de communauté, il y aurait alors lieu de qualifier l'ensemble des deniers figurant sur le compte de deniers communs⁴. Il conviendrait alors de recourir au mécanisme des récompenses pour rétablir l'équilibre entre la masse propre et la masse commune.

Cette analyse est également retenue dans un Bulletin d'information de la Cour de cassation⁵. Le même raisonnement pourrait s'appliquer au compte rémunéré sur lequel a simplement été versée une somme propre. Le versement des intérêts (communs) sur ce même compte pourrait conduire à qualifier le solde commun, à charge de récompense au profit de l'époux qui détenait la somme propre initialement versée. Une solution pourrait être trouvée dans l'ouverture d'un autre compte destiné à recevoir les intérêts.

Acquisition financée par un prêt

Le bien acquis à titre onéreux pendant le mariage par l'un des époux constitue un acquêt et ce quand bien même l'époux financerait l'opération par un prêt souscrit par lui seul.

¹ Cass. 1^{re} civ., 31 mars 1992, n° 90-16343.

² La présomption simple peut être renversée en apportant une ou des preuves contraires. On la nomme simple « simple » par opposition à la présomption dite « irréfragable », c'est-à-dire qui ne peut pas être combattue.

³ *Contra* : Pour certains auteurs, les deniers propres déposés sur un compte sur lequel figurent tant des fonds propres que des fonds communs conservent leur qualification de biens propres. La seule difficulté est celle de la preuve de la nature propre des fonds figurant sur le compte. Mais dès lors que la traçabilité des fonds peut être assurée – notamment si le compte a fait l'objet de mouvements limités – il pourrait être apporté la preuve du caractère propre des fonds, ce qui permettrait d'en effectuer la reprise (E. Naudin, *Encaissement de deniers propres et droit à récompense*, Dr. de la famille n° 3, mars 2006 étude 16 ; A. Colomer, *Régimes matrimoniaux*, éd. Litec, n° 955).

⁴ B. Vareille, RTD Civ. 2006 p. 814, comm. sous Civ. 1^{ère}, 8 novembre 2005 ; C. Grare-Didier et M. Pichard, *L'argent en compte et la famille*, Mélanges G. Champenois, p.380 ; G. Champenois, Defr. 2012, p.1195 ; Le Guidec et Zalewski-Sicard, *Divorce par consentement mutuel : liquidation partage du régime matrimonial et règlement de prestation compensatoire (cas pratique)*, Defr. 2014, art. 1150.

⁵ BICC n°721 du 1^{er} mai 2010.

Les deniers prêtés par l'établissement bancaire, ou tout autre prêteur, ont la nature de biens communs.

Le recours au prêt ne permet pas de faire échapper le bien à la communauté.

Gains de jeux de hasard

La nature du gain dépend de la nature des fonds utilisés pour acquérir le billet gagnant. Dès lors que le titre, le billet, a été acquis au moyen de deniers communs, le gain fortuit est lui aussi commun. La doctrine ne paraît pas exiger la formalité du remploi mais simplement la preuve du caractère propre des deniers employés. Cependant, en pratique, la présomption de communauté est un obstacle important à la qualification de propre des deniers employés, le gain étant alors commun¹.



Réflexe pratique

En raison de la présomption de communauté, il faut toujours partir du postulat que l'ensemble des biens du couple sont communs. C'est seulement lorsque les époux sont en mesure de prouver la nature propre d'un bien que ce dernier sera exclu de la masse commune.

Cela vaut notamment pour tous les avoirs financiers des époux. Il règne en la matière une grande confusion dans l'esprit des néophytes selon laquelle l'enveloppe ouverte au nom d'un seul abrite une propriété exclusive. Or, si chacun a pouvoir pour ouvrir un compte de dépôt à son seul nom et y déposer des fonds sans justifier de leur propriété², cela ne signifie pas que ces fonds lui appartiennent en propre.

Cela vaut également pour les véhicules, qui sont présumés communs quand bien même la carte grise serait libellée au nom d'un seul des époux³.

2 – Biens propres

Parmi les biens propres, il convient de distinguer :

- ✓ les biens propres **à raison de leur origine** tels que les biens présents (art. 1405 al. 1 C. civ.), les biens acquis par donation ou succession (sauf volonté contraire du disposant, art. 1405 al. 2 C. civ.), les biens acquis à titre d'accessoire d'un propre (art. 1406 al. 1 C. civ.), l'acquisition de droits indivis (art. 1408 C. civ.),
- ✓ les biens propres **par nature** (art. 1404 C. civ.),
- ✓ les biens propres **par subrogation** réelle automatique (art. 1406 et 1407 C. civ.) ou par subrogation conventionnelle, soit emploi ou remploi (art. 1434 C. civ.).

a – Biens propres par origine

- Biens présents (C. civ., art. 1405 al. 1er)

Les biens présents sont ceux qui appartiennent à chacun des époux avant le mariage.

¹ TGI Créteil 19 janv. 1988 : JCP G II 21385 ; D1989 jurispr. P.37 ; CA Orléans, 12 mai 2009 JurisData 2009-005100 ; CA Toulouse 31 janv. 2012 JurisData 2012-013664 ; CA Paris 13 sept. 2012 JurisData 2012-013664 ; CA Versailles 13 Novembre 2014 JurisData : 2014-027930 ; CA Dijon, 8 déc. 2016, n° 16/00532)

² Au plan du régime matrimonial, même si, par ailleurs, il peut exister d'autres obligations déclaratives concernant l'origine des fonds ([TRACFIN](#)).

³ Rappelons que la carte grise est un document nécessaire mais pas suffisant à prouver la propriété du bien : Cass. 1^{re} civ., 30 oct. 2008, n° 07-19.633.

Comme nous l'avons indiqué¹, il existe des difficultés lorsque le processus d'acquisition (ou de création) s'échelonne dans le temps, et chevauche la période du mariage ou de la fin de l'union (notamment le divorce).

- Biens acquis par donation ou succession (C. civ., art. 1405 al. 1er)

Les biens acquis pendant le mariage par succession ou libéralité sont des biens propres. En revanche, les biens acquis à titre gratuit autrement que par succession ou libéralité ont le caractère de biens communs. Ce peut être le cas d'une acquisition par prescription acquisitive.

Sont également communs les biens reçus par donation consentie aux deux époux conjointement ou encore le bien donné ou légué à l'un des époux avec stipulation que le bien entrera dans la communauté du donataire.

Rappelons en effet qu'il est licite pour le donateur de prévoir une clause d'entrée en communauté du bien donné C. civ., art. 1405 al. 2).

- Biens propres par dépendance à un autre bien propre

Bien propre par accession

Suivant le droit commun de la propriété et l'article 552 du Code civil qui prévoit que « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous », toute construction édifée sur un terrain propre appartient en propre au même époux (à charge de récompense au profit de la communauté le cas échéant).

L'inextricable question de la construction édifée à cheval sur un terrain propre et un terrain commun

Bien que relativement fréquente en pratique, une telle situation n'est pas réglée par les textes et *il n'est pas du tout évident de trouver une solution satisfaisante dans la mise en œuvre des principes généraux et des règles ordinaires du régime de communauté*².



L'application stricte du principe d'accession devrait conduire à retenir une qualification mixte de la construction édifée à la fois sur un terrain propre et un terrain commun. Cette solution, soutenue par certains³, est inextricable en pratique. Comment admettre que la maison soit divisée verticalement en suivant les contours de la parcelle propre ? Dans la mesure où la construction forme un tout indivisible, il conviendrait de soumettre l'ensemble à un statut juridique unique.

Pour parvenir à un tel résultat en pratique, les juges s'appuient parfois sur la règle de « *majors pars trahit ad se minorem* » (faisant prévaloir la partie majoritaire sur le tout) et parfois sur celle de l'accessoire de propre⁴.

Bien propre par accroissement (C. civ., art. 1406 al. 1er)

Suivant l'article 1406, alinéa 1^{er} du Code civil, sont propres « les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres ».

¹ Concernant la date d'acquisition des acquêts, page 30.

² G. Goubeaux « *La construction édifée pour partie sur un terrain propre et pour partie sur un terrain commun* », Defrénois 1993 art. 35633 p. 1233

³ Patarin et Morin T.I n° 135 note 1

⁴ Pour une illustration récente voir Cass. 1^{re} civ., 11 juil. 2019, n°18-20.235.

Forment ainsi des propres les parts nouvelles attribuées gratuitement en cas d'augmentation de capital par incorporation des réserves, lorsque les parts anciennes détenues par l'époux étaient elles-mêmes propres¹.

Les parts nouvelles acquises grâce aux droits préférentiels de souscription attachés aux parts propres, forment également des biens propres.

Le raisonnement est que dans ces hypothèses, les valeurs nouvelles ou les accroissements sont générés par les parts préexistantes.

Attention : arrêt Baylet et communauté

Un important arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 novembre 1998 a jugé qu'un portefeuille de titres est une universalité². Bien que cet arrêt ait été rendu dans le cas où il s'agissait de déterminer les pouvoirs de l'usufruitier du portefeuille-titres, sa portée dépasse ce seul problème de pouvoir. Dès lors qu'il s'agit d'une universalité, la composition du portefeuille se modifie selon le mécanisme de la subrogation réelle : les différents titres ne sont pas des biens indépendants mais font partie d'une unité plus vaste à l'intérieur de laquelle joue la subrogation réelle.

Avant cela, les règles du régime matrimoniales conduisaient à qualifier de commune toute valeur mobilière acquise pendant le mariage sans déclaration de remploi (inconcevable en pratique).

Depuis, la doctrine considère que la notion d'universalité du portefeuille doit s'appliquer en matière de régimes matrimoniaux. Il en résulte que si le portefeuille de valeurs mobilières est propre, les arbitrages réalisés à l'intérieur du portefeuille sont sans conséquence sur la nature propre ou commune des valeurs mobilières : le portefeuille, dans son universalité, demeure propre.

La solution reste pourtant imparfaite en ce que la communauté aura droit à récompense pour les revenus produits par les valeurs mobilières et réinvestis dans le portefeuille³.

Bien propre accessoire (C. civ., art. 1406 al. 1er)

La notion d'accessoire se caractérise par la réunion de deux éléments :

- Un élément subjectif : l'acquisition d'un bien dans l'intention de l'affecter au service d'un bien propre principal. Cette intention doit exister dès l'acquisition. Ce qui implique une chronologie dans les acquisitions.
- Un élément objectif : un lien de dépendance économique.

Quelques exemples de biens qualifiés par la jurisprudence de propres par accessoires :

- Le corps de ferme acquis pour les besoins d'une exploitation agricole propre ;
- Le matériel et le cheptel dans les mêmes circonstances ;
- Les marchandises acquises pour l'exploitation d'un fonds de commerce propre ;

¹ J. Flour, G. Champenois, *Les régimes matrimoniaux*, 2^e éd°, A. Colin, n° 282

² Cass. 1^{re} civ., 12 novembre 1998, n° [96-18.041](#).

³ En ce sens, JCP 1999, G, II, n° 10027 p. 336, note PIEDELIEVRE : « Pour autant, toutes les difficultés ne sont pas résolues puisque les revenus des valeurs mobilières sont des biens communs. S'ils sont réinvestis dans le portefeuille, la communauté aura droit à une récompense puisque le patrimoine propre a profité d'une somme commune ».

- Les meubles et équipements acquis pour garnir le local dans lequel l'époux exerce la profession d'avocat avec une clientèle propre ;
- La voiture acquise dans le cadre de son activité par l'agent d'assurance dont la clientèle est propre ;
- Le fonds de commerce incorporé à un fonds de commerce propre (sans activité nouvelle ou changement d'activité).

Cette catégorie est à rapprocher de celle prévue à l'article 1404 du Code civil, disposant que sont propres les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, sauf s'ils sont accessoires à un fonds de commerce ou une exploitation communs.



Attention

Ni la contiguïté ni la simple opportunité de réunir deux biens ne constituent des éléments suffisants à caractériser une dépendance économique. Sauf circonstances très particulières répondant aux deux critères énoncés ci-avant, l'acquisition d'un terrain contigu à un terrain propre forme un acquêt de communauté¹.

- Biens acquis par licitation ou partage (art. 1408 C. civ.)

Suivant l'article 1408 du Code civil, lorsqu'un époux acquiert pendant le mariage une portion de bien dont il était déjà propriétaire en propre pour une quote-part indivise, il ne s'agit pas d'un acquêt mais d'un bien propre. Le cas échéant, une récompense sera due par cet époux à la communauté à raison du financement.

Ce texte vise notamment des hypothèses dans lesquelles un époux, propriétaire d'une quote-part indivise d'un bien lui appartenant en propre pour l'avoir reçue par succession, procède avec ses coindivisaires à un partage à l'issue duquel, contre versement d'une soule, il devient seul propriétaire du bien. Dans cette hypothèse, et ce quelle que soit la proportion de financement assurée par la communauté, le bien sera propre à l'époux concerné. La communauté aura alors simplement droit à une récompense.

Les dispositions de ce texte sont impératives et s'imposent aux époux qui ne peuvent pas l'écarter. C'est ce qui a pu être jugé notamment dans une affaire où les époux s'étaient portés ensemble co-acquéreurs de la quote-part d'un bien dont l'un d'eux était déjà propriétaire indivis en propre².

b – Biens propres par nature

Suivant l'article 1404 du Code civil, sont des biens propres par nature :

- ✓ les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux,
- ✓ les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral,
- ✓ les créances et pensions incessibles,
- ✓ tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
- ✓ les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, sauf s'ils sont l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. Le cas échéant, une récompense peut être due par l'époux à la communauté.

¹ Pour une illustration récente : Cass. 1re civ. 11 juil.2019, n° 18-20.235.

² Cass. Civ. 1^{re}, 13 oct. 1993, n°91-21.132.

- Actions en réparation d'un dommage corporel ou moral

En fait, ce ne sont pas tant les actions en réparation que les dommages-intérêts auxquels elles peuvent donner lieu qui sont propres.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué¹, c'est la nature du préjudice indemnisé qui guide la qualification. Seule l'indemnité versée à raison d'un préjudice personnel à l'époux, moral ou physique, est qualifiée de propre.

En revanche toute indemnité perçue en raison d'un préjudice matériel ou économique a la nature de bien commun.

- Créances et pensions incessibles

Entrent dans cette catégorie les pensions de retraite, d'invalidité ou encore les pensions alimentaires.

Attention toutefois, il convient ici de distinguer le titre de pension, le droit à percevoir la pension, qui est propre, de l'arrérage, la somme perçue au titre de la pension, qui peut être commune. Pour savoir si cette pension est propre ou commune, il convient de savoir si elle se substitue à un revenu (nature commune) ou si elle est versée en réparation d'un préjudice corporel ou moral (nature propre). Par exemple, il a pu être jugé que la pension de guerre est destinée à réparer un préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique et a la nature de bien propre². En revanche, une *pension militaire de retraite* est bien un substitut de revenus qualifiée de commune³.

- Instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux

Sont propres, à charge de récompense au profit de la communauté qui les aurait financés le cas échéant, les instruments nécessaires à la profession d'un des époux, sous les deux conditions cumulatives suivantes :

- Ils doivent être affectés à l'exercice d'une profession séparée, ce qui suppose que les époux n'exercent pas ensemble leur profession ;
- Et ils ne sont pas l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Cette catégorie tend à se rapprocher de celle des propres par accessoire déjà étudiée⁴.

- Biens à caractère personnel et droits exclusivement attachés à la personne

Cette dernière catégorie est sans doute celle qui soulève le plus de questions en pratique. La jurisprudence sur la question est abondante et difficilement synthétisable. Il est important de noter qu'il est très souvent fait application de la distinction du titre et de la finance, laquelle consiste globalement à conserver le caractère de propre à la « titularité » du droit ou de la créance, tout en faisant tomber en communauté sa valeur. Nous renvoyons ici à nos développements sur les cas particuliers et sur la distinction du titre et de la finance (page 67).

L'on peut néanmoins citer l'exemple de la dotation d'installation à un jeune agriculteur qui a été qualifiée de propre par la jurisprudence, quand bien même l'exploitation agricole était commune⁵.

¹ Concernant les indemnités perçues pendant le mariage, voir page 28.

² Cass. civ. 1^{ère}, 8 juil. 2009, n°08-16.364.

³ Arrêt précité.

⁴ Concernant les biens propres accessoires, voir page 34.

⁵ Cass. 1^{re} civ., 15 avr. 2015, n°13-26.467.



Assurance-vie VS Contrat retraite

Alors que la jurisprudence a tranché en faveur du caractère commun de la valeur d'un contrat d'assurance-vie non dénoué¹, elle suit un raisonnement bien différent pour les contrats retraite. La Cour de cassation² s'est en effet prononcée en faveur du caractère propre par nature d'un contrat d'assurance retraite souscrit pendant la communauté.

Il est retenu que le bénéficiaire ne peut faire valoir ses droits qu'à la cessation de son activité professionnelle, ce qui permet de caractériser un propre par nature (droits exclusivement attachés à la personne). Lorsque ce contrat a été alimenté de deniers communs et qu'il n'est pas prévu de réversion au profit du conjoint, alors la communauté a droit à récompense.

C'est généralement dans l'hypothèse d'un divorce, intervenant avant la retraite de l'époux, que la question se pose. Il convient donc de préciser que c'est seulement si le droit à réversion au profit du conjoint est certain et définitif que l'époux ne sera pas débiteur d'une récompense envers la communauté. Dit autrement, la communauté devrait systématiquement avoir droit à récompense puisque d'une part, on ne peut assurer par avance au conjoint qu'il bénéficiera de la réversion³ et, d'autre part, il sera devenu ex-conjoint, ce qui, généralement, suffit à l'exclure du bénéfice de cette réversion...

Si la Cour de cassation n'a jamais eu à se prononcer sur l'évaluation de la récompense, elle devrait obéir à la règle de la dépense faite faute de valeur de rachat dans ces contrats (c'est-à-dire une récompense égale à la somme des versements réalisés, de manière directe par l'époux ou indirecte par l'employeur).

Quid du PER ?

Le PER étant comme ses prédécesseurs par principe un support d'épargne sans faculté de rachat, il conviendrait d'appliquer les mêmes règles : qualification de propre par nature, à charge de récompense au profit de la communauté, selon la dépense faite sous les réserves faites ci-avant. La nature rachetable du contrat dans certaines circonstances soulève cependant des questions inédites... affaire à suivre

c – Propres par subrogation

- Créances et indemnités remplaçant des biens propres (C. civ., art. 1406, al. 2)

Dans cette hypothèse, la subrogation est dite automatique car elle ne nécessite aucun formalisme.

Il s'agit notamment du prix de vente d'un bien propre, de l'indemnité d'assurance versée par suite de la destruction d'un bien propre ou encore de l'indemnité d'expropriation d'un bien propre.

¹ Voir paragraphe O- d – Acquisition pendant le mariage, page 25 et s.

² Cass. 1^{re} civ., 30 avril 2014 n° [12-21.484](#) ; Cass. 1^{re} civ., 1^{er} févr. 2017, n° [16-11.599](#) ; Cass. 1^{re} civ., 28 févr. 2018, n° [17-13.392](#).

³ Le choix d'un bénéficiaire de substitution ne se fait pas forcément à la souscription mais parfois lors de la sortie.

Encaissement d'une somme propre, fongibilité des deniers et présomption de communauté

Prenons pour exemple le prix de vente d'un bien propre.

Si la somme a été encaissée sur un compte *ad hoc*, une certaine traçabilité a pu être assurée. Dans la mesure où elle figure toujours sur ledit compte, cette somme est demeurée propre et identifiable. Dans ce cas, la preuve de la nature propre des deniers sera facile à apporter (acte de vente, relevés de compte, etc.)¹.

En effet, si la somme a été déposée sur un compte bancaire sur lequel il n'y a eu aucun mouvement, la reprise pourra en être faite par l'époux concerné à la fin du mariage, la preuve du caractère propre des deniers étant aisément apportée.



Mais si, hypothèse plus courante, cette somme a été mélangée à d'autres fonds et notamment à des fonds communs et qu'il y a eu divers mouvements, la question de l'identification des fonds soulève un problème de preuve.

La question est de savoir si une reprise peut être exercée alors qu'il a eu confusion de deniers.

La nature propre des deniers originaux n'est pas remise en cause ainsi que le formulent plusieurs auteurs².

¹ RTD civ. 2006, 814, obs. B. VAREILLE.

² F. TERRE et Ph. SIMLER, « Les régimes matrimoniaux », Dalloz 5^e éd., n° 653 ; MAZEAUD et DE JUGLARD, Tome 4^e, « Régimes matrimoniaux », Montchrestien, 5^e éd., n° 115 et 420 ; COLOMER, « Droit civil Les régimes matrimoniaux », LITEC, 2^e éd., n°955 ; Dr. Fam., n°3, avril 2006, Etude 16 par E. NAUDIN.

C'est tout d'abord **la fongibilité des deniers** qui pose problème.

Comment peut-on en effet déterminer que les fonds demeurant sur le compte sont les fonds propres alors que des fonds communs y ont été mêlés et que parfois même diverses dépenses ont été réglées au moyen de ces fonds ?

D'autre part, l'on se heurte à **la présomption de communauté** édictée par l'article 1402 du Code civil.

A défaut de preuve contraire, les sommes figurant sur le compte bancaire, qu'il soit ouvert au nom de l'un ou des deux époux conjointement, sont réputées faire partie de l'actif commun.

Cette fongibilité des deniers pourrait déjà empêcher l'identification et la reprise des deniers propres.

Le solde du compte pourrait également s'avérer inférieur à la somme propre encaissée.

En pratique, il est recommandé de faire prévaloir le caractère commun du solde de compte et de rechercher si une récompense est due à l'époux au titre de l'encaissement de la somme propre.

Suivant les principes énoncés infra¹, une récompense est due par la communauté chaque fois qu'elle a tiré profit des biens propres.

Sur ce dernier point, la jurisprudence a fait preuve de pragmatisme en dégagant des présomptions² :



- Si la somme propre a été encaissée sur un compte joint entre les époux, le solde de ce compte est un actif commun mais la communauté est présumée en avoir tiré profit, ce qui ouvre droit à récompense au profit de l'époux ;
- Si la somme propre a été encaissée sur un compte ouvert au seul nom de l'époux concerné, il est présumé l'avoir utilisée à des fins personnelles et le droit à récompense est exclu. Le solde de ce compte est alors propre à l'époux.

Il s'agit de présomptions simples, ce qui laisse la liberté aux époux de rapporter la preuve contraire.

L'on part ici du principe que si les fonds sont encaissés sur un compte joint, et compte tenu de l'esprit communautaire du régime, c'est qu'ils vont être utilisés au règlement des dépenses communes ou du moins dans l'intérêt commun des époux. Dans ce cas, c'est donc à l'autre époux qu'il appartient de démontrer que ces sommes, bien qu'encaissées sur un compte joint, n'ont pas profité à la communauté

pour exclure le droit à récompense. En d'autres termes ce dernier doit prouver que ces deniers ont été utilisés dans l'intérêt exclusif de son époux.

¹ Voir les développements sur les récompenses pages 48 et suivantes

² Cass. Civ. 1^{re}, 8 février 2005, n° 03-13456 et n° 03-15.384 ; Cass. Civ. 1^{re}, 28 juin 2005, n° 02-17.599 ; Cass. Civ. 1^{re}, 6 juillet 2005, n° 02-17.628 ; Cass. Civ. 1^{re}, 8 novembre 2005, n° 03-14.831 ; Cass. Civ. 1^{re}, 28 novembre 2006, n° 04-17.147 ; Cass. Civ. 1^{re}, 25 avril 2007, n° 05-19.129.

Et inversement lorsque les fonds ont été déposés sur un compte ouvert au seul nom de l'époux, c'est à lui qu'il incombe de prouver que ces sommes ont profité à la communauté pour faire valoir un droit à récompense¹.

- Bien acquis par échange (C. civ., art. 1407)

Le bien acquis en échange d'un bien propre est lui-même propre par subrogation réelle automatique, à la condition que, le cas échéant, la soulte acquittée par la communauté ne soit pas d'un montant supérieur à la valeur du propre échangé. Précision faite que les frais d'acquisition doivent être pris en compte pour apprécier cette *major pars*².

- Bien acquis par emploi ou remploi (C. civ., art. 1434 et s.)

Lorsque des deniers propres sont employés à une acquisition, la subrogation n'est pas automatique.

Le législateur prévoit que le bien acquis avec des deniers propres n'aura le caractère propre à son tour que si l'époux respecte un certain formalisme : la déclaration d'emploi ou de remploi.

Il s'agit en réalité d'une double déclaration :

- Sur l'origine des deniers employés, établissant leur caractère propre ;
- Sur la volonté de faire du nouveau bien un propre.

Cette double déclaration doit être faite au moment de l'acquisition du bien.

Attention, une simple déclaration d'origine des deniers est inefficace à faire du bien acquis un propre.

La loi n'exige pas que les sommes utilisées en emploi ou remploi soient d'un point de vue matériel identiquement celles-là mêmes reçues à titre de propres, soit en donation ou succession, soit par suite de la vente d'un bien propre ; **il suffit donc qu'elles représentent un montant équivalent.**



Place du conjoint dans le remploi

La double déclaration d'emploi/remploi est unilatérale. Elle doit émaner de l'époux concerné. L'intervention de son conjoint n'est pas une condition de validité du remploi. En pratique elle est toutefois courante, et ce, afin d'éviter qu'ultérieurement le conjoint ne remette en cause le caractère propre des deniers employés. Son intervention est donc généralement requise aux fins de reconnaître le caractère propre à son époux des deniers et la véracité de ses déclarations à ce sujet.

Enfin, si les deniers propres sont insuffisants à réaliser l'acquisition, ils peuvent être complétés par des fonds communs.

Dans ce cas, la règle de *major pars* s'applique : pour que le bien acquis soit propre, les deniers propres doivent constituer la part majoritaire du financement. L'appréciation de cette proportion prend en compte non seulement le prix mais également les frais d'acquisition.

¹ Et inversement lorsque les fonds ont été déposés sur un compte ouvert au seul nom de l'époux, c'est à lui qu'il incombe de prouver que ces sommes ont profité à la communauté pour faire valoir un droit à récompense. Cass. Civ 1^{re}, 6 juillet 2005, n° 02-17.628 ; Defrénois 2005, 38245, n°71, obs. CHAMPENOIS.

² Par assimilation aux règles du remploi : 1436 du Code civil.

Il n'est pas possible de faire un remploi partiel aboutissant à une propriété mixte : x % du bien est propre et le complément commun.

Remarque pratique

La déclaration d'emploi n'est donc pas obligatoire. L'époux qui investit des deniers propres dans une acquisition a le pouvoir de choisir la nature du bien :

- Propre s'il fait la double déclaration de remploi
- Commun à défaut de déclaration de remploi.



Dans ce dernier cas, le bien sera un actif de communauté mais cette dernière sera débitrice d'une récompense envers l'époux qui a financé l'acquisition en tout ou partie au moyen de deniers propres. Afin de préserver ses droits et de s'assurer la preuve du droit à récompense à la fin de l'union, il est fortement conseillé d'insérer dans l'acte d'acquisition non pas une double déclaration d'emploi mais une simple déclaration d'origine des deniers.

L'hypothèse se rencontre parfois pour le logement du couple. Les époux ont souvent la volonté d'être propriétaires ensemble de leur résidence principale. Dans ce cas, l'époux qui financerait avec des deniers propres pourrait s'abstenir de faire une double déclaration d'emploi mais déclarerait l'origine propre des deniers.

Remploi par anticipation (art. 1435 C. civ.)

La loi permet également à l'époux de faire un remploi par anticipation. Ce peut être le cas par exemple lorsqu'il veut céder un bien propre mais que la signature de l'acte et le versement du prix ne sont pas encore intervenus alors qu'il a déjà trouvé un nouveau bien à acquérir. Dans cette hypothèse, c'est la communauté qui va faire l'avance des fonds, soit au moyen de deniers communs économisés soit via un prêt relais. L'article 1435 du Code civil impose alors, pour que le remploi soit efficace, et que le bien acquis soit définitivement propre à

l'époux, que la communauté soit réglée dans les cinq ans de l'acquisition. Si le remboursement n'a pas lieu dans les cinq ans, le bien sera commun.

Il est donc usuel de faire un second acte prouvant le remboursement dans le délai de cinq ans. En matière de biens et droits immobiliers, cet acte est obligatoire pour les besoins de la publicité foncière.



L'époux a omis de faire une déclaration de remploi lors de son acquisition : *quid* ?

Comme nous l'avons indiqué, c'est au moment de l'acquisition que cette double déclaration doit être faite.

Le législateur permet toutefois ce que l'on nomme un remploi *a posteriori*.

En effet, l'article 1434 du Code civil permet à des époux ayant réalisé une acquisition sans rien spécifier au moment de l'acte, de se mettre d'accord, après coup, pour reconnaître l'existence d'un remploi de fonds propres.

Toutefois, un remploi *a posteriori* ne produit d'effet qu'entre époux et non à l'égard des tiers.

Dans les rapports avec les tiers, le remploi *a posteriori* doit en effet être considéré comme inefficace. Le bien objet de l'accord des époux reste, pour les créanciers de la communauté, un bien commun qui fait partie de leur gage et qu'ils peuvent saisir.

Mais pour être valable, le remploi *a posteriori* nécessite un accord des époux. L'intervention du conjoint est donc ici indispensable.

▪ L'apport en société

Attention, en matière d'apport de biens propres en société, il convient de distinguer l'apport en nature des autres apports.

Concernant les biens corporels (apport en nature), la subrogation a lieu automatiquement, de sorte que les parts ainsi souscrites seront nécessairement propres à l'époux¹. Évidemment, il est néanmoins fort utile que les statuts contiennent toutes précisions utiles indiquant et justifiant le caractère propre des biens apportés.

Concernant l'apport en numéraire, l'époux devra formaliser une (double) déclaration de remploi pour que les parts constituent des propres (art. 1434 C. civ.). A défaut, les parts seront communes à charge de récompense au profit de l'époux.

EXERCICE N° 6

Pendant le mariage, Monsieur et ses deux frères ont hérité de leur père un appartement locatif à Eze. Chacun est propriétaire pour un tiers.

Monsieur a racheté la part de ses frères en 2007, l'appartement était évalué 450.000 €. Le prix a été payé avec ses économies personnelles.

Madame décède cette année. L'appartement d'Eze vaut 600.000 euros.

¹ Sont propres les parts ou actions reçues en contrepartie de l'apport d'un fonds de commerce propre sans déclaration de d'emploi : Civ. 1^{re}, 27 mai 2010, n°[09-11.894](#).

Questions :

L'appartement d'Eze est-il propre ou commun ?
Existe-t-il une récompense ?

Réponses :

EXERCICE N°7

Les époux X envisagent de créer une société à laquelle ils apporteront :

- Le fonds de commerce de mercerie tenu par Madame, dont l'ouverture a eu lieu une semaine avant le mariage (50.000 €)
- Les locaux dans lesquels le fonds est exploité, que Monsieur a reçu par donation de ses parents (60.000 €)
- La somme de 30.000 € qui appartient en propre à Madame pour l'avoir reçue dans la succession d'une tante

Question :

Quelle est la nature des parts sociales acquises en contrepartie de ces apports ?

Réponse :

B – Le passif

Il convient de distinguer deux notions différentes : obligation au passif et contribution au passif.

Obligation au passif : ces règles régissent les rapports entre le couple d'une part et les créanciers d'autre part. L'enjeu est ici celui de l'étendue du droit de gage du créancier en cas de non-paiement : peut-il agir sur les biens communs ? Une fois le mariage dissout, sur quels biens peut-il agir ?

Contribution au passif : ces règles régissent les relations entre les deux époux. La question est ici celle de savoir, à la fin du mariage si le patrimoine qui a supporté la dette était celui auquel elle incombait. Cela emporte deux conséquences :

- Existe-t-il des récompenses ;
- Le cas échéant, à qui incombe le solde de la dette à la fin de l'union.

1 – La contribution à la dette

Durant le mariage, le couple est amené à payer un certain nombre de choses. Selon l'objet de la dette payée, l'on peut en identifier le véritable débiteur. Mais il est fréquent que la communauté ait acquitté la majorité des dettes. La question se pose alors à la fin de l'union, de savoir pour chaque dette si elle est « propre » ou « commune ».

La dette « *propre* » devait être acquittée par le patrimoine propre. A défaut, la communauté est *créancière* d'une récompense.

La dette « *commune* » devait être acquittée par le patrimoine commun. À défaut, la communauté est *débitrice* d'une récompense.

a – Principe

La nature commune des dettes au plan de la contribution doit être considérée comme le principe et leur caractère propre comme l'exception. Il s'agit en quelque sorte du pendant de la présomption de communauté de l'article 1402 du Code civil énoncée pour les actifs. La règle s'applique si la dette a été souscrite par un seul des conjoints ou, *a fortiori*, par les deux.

Les dettes qui incombent à la communauté (art. 1409 C. civ.) sont :

- Les dettes nées pendant le mariage (dont celles contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants) ;
- Les dettes d'aliments¹ dues par les époux.

Incombent également à la communauté ce que l'on nomme les charges de la jouissance des propres. Puisque la communauté jouit tant des biens communs que des biens propres², elle doit corrélativement en supporter les charges. La communauté qui assume le règlement des dépenses courantes ou d'entretien d'un bien propre n'a pas droit à récompense puisque, par ailleurs, les fruits et revenus de ces mêmes biens propres accroissent à la communauté. Ce principe vaut que le bien propre soit frugifère ou non.

Le principe posé par un important arrêt de 1992³ est simple mais soulève parfois des difficultés pratiques.

En pratique quelles sont les charges supportées par la communauté concernant un bien propre ?

La Cour de cassation a rejeté l'assimilation aux charges usufruitaire considérant que la communauté n'a pas l'usufruit mais la jouissance des propres.

Ce que l'on peut retenir des jurisprudences :

- Les dépenses d'entretien constituent des charges de la jouissance, incombant à la communauté. La difficulté pratique se trouve parfois dans la délimitation entre dépense d'entretien et dépense d'amélioration. La jurisprudence fait alors une appréciation au cas par cas.
- Les frais d'assurance relatifs au bien sont également des charges de la jouissance incombant à la communauté.
- Les intérêts d'emprunt sont des charges de la jouissance. Lorsque la communauté rembourse un emprunt pour une dette relative à un bien propre, seule la part en capital des échéances doit être retenue pour évaluer la récompense due à la communauté

¹ Pension alimentaire due à un descendant ou ascendant par exemple.

² Rappelons une fois encore que les revenus des biens propres entrent en communauté.

³ Cass. 1^{re} civ., 31 mars 1992, [90-17.212](#).

par l'époux. L'assurance décès-invalidité ou l'assurance chômage souscrites dans le cadre du prêt sont assimilés aux frais de l'emprunt.

Communauté et fiscalité : quid des impôts ?

○ Contribution à la dette

La dette d'impôt sur le revenu est commune, qu'il s'agisse des revenus du travail ou des revenus de biens propres comme de l'immobilier locatif ou des capitaux mobiliers.

La taxe d'habitation est considérée comme une charge de la jouissance et incombe ainsi à la communauté, quand bien même le bien serait propre à l'un des époux.

Concernant la taxe foncière, s'agissant d'un bien commun, il ne fait pas de difficulté que la charge repose sur la communauté. S'agissant d'un bien propre, le débat n'est pas tranché. Pour les uns, il s'agit d'un impôt qui fait partie des charges usufruitaires dans la mesure où il obère d'avantage les revenus du capital que le capital lui-même,

pour les autres, elle est directement liée à la propriété et incombe à ce titre au seul époux propriétaire¹.

La taxe professionnelle avait été jugée à la charge définitive de la communauté². Dans la même logique, les contributions qui lui ont succédé devraient recevoir la même qualification de dette commune (la Contribution Économique Territoriale (CET) composée de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).

Les droits de mutation à titre gratuit qui incombent à l'époux donataire ou héritier constituent des dettes personnelles au plan de la contribution puisqu'elles grèvent les biens reçus par libéralités (C. civ., art. 1410).

Les sommes dues en cas de redressement fiscal dont les intérêts de retard sont généralement dues par la communauté car l'on considère qu'elles ont la même nature que l'impôt lui-même. En revanche, lorsqu'un époux est fautif en cas de fraude fiscale, alors les pénalités dues à ce titre constituent une dette propre à l'époux concerné.

○ Obligation à la dette

¹ Dans un arrêt du 14 novembre 2007 (n° [05-18.570](#)), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui mettait la taxe foncière à la charge de la communauté sur le fondement de l'article 609 du Code civil. La décision permet avec certitude de retenir que les textes relatifs au démembrement de propriété ne sont pas applicables à ce cas de figure. Pour certains auteurs, il faudrait également comprendre que la taxe foncière n'est pas une charge de la jouissance pour les magistrats de la Cour de cassation.

² Cas. 1^{re} civ., 3déc. 2002, n° [00-16.877](#).

Le droit fiscal pose le principe d'une solidarité fiscale entre les époux (et partenaires de PACS) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et l'impôt sur la Fortune Immobilière¹.

En cas de séparation, les époux peuvent demander une imposition séparée². Ils ont d'ailleurs intérêt à le faire sans tarder s'ils ne veulent plus être solidaires dans le paiement de ces impôts. La solidarité prend fin pour les impôts nés à compter de cette demande. Par exemple, pour les impôts dont le fait générateur s'apprécie au 1^{er} janvier de l'année N, les époux ne seront plus solidaires si leur résidence séparée a pris effet en N-1. Pour l'impôt sur le revenu, ils seront solidairement tenus pour les revenus de l'année N-1 mais plus pour ceux de l'année N.

b – Exceptions

A l'inverse, les dettes qui incombent à l'un des époux (art. 1410 C. civ.) sont :

- Les dettes propres par nature ;
- Celles dont l'époux était tenu avant le mariage ;
- Celles qui grèvent une libéralité ou une succession ;
- Dettes délictuelles ou quasi-délictuelles (infractions pénales ou réparations pour délits ou quasi-délits civils) par exemple pour les sommes dues à la victime d'un accident de la route causé par un époux ;
- Les dettes souscrites au mépris des devoirs du mariage comme la dette souscrite pour entretenir une concubine ou la pension due à un enfant adultérin ;
- Les dettes souscrites dans l'intérêt personnel d'un époux comme pour les travaux de conservation ou d'amélioration d'un bien propre.



Attention

Ne sont pas concernées par cette exclusion les dettes contractuelles. Si la pénalité due par l'époux trouve sa source dans un contrat, elle devra être supportée à titre définitif non pas par l'époux débiteur mais par la communauté. Il en sera ainsi, par exemple, en cas d'application d'une **clause pénale** ou en cas de violation d'une **clause de non-concurrence**.

¹ En vertu du I de l'art. 1691 *bis* du CGI, les époux et les partenaires de PACS sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune et de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. L'art. 1723 *ter*-OO B prévoit également que les époux et partenaires de PACS sont solidaires pour le paiement de l'IFI.

² Art. 6, 4, b du CGI.

Bien distinguer la pension alimentaire de la prestation compensatoire

En matière de contribution au passif, on distingue la dette d'aliments, résultant de l'obligation alimentaire, de la prestation compensatoire, résultant du divorce. Nous avons déjà indiqué qu'il existe souvent une confusion entre ces deux dettes¹.

Les pensions alimentaires dues par un époux incombent à titre définitif à la communauté.

Tel est le cas des pensions alimentaires dues à un enfant d'un premier lit, après le remariage du débiteur².

De la même manière, il a été jugé que les sommes dues à un ex-conjoint en vertu d'une pension alimentaire allouée dans le cadre d'un divorce pour rupture pour la vie commune ou de convention expresse dans le cas d'un divorce sur requête conjointe ont un caractère alimentaire et incombent à titre définitif à la communauté³. Cette dernière hypothèse ne devrait plus se rencontrer en pratique puisque depuis le 1^{er} janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, dans tous les cas le divorce met fin au devoir de secours entre ex-époux. La pension alimentaire ne peut être due qu'à un conjoint en instance de divorce mais non encore divorcé. Il ne peut donc y avoir de nouveau conjoint commun en biens qui ait à supporter cette pension alimentaire.

En revanche, une prestation compensatoire à laquelle un époux a été condamné à verser à son ex-conjoint reste une dette purement personnelle à l'époux débiteur (car antérieure au mariage). Si certains arrérages ont été versés avec des deniers communs, une récompense est due à la communauté conformément à l'article 1410 du Code civil⁴.

c – Quid à la fin de l'union

La contribution au passif est une notion qui intéresse la relation patrimoniale au sein du couple.

Comme nous l'avons indiqué, il s'agit de se placer au moment de la dissolution de la communauté et d'examiner si des dettes ont été supportées par la communauté alors qu'elles incombaient à un seul époux.

Dans l'affirmative, des récompenses seront à comptabiliser.

Rappelons que la dissolution de la communauté a lieu lors du décès d'un époux, lors du divorce ou encore lors d'un changement de régime matrimonial.

Par ailleurs, si la dette n'a pas été intégralement réglée, il faudra, selon le cas, comptabiliser le solde restant dû au passif de la communauté ou au passif propre de l'époux concerné.

¹ Voir le paragraphe concernant la Contribution aux charges du mariage : Opage 14

² Cass. 1^{re} Civ., 8 nov. 2005, n°[03-14.831](#).

³ Cass. 1^{re} civ., 25 janv. 1984, Bull civ II, n°13.

⁴ Cass. 1^{re} civ., 3 nov. 1988, Bull civ II, n°299.



Les dettes professionnelles

Le passif professionnel d'un époux, lié au fonctionnement normal de son activité professionnelle, doit être considéré comme faisant partie du passif définitif de la communauté et ne donne pas lieu à récompense. Cette solution se justifie par le fait que les revenus de l'exploitant tombent en communauté par application de l'article 1401 du Code civil¹.

Il faut, en la matière, établir un parallèle entre la nature juridique des revenus professionnels et les charges occasionnées par cette activité. Les charges relatives à l'exercice de l'activité professionnelle de l'époux incombent définitivement à la communauté en application de l'article 1409 du Code civil.

Sur un plan général, le passif professionnel né au cours du mariage constitue un passif commun auquel les époux contribuent en principe par moitié.



Cas particulier : dettes professionnelles et article 1387-1 du Code civil

Le législateur a introduit une exception à ce principe lors de l'adoption de la loi Dutreil du 2 août 2005².

L'article 1387-1 du Code civil prévoit que, en cas de divorce, les dettes souscrites pendant le mariage par un époux dans le cadre de la gestion d'une entreprise peuvent être mises à la charge exclusive de celui qui est attributaire du patrimoine professionnel. Seul le TGI est compétent pour rendre une telle décision, sur requête du conjoint.

Très critiquée par la doctrine³, cette mesure ne semble concerner que la contribution au passif et non l'obligation. Cela signifie que, en pareilles circonstances, le TGI a le pouvoir de décider que la dette, commune au plan de la contribution, ne sera finalement supportée que par l'époux concerné⁴.

En revanche, il ne paraît pas possible de l'étendre aux règles de l'obligation. Si l'époux à la charge exclusive duquel la dette a été mise par le TGI s'avérait insolvable, le créancier pourrait toutefois agir sur les biens qui étaient communs.

2 – L'obligation à la dette

Il s'agit ici de savoir de quoi est constitué le gage du créancier en cas de non-paiement spontané : biens propres et/ou biens communs.

Rappelons que ces règles régissent toute relation entre un créancier et son débiteur marié en communauté légale, nonobstant les garanties conventionnelles ou légales qui peuvent exister par ailleurs.

¹ J. FLOUR et G. CHAMPENOIS, *Les régimes matrimoniaux*, Armand Colin, Paris 1995, n° 464

² Loi n°2055-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

³ V. BREMOND, « *Le nouveau régime des dettes professionnelles conjugales en cas de divorce. À propos de l'article 1387-1 du Code civil* », JCP N 2005, n° 50, p. 1497 – R. CABRILLAC, « *Le nouvel article 1387-1 du Code civil* », RLDC 2006, supp. au n° 25, 2005, p. 35 – P. CROCQ, « *Les bons sentiments ne font pas les bons textes* », D. 2005, p. 2025. – P.-F. CUIF, « *Le nouvel article 1387-1 du Code civil, sens et devenir d'un texte contesté* », RLDC. 2005, n° 22, p. 23. – V. LARRIBAU-TERNEYRE, « *Le créancier se trouva fort dépourvu quand le divorce fut venu ou le nouvel article 1387-1 du Code civil* », Dr. fam. 2005, étude 21.

⁴ Cass. 1^{re} civ., 5 sept. 2018, n°17-23.120.

Un prêt est très souvent assorti de garanties dites conventionnelles (hypothèque, nantissement, etc). Dans ce cas, c'est le bien mis en garantie qui suffit généralement à désintéresser le créancier en cas de difficultés de paiement.

Mais l'existence d'une garantie conventionnelle est beaucoup plus rare dans les autres passifs. Le créancier sans garantie est dénommé créancier *chirographaire*. En cas de difficulté pour se faire payer, il devra en passer par les procédures civiles d'exécution et son espoir de retrouver les sommes prêtées est naturellement limité au patrimoine de son débiteur. Lorsque le débiteur est marié en communauté, le créancier pourra, selon le cas, avoir *in fine* pour « gage » soit seulement le patrimoine propre de son débiteur, soit le patrimoine propre et le patrimoine commun.

C'est ce que nous étudions ci-après.

a – Principe

Les dettes contractées pendant le mariage par l'un ou l'autre des époux engagent ses biens propres et les biens communs (C. civ., art. 1413 et s.).

Ce principe est très large. Cela vise toute dette née d'un contrat, quasi-contrat, délit, quasi-délit, etc. C'est ce qui résulte de la formule « *pour quelque cause que ce soit* ».

Sont notamment visées :

- Les dettes contractuelles ;
- Les dettes extracontractuelles ;
- Les dettes fiscales ;
- Les dettes délictuelles ;
- Les dettes résultant d'infractions pénales.

Au plan de l'obligation, peu importe le montant ou encore la finalité de la dette. Même engagée dans l'intérêt d'un seul des époux, la dette oblige le patrimoine commun dès lors qu'elle a été contractée pendant le mariage.

On tient compte du fait générateur de la dette et non son exigibilité. Elle doit être née pendant la communauté. Par exemple, les dettes de nature contractuelle doivent être nées au cours du mariage. Seule compte la date de naissance de la créance et non celle de son exigibilité (exemple de l'engagement de caution par un époux pris antérieurement au mariage mais engagé pendant la communauté : dette personnelle au plan de l'obligation). Concernant les dettes délictuelles, il faut que le fait dommageable ait été commis pendant le mariage, peu importe la date du jugement de condamnation de l'époux. Tel sera le cas, par exemple, d'un époux condamné à des dommages-intérêts après la dissolution de l'union en raison de faits commis pendant le mariage.

b – Exceptions

Fraude et mauvaise foi du créancier (C. civ., art. 1413)

C'est la situation dans laquelle, en toute connaissance de cause, un des époux a souscrit des dettes dans le but d'appauvrir la communauté, et de nuire ainsi aux intérêts de son conjoint. Le texte exige en outre qu'une telle fraude soit accompagnée de la mauvaise foi du créancier. Cela pourrait être le cas par exemple d'un faux acte de cautionnement (imitation de la signature de Madame) avec mauvaise foi du créancier.

Dettes « propres » (C. civ., art. 1410 et 1411)

Constituent des dettes « personnelles » au plan de l'obligation les dettes antérieures au mariage et celles grevant les successions et libéralités.

Concernant ces dettes, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.



Attention au nouveau statut d'entrepreneur individuel

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a créé un nouveau statut d'entrepreneur individuel qui a pour effet de déroger aux règles générales du droit de gage des créanciers et limiter ainsi le droit de gage des créanciers professionnels aux biens utiles à l'activité de l'entrepreneur individuel, excluant ainsi les biens non professionnels.

La nature propre ou commune des biens de l'entrepreneur au regard de son régime matrimonial n'est pas déterminante de ce point de vue.



Attention à la confusion du mobilier

Il existe un important risque de confusion du mobilier propre avec le mobilier commun des époux. D'autant plus que les conjoints pourraient utiliser la présomption de communauté de l'[article 1402 du Code civil](#) pour soustraire leurs apports mobiliers au gage de ces créanciers.

C'est la raison pour laquelle selon l'alinéa 2 de l'[article 1411 du Code civil](#), lorsqu'en raison de la confusion du mobilier et de l'application de la présomption de communauté, il est impossible d'identifier le mobilier propre, les créanciers voient leur droit de gage étendu aux biens communs.



A savoir – Protection des gains et salaires

Les salaires du conjoint du débiteur sont en partie protégés (C. civ., art. 1414).

Ils ne peuvent être saisis que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants conformément à l'article 220 du Code civil.

Attention toutefois car cette protection ne concerne pas les salaires économisés. Dit autrement, c'est le salaire courant qui est laissé au conjoint. Suivant le texte, en cas de voie d'exécution, doit être laissée au conjoint du débiteur une somme correspondant « *au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.* »¹

c – Cas particuliers

Le cautionnement et l'emprunt (C. civ., art. 1415)

Les opérations d'emprunt et de cautionnement font l'objet de dispositions particulières en ce qu'elles sont regardées par le législateur comme des dettes ou des engagements particulièrement graves.

Ainsi, lorsque l'emprunt ou le cautionnement n'est le fait que d'un seul des époux, ce dernier ne peut engager que ses biens propres et ses revenus. Le patrimoine propre du conjoint et le patrimoine commun sont hors d'atteinte du créancier en cas de difficulté.

¹ CPC, art. [R 162-9](#).

Pour donner plus de crédit au couple, la loi prévoit que le conjoint de l'emprunteur peut *consentir* à l'opération afin que le droit de gage du créancier soit étendu aux biens communs¹. Ce consentement doit être exprès. Dans ce cas de figure, le conjoint ne se porte pas lui-même emprunteur. Son intervention n'a pour finalité que de permettre au créancier de se faire payer *in fine* sur les biens communs (en plus des biens propres de l'emprunteur) en cas de non paiement spontané.

Évidemment, reste l'hypothèse dans laquelle les époux sont co-emprunteurs. Dans ce cas c'est l'intégralité du patrimoine du couple qui constitue le droit de gage du créancier.

En synthèse :

- ✓ Si l'époux souscrit seul l'emprunt ou le cautionnement sans l'intervention de son conjoint : il n'engage que ses biens propres.
- ✓ Si un époux souscrit un emprunt ou un cautionnement avec *l'intervention* de son conjoint : sont engagés les biens propres de l'emprunteur et les biens communs
- ✓ Si les deux époux se portent *co-emprunteurs* : tous les biens du couple sont engagés.

Solidarité légale pour les dettes ménagères (C. civ., art. 220)

Suivant l'article 220 du Code civil déjà étudié dans le régime primaire, les dettes souscrites par l'un des époux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants les oblige solidairement.

Si la dette entre dans le champ de la solidarité légale mise en place à l'article 220 du Code civil, l'ensemble des biens du couple sera engagé, c'est-à-dire les propres de l'époux débiteur, ses revenus, les acquêts de communauté, mais également les revenus du conjoint ainsi que ses biens propres.

La règle vaut que la dette ait été souscrite par l'un ou l'autre des époux ou par les deux conjointement. Pour ces dettes d'essence familiale, le législateur a donc choisi d'accorder au créancier un gage maximum afin de garantir le crédit du ménage.

Exemples de dettes qui entrent dans le champ de l'article 220 :

- soins dentaires,
- dettes de loyers du logement familial,
- dettes de salaire d'une employée de maison.
- dettes de cotisation de retraite,
- factures de frais médicaux d'un enfant.

La jurisprudence oppose les dettes d'entretien aux opérations d'investissement qui sont exclues du champ de la solidarité (acquisition d'une résidence secondaire).

Enfin, en dépit de la lettre du texte, qui semblait réserver son application aux engagements contractuels, la jurisprudence a accepté d'étendre la solidarité aux dettes extracontractuelles dès lors qu'elles ont un objet ménager (par exemple pour des cotisations sociales afférentes à un régime de prévoyance sociale).

d – Quid à la fin de l'union

A la fin du mariage, la communauté est dissoute et laisse place à l'indivision post-communautaire.

¹ A l'exception du salaire du conjoint non-emprunteur comme vu ci-avant, C. civ., art. 1414.

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens communs avant la dissolution conservent leur droit de poursuite sur les biens indivis (art. 815-17 al.1 er du Code civil).

Sur le plan de l'obligation à la dette, à la dissolution de la communauté, celui du chef duquel la dette est entrée en communauté peut être poursuivi pour la totalité de la dette existant au jour de la dissolution¹, tandis que son ex-conjoint ne pourra être poursuivi que pour la moitié de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint².

Enfin, si dans le partage les parties modifient les règles de la contribution, ceci sera sans incidence sur le droit de poursuite des créanciers (C. civ., art. 1490).

À savoir – Le conjoint peut demander le bénéfice d'émolument

Le « bénéfice d'émolument » (C.c vi., art. 1483) permet à un époux de n'être tenu des **dettes entrées en communauté du chef de son conjoint** qu'à concurrence de l'émolument qu'il recueille dans le partage.

Pour faire valoir le bénéfice d'émolument, il faut respecter les conditions suivantes :

Ne pas avoir commis de recel de communauté

Faire dresser un inventaire dans les 9 mois de la dissolution de la communauté

Avoir consacré l'intégralité de l'émolument reçu au paiement des créanciers communs³.

Précisions : la part d'actif recueilli ne tient pas compte des récompenses qui lui sont dues.

Le bénéfice d'émolument est sans effet sur le passif entré en communauté de son propre chef ou du chef des deux époux (spécialement pour les dettes solidaires). Il ne protège un époux que contre les créanciers de son conjoint.

Qu'est-ce que le recel de communauté ?

Le recel de communauté (C. civ., art. 1477) peut se définir comme toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment par un époux et ayant pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir⁴. La constatation de ce recel suppose une action en justice exercée par l'époux victime des agissements de son conjoint⁵.

Il convient de rapporter la preuve d'un élément matériel et d'un élément intentionnel.

¹ Article 1482 du Code civil

² Article 1483 du Code civil

³ L'époux qui demande le bénéfice d'émolument doit donc présenter un compte récapitulatif tout ce qu'il a reçu en qualité de copartageant et du passif déjà acquitté.

⁴ JCI Civil Code Art. 1477 fasc. *unique Communauté légale* (7/03/2012), n°1

⁵ A.Colomer *Les régimes matrimoniaux* Litec 10° éd. n°1028

La jurisprudence retient une interprétation extensive de l'élément matériel puisqu'elle n'exige pas qu'il s'agisse d'un acte d'appropriation mais admet tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté¹. Elle admet ainsi divers procédés indirects, notamment la cession de parts de société réalisée en fraude des droits de l'épouse². En ce qui concerne **l'élément intentionnel**, il convient de démontrer une intention frauduleuse. En d'autres termes, il convient de prouver que l'auteur du divertissement avait sciemment l'intention de fausser le résultat du partage à son avantage. Cette intention ne peut être déduite du seul élément matériel et est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Le recel peut être constitué lorsqu'un époux dissimule non pas le bien, mais sa valeur réelle³.

Sanction du recel : celui qui a recelé est privé de toute part dans les biens recelés.

En pratique

Cette sanction peut s'appliquer en cas de dissimulation d'un contrat d'assurance-vie.

Dans l'hypothèse d'un divorce, les époux doivent déclarer la valeur de rachat des contrats qu'ils auraient souscrits pendant mariage (sans déclaration de emploi) en raison de leur valeur commune).

Pour les mêmes raisons, dans l'hypothèse du décès d'un époux, son conjoint survivant doit déclarer les contrats d'assurance-vie non dénoués qu'il aurait souscrits pendant le mariage (sans déclaration de emploi).

EXERCICE N°8

Un époux commun en bien souscrit seul (sans le consentement de son conjoint) un emprunt pour réaliser des travaux sur un bien commun pour un montant de 40.000 euros.

Au jour de la liquidation le solde de l'emprunt est de 15.000 euros.

Question :

Quid du passif au plan de la contribution et de l'obligation ?

Réponse :

EXERCICE N°9

¹ Cass. Civ. 1^{ère} 26 janv. 1994 Def. 1994, 899

² Cass. Civ. 12 oct. 1964 Bull civ I n°437

³ Cass. 1^{re} civ., 1er juin 2011 : [JurisData n° 2011-010225](#) ; AJF 2011, p. 383, note P. Hilt ; RTD civ. 2011, p. 578, note B. Vareille ; [JCP N 2011, n° 24, act. 521](#) ; [JCP G 2011, chron. 1371](#), n° 12, obs. A. Tisserand-Martin ; Defrénois 2011, art. 40270, note C. Courtaigne-Deslandes.

Pendant le mariage, les époux souscrivent ensemble un emprunt de 65.000 € afin de réaliser une véranda dans une maison appartenant en propre à Monsieur. Au jour de la dissolution il reste dû un solde de 10.000 €.

Question :

Quid du passif au plan de la contribution et de l'obligation ?

Réponse :

EXERCICE N°10

Pendant le mariage, Monsieur a ouvert un café et contracté diverses dettes dans le cadre de cette activité professionnelle : URSSAF pour 3.500 €, loyers pour 5.000 € et fournisseurs pour 3.900 €.

Il rencontre quelques difficultés financières et ses créanciers s'impatientent.

Question :

Quid du passif au plan de la contribution et de l'obligation ?

Réponse :

Section 2 – Les pouvoirs sur les biens

A – Biens propres

1 – Principe : autonomie de gestion

Chaque époux exerce des pouvoirs totalement indépendants sur ses biens conformément à l'article 1428 du Code civil. Cette autonomie de gestion permet à chacun, sans en informer son conjoint, de passer tout acte sur ses biens propres. Il s'agit tant des actes conservatoires que des actes d'administration ou de disposition. Les pouvoirs de chacun sont exclusifs.

2 – Exception : le logement de la famille

Comme nous l'avons indiqué, le toit et la famille fait l'objet d'une protection spécifique. L'époux propriétaire en propre des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ne pourra pas passer n'importe quel acte de manière autonome.

Nous renvoyons donc à nos développements page 28.

B – Biens communs

1 – Principe : gestion concurrente

Concernant les biens communs, le principe est celui de la gestion concurrente (C. civ., art. 1421). Chaque époux est propriétaire de tous les biens communs pendant la vie du régime.

Ainsi chacun se voit conférés les mêmes pouvoirs de gestion sur les biens communs. Ils disposent de pouvoirs concurrents qui s'étendent à tous les actes : conservatoires, d'administration ou de disposition.

Par exemple, la vente d'une voiture commune peut valablement être passée par l'un seulement des époux. De la même manière, la conclusion d'un bail d'habitation, en qualité de bailleur, relève de la gestion concurrente.



L'emploi des fonds communs est soumis à la gestion concurrente

Alors que la vente de certains biens communs est soumise à une gestion conjointe (voir *infra*), relevons que l'emploi des deniers propres ne nécessite pas l'accord des époux. Qu'il s'agisse d'une dépense ou d'un investissement, et quel qu'en soit le montant, chacun a le pouvoir d'agir seul pour affecter les fonds communs. L'acquisition d'un bien immobilier peut valablement être faite aux moyens d'économies communes par un seul époux. Le bien acquis sera commun.



Cas particulier des parts sociales

L'époux qui utilise des fonds communs pour devenir associé d'une société de personnes doit en informer son conjoint en vertu de l'article 1832-2 du Code civil.

Cette obligation d'information pèse sur l'époux associé et doit être justifiée dans l'acte-même de constitution de société ou d'acquisition des parts. Elle est sanctionnée par la nullité de l'opération. Il ne s'agit pas d'un consentement mais bien d'une information, destinée à éclairer le conjoint de l'associé le cas échéant, sur l'impact de l'engagement sociétair. Rappelons en effet que dans certaines des sociétés concernées (sociétés civiles notamment), l'associé répond indéfiniment des dettes sociales, et peut donc être poursuivi sur son patrimoine personnel par les créanciers de la société. Dit autrement, il engage, en devenant associé, son patrimoine propre mais aussi l'essentiel du patrimoine commun des époux en cas de difficultés de la société. Les dispositions protectrices de la masse commune (C. civ., art. 1415, en matière d'emprunt et de cautionnement) ne sont pas applicables en la matière, nul besoin de recueillir le consentement du conjoint pour que le patrimoine commun se trouve engagé.

Ensuite, le conjoint a la possibilité de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. C'est la seconde finalité de l'obligation d'information. Au moment de l'entrée en société, trois voies lui sont ainsi possibles :

- Renoncer définitivement à prendre la qualité d'associé : dans ce cas, il renonce à pouvoir interférer de quelque manière que ce soit dans la société et il protège son patrimoine propre s'il s'agit d'une société à responsabilité indéfinie. Sa décision est irrévocable.
- Revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites/acquises : les statuts devront alors préciser pour quelles parts chacun des époux a la qualité d'associé. Et puisque *qui peut le plus peut le moins*, le conjoint peut revendiquer cette qualité sur moins de la moitié des parts concernées. L'agrément donné pour l'un vaut pour l'autre. Il n'est pas possible d'empêcher l'entrée en société du conjoint à ce stade. Le point est d'importance : chaque fois qu'un nouvel associé marié obtient l'agrément dans ces circonstances, il appartient aux Conseils d'avertir l'ensemble des

associés sur le fait que cet agrément vaut pour le couple le cas échéant. Si le conjoint devient associé, il pourra jouir des prérogatives d'associé et répondra des dettes sociales le cas échéant (l'ensemble du patrimoine des époux étant alors engagé en cas de difficultés sociales s'agissant d'une société à responsabilité indéfinie).

- Ne pas se prononcer : dans ce cas, la faculté de revendiquer la qualité d'associé lui reste ouverte, et ce, jusqu'à la fin du mariage. En revanche, les statuts peuvent prévoir que si le conjoint se manifeste postérieurement à l'entrée en société, il sera soumis à agrément. Attention toutefois car son époux ne peut pas participer au vote. C'est dire que l'époux déjà associé ne pourra ni s'opposer ni appuyer la volonté de son conjoint.

Enfin, force est de constater que les exceptions sont nombreuses. Un certain nombre d'actes sont regardés comme importants voire graves par le législateur. Le principe de gestion concurrente cède alors la place au principe de co-gestion ou gestion conjointe.

2 - Exception : gestion conjointe ou co-gestion

Sont soumis à la co-gestion, ou gestion conjointe, une série d'actes énumérés par la loi. Cela signifie que les époux n'ont le pouvoir de les passer qu'ensemble ; ces actes nécessitent l'accord des deux conjoints (C. civ., art. 1422, 1424 et 1425).

a - Donation d'un bien commun

La donation d'un bien commun est soumise à co-gestion (C. civ., art. 1422), qu'elle que soit sa forme, donation authentique ou don manuel.

Les présents d'usage n'étant pas considérés comme des donations, ils ne sont pas concernés.

Certains considèrent également qu'échappent à la cogestion les dons manuels de meubles corporels en application des dispositions de l'article 222 du code civil.



Donation d'un bien commun à l'enfant non commun

Lorsque le couple est marié en communauté et que l'un d'eux veut donner un bien de communauté à son enfant, non issu de son conjoint, le traitement civil et fiscal de la donation peut être dissuasif.

Rappelons en effet que chacun des époux est réputé donner la moitié du bien de communauté. Si la donation de moitié faite à l'enfant par son parent ne soulève pas de difficulté, il en va différemment pour la donation de moitié faite à l'enfant par son « beau parent »...

Mais un remède existe : la donation du bien commun par le parent, avec le consentement du conjoint.

La doctrine majoritaire admet qu'un époux puisse donner seul un bien commun avec l'accord de son conjoint en application de l'article 1422 du Code civil¹. Dans cette hypothèse, le conjoint intervient uniquement pour valider l'acte de cession mais n'a pas la qualité de codonateur.

Dans ce cas, l'époux donateur doit récompense à la communauté². En effet, lorsqu'un époux commun en biens déclare se porter seul donateur, c'est qu'il entend prendre personnellement la libéralité à sa charge, tout en l'ayant fait porter sur des biens communs.

Ayant emprunté à la communauté ce dont il gratifie le donataire, l'époux doit récompense à celle-ci³.

Dès lors que l'époux a donné l'entier bien elle sera redevable d'une récompense fixée à la valeur de l'entier bien. Pour évaluer la récompense, il y a lieu de prendre en compte la valeur du bien donné au jour de l'acte⁴.



Donation sur les gains et salaires

Conformément aux dispositions de l'article 223 du Code civil, du régime primaire, les gains et salaires sont laissés à la libre disposition de l'époux malgré leur caractère commun. Ils peuvent donc faire l'objet d'une donation par l'époux seul.

Notons toutefois qu'il s'agit des gains et salaires non encore économisés. Les deniers épargnés ne sont pas visés par l'article 223 précité.

b – Aliénations et constitutions de droits réels sur certains biens

Selon l'article 1424 du code civil, « *Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité.* »

¹ Rép Civ Dalloz V° *Communauté légale (2° gestion des biens)* n°263 s. ; F.Terré et Ph. Simler *op. cit.* n°486 ; G.Cornu, *op. cit.* n°66 ; J.Flour et G.Champenois, *op. cit.* n°564 ; A.Colomer *op. cit.* n°437

² Flour et Champenois, *op. et loc. cit.* ; Dalloz action *Droit patrimonial de la famille* sous la direction de M.Grimaldi, n° 312.161 ; A Colomer, précité, n° 948 ; B. Vareille, *Libéralité des biens de communauté*, RTDC 1995 p. 171.

³ Droit patrimonial de la famille, sous la direction de M. Grimaldi, n° 3061 ; J. FLOUR et G. CHAMPENOIS, *Les régimes matrimoniaux*, éd. Colin, n° 564 ; A. COLOMER, *Régimes matrimoniaux*, Ed. Litec, n° 437 ; Defrénois 1991, art. 35087 ; Defrénois 1994, art. 35916 *Encyc. Dalloz V° Communauté* n° 795 s. ; F.Terré et Ph.Simler, *Les régimes matrimoniaux*, précis Dalloz n° 484

⁴ F. Terré et P. Simler, *Les régimes matrimoniaux*, Précis Dalloz n° 678 ; A. Colomer, *régimes matrimoniaux*, éd. Litec, n° 988 ; J. Flour et G. Champenois, *Les régimes matrimoniaux*, Ed. Colin n° 589

Sont visées toutes les formes d'aliénations (vente, promesse de vente, échange, etc) ainsi que la constitution de droits réels (hypothèque, servitude, usufruit, etc).

Les biens concernés sont ceux qui sont considérés comme patrimoniallement importants par le législateur. On trouve tout d'abord les immeubles, les fonds de commerce et d'exploitation dépendant de la communauté.

Concernant l'aliénation ne portant pas sur le fonds lui-même mais sur un élément du fond, il convient de distinguer selon l'importance de cet élément. Si son aliénation emporte la disparition du fonds, alors l'article 1424 du code civil doit s'appliquer. On relèvera en ce sens également les dispositions de l'article L121-5 du Code de commerce pour les époux travaillant ensemble dans l'entreprise concernée.

Quant aux exploitations visées par le texte, il s'agit aussi bien des exploitations agricoles, artisanales ou libérales.

Font également partie du domaine de l'article 1424 du code civil les droits sociaux non négociables, c'est-à-dire les droits qui ne sont pas transmissibles selon les modes simplifiés du droit des sociétés, autrement dit les sociétés dites « de personnes » par opposition aux sociétés « de capitaux ».

Le texte vise également les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à la publicité : aéronefs, navires et bateaux. En revanche, puisque les automobiles relèvent d'une simple autorisation administrative, leur aliénation échappe à la cogestion.

Enfin, l'article 1424 du code civil soumet à cogestion la perception des capitaux provenant d'opérations soumises à cogestion.

c – Baux portant sur certains immeubles

L'article 1425 du code civil, prévoit, quant à lui, que « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté ». En revanche pour les autres baux, l'article 1425 du code civil renvoie aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier. Ils relèvent de la gestion concurrente.

d – Sanction du dépassement de pouvoir

Lorsqu'un époux outrepassé ses pouvoirs en passant seul un acte qui nécessitait l'intervention du conjoint au titre de la cogestion, l'acte est passible de la nullité.

Il s'agit d'une nullité relative, réservée à l'époux victime du dépassement de pouvoirs.

L'action en nullité doit être introduite dans un délai de 2 ans à compter de la connaissance de l'acte incriminé mais sans jamais pouvoir être intentée plus de 2 ans à dater de la dissolution du régime (article 1427 alinéa 2).

Enfin, l'époux peut également renoncer à invoquer cette nullité et purger l'acte de ce vice par une ratification.

EXERCICE N°11

Les époux MARTIN, mariés en séparation de biens pure et simple, souhaitent modifier leur régime matrimonial pour adopter une communauté réduite aux acquêts. À cette occasion, ils veulent prévoir que l'époux aura pouvoir pour disposer seul des biens communs.

Question :

Que pouvez-vous leur conseiller ?

Réponse :

C – La distinction du titre et de la finance

La distinction du titre et de la finance est née de la difficulté de concilier le *caractère personnel* à l'un des époux de certains biens avec leur appartenance au *patrimoine commun*¹. Il s'agit notamment des offices ministériels, dans lesquels le titre ne peut être détenu à défaut du diplôme ou des parts de sociétés dans lesquelles existe un fort *intuitu personae*.

Suivant cette distinction, la *qualité d'associé* (titre) est propre à l'époux concerné et seule la *valeur* des parts (finance) entre en communauté. Autrement dit, si les parts ont été souscrite ou acquises pendant le mariage, leur valeur est un actif commun. En revanche, le titre d'associé et les prérogatives y attachées demeurent propres à l'époux associé. L'autonomie de gestion de l'époux associé est assurée et les droits pécuniaires de la communauté sont préservés.

Il en va de même pour le contrat d'assurance-vie souscrit pendant le mariage : seul l'époux souscripteur en est le titulaire mais la valeur de rachat constitue un actif de communauté suivant la jurisprudence Praslicka².

Position de l'AUREP

Cette distinction du titre et de la finance devrait gagner encore du terrain.

D'une part, il faut bien reconnaître que le patrimoine tend à se caractériser par des droits contractuels. En dehors des biens corporels, meubles et immeubles, la dématérialisation du patrimoine se traduit par un *avoir contractuel*. On ne possède plus d'argent mais des créances contre un établissement financier (compte de dépôt, livret, assurance-vie) ou contre une société (action, obligation, compte courant d'associé).

D'autre part, les Français renoncent de plus en plus à devenir propriétaires de certains biens pour n'en être plus qu'usagers : leasing, crédit-baux ou autre location longue durée se multiplient. La traduction patrimoniale n'est plus la propriété d'un bien corporel mais la titularité d'un contrat.

Affaire à suivre...

¹ Pour un état de ces débats, v. E. Naudin, « *L'époux associé et le régime légal de la communauté réduite aux acquêts* », in Mélanges G. Champenois, Defrénois, 2012.

² Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16343.

Attention

La distinction du titre et de la finance s'efface au profit des règles de l'article 1424 du Code civil.

Il résulte en effet de la jurisprudence que pendant le mariage, la cession des parts sociales n'échappe pas aux règles du régime matrimonial¹. Conformément aux dispositions de l'article 1424 du Code civil, la cession des droits sociaux non négociables relève de la cogestion. Cela signifie que l'époux associé qui souhaite vendre les parts sociales pendant l'union doit le faire aux côtés de son conjoint et avec son accord.

¹ Cass. 1re civ., 9 nov. 2011, n° 10-12.123.

EXERCICE N°12

Amélie et Sébastien sont mariés en communauté. Pendant le mariage, Amélie a constitué une SCI avec des amies d'enfance pour acquérir un appartement à Royan. Elle avait réalisé un apport en numéraire sans précision sur l'origine des fonds. Sébastien est intervenu dans les statuts pour renoncer à la qualité d'associé. L'acquisition de l'appartement a été financée via des apports en comptes courants faits par les associées.

Le couple se sépare et Sébastien a notifié à la SCI une demande de remboursement du compte courant d'associé d'Amélie.

Question :

A-t-il des droits sur cette créance de compte courant.

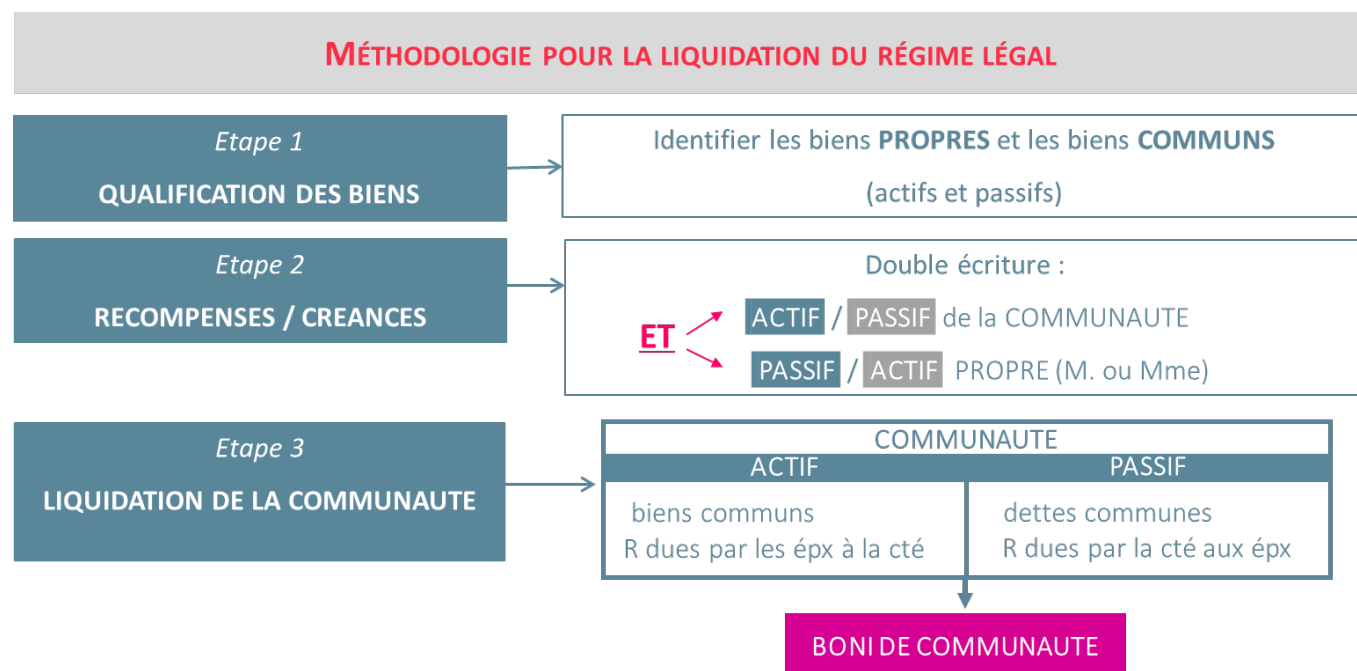
Peut-il obtenir le remboursement ?

Réponse :

Section 3 – La dissolution du régime

A – Méthodologie

Voici le schéma liquidatif à suivre :



L'identification des propres et communs a été étudiée. Reste à définir les notions de récompense et créances entre époux.

B – Les récompenses et les créances entre époux

1 – Les récompenses

Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux, c'est-à-dire dont il est résulté l'enrichissement de la communauté et l'appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l'époux, ou inversement.

Les récompenses se distinguent des créances entre époux, lesquelles résultent de transferts de valeurs entre les patrimoines propres des époux.

➤ Récompenses dues par la communauté à un époux

Elles trouvent leur principe énoncé dans l'article 1433 du code civil, lequel dispose que « *la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres* ».

➤ Récompenses dues par un époux à la communauté

Elles trouvent leur principe dans l'article 1437 du code civil, aux termes duquel : « [...] *toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense* ».

Les règles d'évaluation des récompenses résultent de l'article 1469 du code civil. La récompense est, selon les cas, égale à la dépense faite ou au profit subsistant.

- la dépense faite est la valeur empruntée par une masse de bien à l'autre, retenue pour son montant nominal à la date à laquelle la dépense a eu lieu, donc sans réévaluation ; c'est l'application du principe du nominalisme monétaire (C. civ., art 1895) ;
- le profit subsistant est l'avantage réellement procuré au patrimoine emprunteur au jour du règlement de la récompense ; c'est l'application de la théorie de la dette de valeur.

Alors, applique-t-on le profit subsistant ou la dépense faite ?

Les règles posées par l'article 1469 du Code civil sont les suivantes :

- **Principe : La récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.**
- Exceptions :
 - Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
 - Elle ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

En fait, la combinaison des alinéas 2 et 3 de l'article 1469 du code civil implique que la récompense ne peut être inférieure ni à la dépense faite ni au profit subsistant (règle du double minimum).

Il faut donc retenir la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Exigibilité des récompenses

Chaque récompense ne constitue pas véritablement une créance. En réalité elles doivent être comptabilisées dans chaque compte (compte de récompense de M., compte de récompense de Mme et compte de récompense de la communauté). Les récompenses constituent les éléments d'un compte unique et indivisible dont seul le reliquat après dissolution du régime est à considérer. Elles ne sont pas exigibles tant que le régime matrimonial n'est pas dissout (à la différence des créances entre époux).

EXERCICE N°13

Caroline hérite d'une maison pendant son mariage. Elle la revend 300.000 € et acquiert une nouvelle villa (300.000€) avec le prix de vente, sans déclaration de remploi. Plus tard, elle y fait construire une piscine au moyen de ses économies. La maison vaut, au jour de la liquidation, 400.000 euros. Sans la piscine, elle ne vaudrait que 360.000 euros.

Questions :

La nouvelle villa est-elle propre ou commune ?
Existe-t-il une récompense ?

Réponses :



Quid s'il s'agit d'une dépense d'acquisition, de conservation ou d'amélioration mais qu'il n'y a pas de profit subsistant ou un profit subsistant inférieur à la dépense faite ?

Dans ce cas, il existe deux possibilités :

- La valeur empruntée a servi à une dépense qui peut être qualifiée de nécessaire : alors la récompense sera égale à la dépense faite
- Soit ce n'est pas le cas et il faudra s'en tenir à évaluer la récompense au profit subsistant, même s'il est inférieur à la somme empruntée, voire nul.



Illustration

Une somme propre à Monsieur a servi à acquérir du matériel numérique (acheté 6.000€) pour Madame, passionnée de photographie. Faute de déclaration de remploi, le matériel acquis était commun, à charge de récompense au profit de Monsieur. Au jour de la liquidation, ce matériel est devenu obsolète et n'a plus de valeur. Il ne s'agissait pas d'une dépense nécessaire. Le droit à récompense existe bien pour Monsieur mais son évaluation est nulle.



Illustration

Une somme propre à Monsieur de 12.000€ a servi à remplacer la chaudière de la résidence principale commune du couple. La chaudière est commune mais à charge de récompense au profit de Monsieur. Au jour de la liquidation, le remplacement de la chaudière n'apporte pas vraiment de plus-value à la maison commune. En clair, si profit subsistant il y a, il est inférieur à la dépense faite (profit subsistant : 4.000 €). Mais en l'espèce, il s'agissait d'une dépense nécessaire. Le droit à récompense pour Monsieur doit alors être évalué à la dépense faite, soit 12.000 €.

Constituent des dépenses nécessaires, celles relatives à la conservation, la maintenance ou l'utilisation normale des biens. Cette notion de dépense nécessaire est comprise de manière plutôt extensive par la jurisprudence qui l'a appliquée par exemple aux dépenses d'entretien et réparation d'un immeuble mais également aux dépenses d'habilité voire de confort comme l'installation d'une salle de bains ou un agrandissement de la maison pour mieux répondre aux besoins de la vie familiale. Ce sont donc également les dépenses qui sont utiles sans être absolument indispensables.

EXERCICE N°14

Alors qu'il était marié en communauté légale, Pierre a reçu par donation une maison à la campagne.

Quelques années plus tard, il l'a vendu au prix de 100 000 euros. Dans la foulée, il a acquis un appartement à Lyon au prix de 140.000 euros, les frais d'acquisition s'élevant à 10 000 euros. La différence entre le prix de vente de la maison et le coût global de l'acquisition de la villa (frais compris), soit 50 000 euros, a été réglée au moyen d'économies réalisées par Pierre sur ses revenus.

L'épouse de Pierre vient de décéder et la communauté doit donc être liquidée.

L'appartement est actuellement évalué à 360.000 euros.

Questions :

L'appartement est-il propre ou commun ?

Existe-t-il une récompense ?

Réponses :



Dénouement d'un contrat d'assurance-vie dont la valeur de rachat était commune

Lorsqu'un époux commun en biens souscrit un contrat d'assurance-vie pendant le mariage sans déclaration de remploi, la valeur de rachat est commune. Au décès de l'époux souscripteur-assuré son contrat se dénoue. Sa valeur de rachat ne figure donc plus à l'actif commun. En revanche, cet époux (sa succession) est en principe redevable d'une récompense envers la communauté. Le prélèvement opéré par l'époux sur la communauté pour la souscription des contrats d'assurance-vie ouvre droit à récompense au profit de la communauté conformément à la règle posée par l'article 1437 du Code civil.

Le Code des assurances prévoit toutefois une exception : dans l'hypothèse où le bénéficiaire du contrat est le conjoint, alors il n'y a pas de récompense (C. ass., L132-16).

Comment évaluer la récompense ?

L'assurance-vie avec capital différé contre-assuré constituant une stipulation pour autrui, elle fait naître un droit direct au profit du bénéficiaire contre l'assureur (art. L132-12 C. ass.). Le dénouement du contrat par décès oblige ainsi l'assureur à verser directement le capital au bénéficiaire. Au jour de la liquidation du régime matrimonial, le contrat s'est dénoué et ne fait plus partie du patrimoine du souscripteur. Au final, le patrimoine de l'époux ne comprend ni le contrat ni le capital assuré. Il ne peut donc en résulter, à proprement parler, aucun « profit subsistant » pour l'époux souscripteur (art. 1469 al. 3 C. civ.).

Ainsi, une partie de la doctrine¹ considère que récompense est due à la communauté pour le montant de « la dépense faite » (art. 1469 al. 1er C. civ.), c'est-à-dire des primes versées. La jurisprudence est en ce sens².



Pas de récompense pour l'industrie de l'époux

¹ D. 1998, p. 26, « *La communauté qui a financé la souscription d'une assurance-vie doit-elle être récompensée lors du divorce ?* », par F. SAUVAGE ; Defrénois 1997, p. 1080, par G. CHAMPENOIS. Voir également en ce sens : Defrénois 1994, p. 737, « *Réflexions sur l'assurance-vie et le droit patrimonial de la famille* », par M. GRIMALDI.

² Cass. Civ. 1^{re}, 10 juin 1996 : JCP G 1997, I, 4008, n°16.

Si des travaux sont réalisés sur un bien propre, l'industrie personnelle déployée par un époux marié sous le régime légal ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté¹.

Un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. Il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien lui appartenant en propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté.

Par ailleurs, il en résulte que le profit subsistant sera déterminé d'après la seule proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué **au financement des travaux** sur le bien propre². En d'autres termes, il ne faut tenir compte que du coût des matériaux et non de la main d'œuvre pour déterminer le montant de la récompense due à la communauté³.

EXERCICE N°15

Leslie a reçu un terrain constructible par donation de ses parents, pour une valeur de 90.000 euros. Deux ans plus tard, elle épouse François sans contrat de mariage. Ensemble, ils font construire leur résidence principale sur ce terrain, ce qui leur coûte 230.000 euros.

Aujourd'hui ils divorcent. Leur maison est évaluée 360.000 euros. Si le terrain était resté nu, il vaudrait 110.000 euros.

Questions :

La maison est-elle propre ou commune ?

Existe-t-il une récompense ?

Réponses :

2 – Les créances entre époux

Ce sont les créances compensant des mouvements de valeurs entre les patrimoines propres des époux, c'est-à-dire dont il est résulté l'enrichissement du patrimoine propre de l'un des époux et l'appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de son conjoint.

Les créances entre époux sont susceptibles de concerner tant les époux communs en biens que ceux soumis au régime de la séparation de biens. C'est, cependant, dans le cadre de ce dernier qu'elles apparaissent le plus souvent. Si les règles qui les gouvernent sont globalement identiques sous les deux régimes, certaines spécificités des créances entre époux en régime séparatiste seront précisées ci-après.

¹ Cass. 1re civ., 5 avr. 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 137 ; Defrénois 1993, p. 800, obs. G. Champenois. – Cass. 1re civ., 18 mai 1994 : Bull. civ. 1994, I, n° 172 ; [JCP N 1995, II, p. 695](#), n° 19, obs. Ph. Simler ; D. 1995, somm. p. 43, obs. M. Grimaldi ; Defrénois 1995, p. 442, obs. G. Champenois. – Cass. 1re civ., 28 févr. 2006 : [JCP G 2006, I, 193](#), obs. A. Tisserand-Martin ; RTD civ. 2006, p. 360, obs. B. Vareille

² Cass. Civ. 1^{ère} 29 mai 2013 n°11-25.444 F+P+B JurisData n°2013-010709 Revue dt fam. Sept. 2013 p.29 n°119

³ [Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-19.829](#) : [JurisData n° 2015-013922](#)

Évaluation des créances entre époux (article 1479 du code civil) :

- Évaluation au profit subsistant lorsque la créance a pour origine une dépense d'amélioration, d'acquisition ou de conservation.
- À défaut, nominalisme monétaire. Cela signifie que la somme due est égale au montant emprunté au patrimoine créancier, donc à la dépense faite.

Il faut en retenir que le profit subsistant est applicable en principe mais quand les fonds propres n'ont pas été utilisés pour des biens particuliers, la règle du nominalisme monétaire prévaut et la créance sera du montant de la dépense faite (ex. : paiement d'une amende pénale par des fonds propres du conjoint).

Le renvoi à l'alinéa 3 de l'article 1469 du Code civil pose un problème d'interprétation :

- soit il s'agit d'une dérogation au principe du nominalisme monétaire dans les seuls cas prévus par cet alinéa : l'évaluation au profit subsistant n'est alors retenue que s'il est supérieur à la dépense faite ;
- soit c'est un renvoi « maladroit » à l'ensemble des dispositions de l'article 1469, auquel cas c'est le profit subsistant qu'il faut toujours retenir en cas d'amélioration, acquisition ou conservation d'un bien.

Cette question donne lieu à des divergences doctrinales et n'a pas été clairement tranchée en jurisprudence.

C'est pourquoi les conventions matrimoniales prévoient généralement des aménagements spécifiques (voir *infra*).

Exigibilité des créances entre époux

Les créances entre époux obéissent en principe aux règles de droit commun des créances, pour ce qui est du moment et de l'objet de leur paiement. Les créances entre époux peuvent donc être recouvrées pendant le mariage. Mais, le plus souvent, c'est lors de la liquidation du régime matrimonial que le règlement de ces créances a lieu.

C – Droits des parties dans la communauté

A la dissolution du régime matrimonial, chaque époux a des droits de moitié sur la communauté.

Mode de règlement des récompenses

Conformément à l'article 1470 du Code civil, le règlement des récompenses s'effectue par la modification des droits des parties dans la masse à partager.

Cela signifie que si balance faite, l'un des époux est créancier de la communauté au titre de récompenses alors il pourra prélever davantage sur l'actif commun jusqu'à due concurrence. Ainsi, la communauté pourrait finalement revenir dans des proportions différentes de la moitié à chacun, par exemple à 60% pour l'un et 40% pour l'autre.

Règlement des créances entre époux

Les créances entre époux obéissent en principe aux règles de droit commun des créances, pour ce qui est du moment et de l'objet de leur paiement.

La méthode utilisée en pratique pour le règlement des créances entre époux est la suivante : il est procédé à la compensation des créances réciproques des époux au sein d'un compte dont la balance va faire apparaître un reliquat qui viendra majorer la part de l'époux créancier dans le boni de communauté et minorer celle du conjoint débiteur.

Bien qu'intégrées aux opérations de liquidation matrimoniale par commodité, les créances entre époux n'entrent en aucun cas dans la masse partageable : étant étrangères à la communauté (elles ne concernent que les patrimoines propres des époux), elles ne figurent dans l'indivision post-communautaire ni à l'actif ni au passif. Elles ne figurent pas non plus dans l'indivision existant entre époux séparés de biens.

D – Distinction entre liquidation et partage

La liquidation et le partage sont deux choses distinctes.

La liquidation permet d'établir les droits théoriques de chacun, évalués en euros, représentant la valeur de la quote-part indivise de chacun.

À ce stade, et dès la fin de l'union, les parties sont dans ce que l'on nomme l'indivision post-communautaire. Tous les biens qui étaient communs sont désormais indivis entre les époux ou ex-époux.

Le partage quant à lui, se distingue de la simple liquidation. Il a pour objet de remplir chaque coindivisaire de ses droits par des attributions divises – les lots – mettant ainsi fin à l'indivision.

À l'issue du partage, chacun se trouve propriétaire exclusif de certains biens et/ou reçoit une soulte.

Partie III – RÉGIMES CONVENTIONNELS COMMUNAUTAIRES

Chapitre I – Aménagements relatifs à la composition des masses commune et propres

Section 1 – Choisir un modèle communautaire proposé par le Code civil

Nous traiterons ici des régimes communautaires. Le choix du régime par les époux doit être guidé par leur volonté plus ou moins grande de mettre leur patrimoine en commun. L'étendue de la communauté est en effet différente selon le modèle de régime choisi. Le contenu de cette communauté, quel que soit le régime choisi, peut ensuite être adapté selon les volontés particulières des clients. Cependant, l'état d'esprit d'un couple adoptant un régime de communauté universelle n'est décidément pas le même que celui d'un couple adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts, et ce, quels que soient les changements apportés aux modèles proposés par le Code civil.

Nous présenterons donc ici les régimes communautaires tels qu'ils sont proposés par le Code civil.

A – Communauté réduite aux acquêts

Ce régime a été étudié au titre du régime légal.

Faire un contrat alors que l'on veut choisir la communauté réduite aux acquêts : pourquoi ?

Ce régime peut être adopté par contrat de mariage dès lors que les époux décident de modifier au moins une des règles du régime légal. En effet, le mariage sans contrat ne permet aucun aménagement du régime légal. Il faudra donc établir un contrat de mariage si le couple veut déroger ou adapter une ou plusieurs règles de la communauté réduite aux acquêts.

Dit autrement, se marier sans contrat c'est être soumis au régime légal, la communauté réduite aux acquêts suivant les règles du Code civil exclusivement.

Enfin, la communauté réduite aux acquêts peut également être choisie dans le cadre d'une modification du régime matrimonial (par exemple, passage d'une séparation de biens à une communauté réduite aux acquêts).

La communauté réduite aux acquêts était également fréquemment adoptée par contrat de mariage par les époux avant le 1^{er} février 1966 (le régime légal étant alors celui de la communauté de biens meubles et acquêts).

B – Communauté de biens meubles et acquêts

Ancien régime légal, c'est encore aujourd'hui, le régime auquel sont soumis les époux qui se sont mariés avant le 1^{er} février 1966 sans avoir fait de contrat et qui n'ont pas déclaré vouloir se soumettre au nouveau statut légal. Il peut maintenant être choisi comme régime

conventionnel mais les statistiques montrent qu'il ne suscite plus d'intérêt parmi les candidats au mariage.

Le régime de communauté de meubles et acquêts est prévu aux articles 1498 et suivants du Code civil. La communauté de meubles et acquêts est une communauté plus étendue que la communauté réduite aux acquêts.

1 – Le patrimoine des époux

a – Les actifs

➤ Biens communs

Il s'agit d'une communauté dans laquelle sont englobés tous les biens de nature mobilière quelle qu'en soit l'origine. La communauté comprend en effet, en plus des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, tous les biens meubles des époux. Ainsi, tous les biens meubles appartenant aux époux avant le mariage et ceux qui leur échoient par succession ou libéralité pendant le mariage, viennent grossir la masse des acquêts.

La catégorie des meubles est de nos jours particulièrement fournie : les meubles meublants, c'est-à-dire le mobilier d'un logement, mais aussi l'argent liquide, les comptes bancaires, titres et valeurs de bourse, placements financiers divers, actions et parts de société, fonds de commerce, ou encore clientèles civiles.

De même que dans la communauté légale, il est possible de déroger à ces règles : soit dans le contrat de mariage en excluant certains biens de la communauté soit par la volonté du donateur par une clause d'entrée en communauté ou au contraire, d'exclusion de communauté.

➤ Biens propres

Sont propres les biens immobiliers appartenant aux époux au jour du mariage ou recueillis par succession, donation ou legs leurs demeurent propres. Lorsqu'un conjoint marié sous ce régime reçoit dans la succession de ses parents une maison et un fonds de commerce, la maison lui est seule propre tandis que le fonds de commerce entre dans la communauté.

Sont également propres :

- Les biens propres par nature (art. 1404 C. civ.) ;
- Les biens meubles reçus par libéralité lorsque le disposant avait stipulé une interdiction d'entrée en communauté (art. 1498, al. 1^{er}, C. civ.) ;
- Les biens acquis par subrogation réelle automatique, comme les parts sociales ou actions reçues suite à l'apport en nature d'un bien propre¹.

Quid du prix de vente d'un bien propre ?

¹ Sont propres les parts sociales acquises par un époux en contrepartie de ses apports immobiliers de biens propres à une société civile agricole : 1^{re} civ., 10 juil. 1996, n°94-17.471.

Certains auteurs avaient pu soutenir que le prix de vente d'un immeuble propre comme reçu par succession au cours du mariage devait tomber en communauté du fait de sa nature mobilière¹.

Il est certain aujourd'hui que cette analyse ne doit pas être retenue. Les deniers subrogés à l'immeuble propre ont le caractère propre. D'ailleurs, il a toujours été reconnu à l'époux marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts la possibilité de procéder aux formalités de remploi du prix de vente d'un immeuble à lui propre.

b – Le passif

En premier lieu, le passif de la communauté de meubles et acquêts est le même que celui de la communauté légale.

Mais il comprend en outre "une fraction (des dettes) dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage".

Cette fraction est elle-même précisée par l'article 1499, alinéa 2 : elle est proportionnelle à la fraction de l'actif que la communauté recueille soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité.

Pour calculer cette fraction supplémentaire de passif commun, il convient d'effectuer les opérations suivantes :

- déterminer, comme l'indique l'article 1499, alinéa 3, la consistance et la valeur de l'actif tombant en communauté ;
- calculer la proportion d'actif recueilli par la communauté par rapport à l'ensemble des biens qui sont la propriété de l'époux au moment du mariage ou reçus par voie de succession ou libéralité ;
- appliquer cette proportion à l'ensemble du passif revenant à l'époux.

Toutefois, on peut noter que pour les dettes successorales, ce calcul peut s'avérer souvent théorique car, la plupart du temps, le passif successoral est réglé avant le partage de l'actif, en sorte que l'époux héritier reçoit une part nette.

Obligation aux dettes

Les dettes nées en cours de mariage du chef des époux suivent le même sort que dans le cadre du régime légal.

Précisons que selon l'article 1501 *"la répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers"*. Autrement dit, la répartition proportionnelle du passif prévue par l'article 1499 ne peut leur être opposée si elle conduit à réduire leur gage par rapport à ce qu'il était avant le mariage de leur débiteur.

En application de cette règle, les créanciers peuvent, en premier lieu, exercer leur droit de poursuite, pour la totalité de leur créance, sur *"les biens qui formaient auparavant leur gage"*. Les biens ainsi visés sont, d'abord, ceux qui sont restés propres. Il s'agit ensuite des biens meubles qui sont entrés en communauté par l'effet du régime conventionnel adopté. Il en résulte que les créanciers peuvent donc agir au-delà de la fraction de passif que la communauté doit supporter.

¹ J.-Cl. Civil code, art. 1433 à 1437, fasc. unique : communauté légale, n° 12 et s.

L'article 1501 *in fine* accorde, en outre, une protection complémentaire aux créanciers, en étendant leur droit de poursuite à l'ensemble de la communauté en cas de confusion de mobilier (principe défini supra dans les exceptions aux règles de l'obligation au passif, page 57 ou suivante).

Contribution aux dettes

Les dettes nées en cours de mariage du chef des époux suivent le même sort que dans le cadre du régime légal.

Les dettes liées à l'accroissement d'actif recueilli par la communauté sont à la charge définitive de la communauté (art. 1500 C. civ.).

2 – Les pouvoirs sur les biens

On applique à ce régime les règles de gestion des biens du régime de communauté légale. Autrement dit, le principe est celui de la gestion concurrente (C. civ., art. 1421). En effet, chaque époux est propriétaire de tous les biens communs pendant la vie du régime. Chacun a le droit de gérer seul les biens de la communauté, c'est-à-dire que chacun peut vendre seul les biens de communauté.

Mais les exceptions sont nombreuses. Sont ainsi soumis à la co-gestion, ou gestion conjointe, un certain nombre d'actes importants. La loi énumère ces actes nécessitant l'accord des deux conjoints et nous renvoyons ici à l'étude déjà faite dans le régime légal (page 62 et suivantes).

3 – La dissolution du régime

Nous renvoyons ici à nos développements sur la communauté légale (page 69 et suivants) :

- La méthodologie de liquidation est identique ;
- Le régime matrimonial est liquidé de manière identique dans les hypothèses de décès et de divorce ;
- Les règles relatives aux récompenses sont les mêmes ;
- Chaque époux a droit à la moitié du boni de communauté.

C – Communauté universelle

Le régime de communauté universelle est celui qui laisse la place la plus large à la communauté. Il est prévu aux articles 1526 et suivants du Code civil. La communauté universelle est une communauté largement plus étendue que la communauté légale.

1 – Le patrimoine des époux

a – Les actifs

➤ Biens communs

La communauté est élargie à la totalité des biens des époux : biens meubles et immeubles, présents et à venir. Tous les biens appartenant aux époux avant le mariage et ceux qui leur échoient par succession ou libéralité pendant le mariage, viennent grossir la masse des acquêts.



L'acte notarié portant changement de régime matrimonial ne mentionne pas tous les biens « apportés » ; les biens omis sont-ils demeurés propres ?

Non !

Le contenu de la communauté est défini par la convention matrimoniale. Dans l'hypothèse où l'on a utilisé le modèle du Code civil, tous les biens présents et futurs composent la communauté, à l'exception des propres par nature comme nous l'avons indiqué.

Que les biens présents, c'est-à-dire ceux existants au jour du mariage ou du changement de régime, soient tous listés ou non, peu importe : ils sont devenus communs.

Concernant les biens et droits immobiliers appartenant déjà à l'un des époux, leur entrée en communauté doit faire l'objet de la publicité foncière. A défaut, ils sont tout de même communs en vertu des stipulations de la convention mais la publicité reste à faire pour « titrer » les deux époux. Si le notaire qui a reçu le changement de régime ne l'a pas fait à cette occasion, il faudra le faire ensuite, notamment si les époux envisagent de vendre l'un de ces biens.

➤ Biens propres

L'article 1526 du Code civil exclut de la communauté les biens propres de l'article 1404 du Code civil c'est-à-dire « les vêtements et linges à l'usage personnel des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ».

Comme dans les autres régimes communautaires, le bien reçu par donation restera propre au donataire si le donateur stipule une exclusion de communauté.

Enfin, comme nous l'étudierons ensuite, cette communauté peut bien sûr être aménagée. Les époux peuvent également faire tomber dans la masse commune les propres par nature. Ils n'ont alors pas de biens propres. Il est également possible de prévoir que cette communauté universelle ne comprendra que les biens futurs et ne fera pas entrer en communauté les biens propres présents ou encore exclure certains biens précis de la communauté.

b – Le passif

Corrélativement à l'actif, toutes les dettes sont à la charge de la communauté, quelle que soit leur nature ou leur origine.

Obligation aux dettes

Il convient de faire application des articles 1413 et suivants du Code civil dont l'article 1415 du Code civil en matière d'emprunt. En effet, « les dispositions de l'article 1415 sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle »¹. La première Chambre civile de la Cour de cassation l'a affirmé dans un arrêt du 3 mai 2000.

Contribution aux dettes

¹ Cass. 1^{re} civ., 3 mai 2000, n°[97-21.592](#).

L'article 1526 du Code civil prévoit que « la communauté supporte définitivement toutes les dettes des époux présentes et futures ».

2 – Les pouvoirs sur les biens

On applique à ce régime les règles de gestion des biens du régime de communauté légale. Autrement dit, le principe est celui de la gestion concurrente (C. civ., art. 1421). En effet, chaque époux est propriétaire de tous les biens communs pendant la vie du régime. Chacun a le droit de gérer seul les biens de la communauté, c'est-à-dire que chacun peut vendre seul les biens de communauté.

Mais les exceptions sont nombreuses. Sont ainsi soumis à la co-gestion, ou gestion conjointe, un certain nombre d'actes importants. La loi énumère ces actes nécessitant l'accord des deux conjoints et nous renvoyons ici à l'étude déjà faite dans le régime légal (page 62 et suivantes).

3 – La dissolution du régime

Attention : si communauté universelle et attribution intégrale sont souvent mariées, ce n'est pas chose obligée !

La clause d'attribution intégrale est un aménagement du régime type proposé par le Code civil.



En effet, le régime type de communauté universelle proposé par le Code civil ne prévoit aucune règle particulière quant à la répartition de cette communauté à la fin du mariage. Le principe est donc celui du partage par moitié entre les époux (en cas de succession, une moitié de la communauté revient au survivant et l'autre moitié compose la succession de l'époux décédé).

Il faut donc vérifier les clauses du contrat de mariage sur ce point.

En effet, il n'est pas rare que cette communauté universelle soit assortie d'une clause d'attribution intégrale (étudiée *infra*). Dans ce cas, par l'effet de cette convention matrimoniale, tous les biens communs reviennent au survivant des époux. La succession en sera donc privée.

Nous renvoyons ici à nos développements sur la communauté légale (page 69 et suivants) :

- La méthodologie de liquidation est identique ;
- Le régime matrimonial est liquidé de manière identique dans les hypothèses de décès et de divorce ;
- Chaque époux a droit à la moitié du boni de communauté.

Existe-t-il des récompenses en communauté universelle ?

L'article 1497 *in fine* du Code civil dispose que les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Aussi, sauf stipulation contraire contenue au sein de la convention de mariage, les dispositions légales relatives aux récompenses sont applicables.

Cependant, de notre point de vue, le mécanisme des récompenses s'articule mal avec le régime de la communauté universelle.

En effet, on peut considérer qu'en application du principe de corrélation entre l'actif et le passif, aucune dette de récompense ne peut exister en régime de communauté universelle (à l'exception de dettes nées relativement à des biens demeurés propres). À partir du moment où la communauté comprend l'universalité des biens des époux, elle ne peut pas

laisser à la charge de l'un d'eux une dette telle une dette de récompense. La doctrine incline d'ailleurs en ce sens¹.

Restent toutefois des hypothèses qui pourraient prêter à discussion comme celle de la souscription d'un contrat d'assurance-vie dont le bénéficiaire serait un autre que le conjoint.



Conseil pratique : pour éviter toute incertitude sur la liquidation, on pourra prévoir dans la convention matrimoniale qu'aucune récompense ne sera due (voir infra, les aménagements possibles en matière de récompenses, page 86).

Section 2 – Aménager ponctuellement la nature d'un bien

A – Apport à communauté (ou « ameublement »)

Sur la base de l'un des régimes types proposés par le Code civil, les époux peuvent décider d'élargir la masse commune.

Cet élargissement peut concerner une catégorie de biens, selon leur nature ou leur origine par exemple, mais aussi certains biens précisément définis.

Bien évidemment la composition des masses commune et propres impactera les réflexes habituels en matière de récompenses et il faudra veiller à des vérifications spécifiques.

Quant à la contribution au passif, si l'apport est à titre particulier, il n'impactera pas la contribution au passif mais le gage des créanciers se trouvera le cas échéant étendu au bien apporté.

En pratique, l'on rencontre fréquemment les clauses dites « d'ameublement » dont l'objet est de faire entrer en communauté un bien qui aurait été propre selon les règles légales.

Cette clause est notamment opportune lorsque l'un des époux est propriétaire en propre d'un terrain destiné à recevoir l'édification du logement de la famille. L'apport à communauté par contrat de mariage ou changement de régime matrimonial doit être préféré selon nous dans cette situation à une clause d'entrée en communauté stipulée par le donateur².

Elle peut également être stipulée lorsque l'un des époux est déjà propriétaire d'un immeuble au jour du mariage, qu'il a acquis au moyen d'un emprunt dont les échéances seront par la suite payées grâce à des fonds communs (salaires le plus souvent), donnant lieu à récompense. Il est alors parfois préférable de prévoir l'apport à communauté du bien ainsi que de la dette de prêt.

EXERCICE N°16

Ludovic a acquis en 2011 une maison dans laquelle il vit avec sa compagne, Marie. Pour faire cette acquisition, Ludovic avait contracté un prêt bancaire, avec échéances mensuelles. A ce jour, le capital restant dû s'élève à 130.000 €.

¹ B. BEIGNIER, « Récompenses et communauté universelle », JCP N 2010, article 1358 ; A. Colomer in Rép. Civ. Dalloz, V° Communauté conventionnelle, n° 178.

² Voir le cours Donations et donations-partages concernant les inconvénients de la clause de mise en communauté.

Par ailleurs, sa compagne, Marie, a investi dans cette maison la somme de 50.000 € au titre de travaux.

Marie et Ludovic ont décidé de se marier. Ils ont entendu parler du régime légal et ils estiment que cela leur convient globalement.

Questions :

Que pouvez-vous leur dire sur les conséquences d'un mariage sans contrat eu égard à leur résidence principale ?

Pourrait-on leur conseiller des aménagements pour améliorer cette situation, tout en conservant un régime communautaire ?

Réponses :

La mise en communauté peut également être utilisée dans le régime de la séparation de biens ; on parle alors de l'adjonction d'une société d'acquêts. Cela sera étudié infra (pages 111 et s.).



Attention

L'apport à communauté est en principe gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie¹. Il peut toutefois être stipulé à titre onéreux ; on parle alors d'apport « *valant vente à la communauté* » ou d'apport à charge de récompense (due par la communauté à l'époux apporteur).

B – Stipulation de propre (ou clause d'exclusion de communauté)

De la même manière que les époux peuvent choisir d'inclure certains biens ou certaines catégories de biens dans la masse commune, ils peuvent décider d'exclure des biens. Cela est possible, quel que soit le régime de communauté choisi par les époux.

Les incidences en termes de passif et de récompenses suivent les principes évoqués ci-avant pour l'élargissement de la communauté.

On trouvait notamment des clauses d'exclusion du mobilier dans les régimes de communauté de meubles et acquêts ou de communauté universelle afin de limiter la masse commune. L'objectif était généralement d'éviter que les biens meubles présents et ceux qui seront recueillis à titre gratuit ne tombent dans la communauté.

Mais aujourd'hui, ces régimes n'étant plus très usités, c'est surtout l'outil professionnel qui fait l'objet de clauses d'exclusion de communauté.

L'intérêt réside à la fois dans la propriété exclusive mais également la gestion exclusive de ces biens.

Il peut être envisagé d'exclure les revenus de biens propres dont il n'est pas forcément de l'essence de constituer des biens communs ... Il faudra alors prendre soin d'encaisser ces revenus sur des comptes *ad hoc* pour faciliter la preuve de l'établissement de leur caractère propre, puis, le cas échéant, de faire des déclarations d'emploi.

¹ Pour une illustration récente, voir : Cass. 1^{re} civ., 3 oct. 2019, n° [18-20.430](#).

Stipulation de propre pour l'entreprise individuelle : une fausse bonne idée ?

Il est souvent conseillé à l'époux entrepreneur individuel, ou à l'époux qui pourrait, en raison de son activité professionnelle, se retrouver avec des passifs importants à charge, d'opter pour le régime de la séparation de biens.

Mais la solution peut être insatisfaisante lorsque, par exemple, le conjoint de l'entrepreneur n'a pas d'activité rémunérée. Le risque pour lui est d'avoir plus ou moins directement contribué à la réussite d'une entreprise sans pouvoir espérer en tirer parti au plan patrimonial.

Parfois, est évoqué la solution qui résiderait dans l'adoption d'un régime communautaire avec une stipulation de propre pour l'outil professionnel.

Dans l'hypothèse où l'entreprise fonctionne normalement ou mieux, l'avantage serait le partage pour partie de l'enrichissement dans le couple. L'existence d'une communauté alimentée par les revenus de l'entreprise et les acquisitions et investissements en résultant profiteraient à la communauté et donc aux deux membres du couple.

La plus-value acquise par l'entreprise, quant à elle, ne profiterait qu'à l'époux propriétaire en propre.

Mais attention, si l'entreprise connaît des difficultés, l'on retrouve ici l'écueil évoqué sur le droit de gage des créanciers.

Une dette née pendant le mariage, quand bien même elle concernerait une entreprise individuelle appartenant en propre à un seul des époux, engage le patrimoine commun du couple. Une dette de fournisseur, une dette fiscale ou une dette sociale, comme l'URSSAF peuvent représenter des montants importants et le droit de gage des créanciers porte alors sur le patrimoine propre de l'époux entrepreneur mais également sur le patrimoine commun.

Des nuances sont à apporter bien sûr avec, d'abord, l'insaisissabilité de droit de la résidence principale et, ensuite le cas particulier des prêts et cautionnements. En effet, les prêts bancaires ne sont en principe pas concernés puisqu'il existe une disposition spécifique. Rappelons qu'en cas d'emprunt ou de cautionnement, le patrimoine commun ne peut être engagé que si le conjoint de l'intéressé y a expressément consenti.

Le nouveau statut de l'entrepreneur individuel constitue un nouvel élément à prendre à compte mais ne règle pas le problème.

Pour savoir si la stipulation de propre est adaptée, il faut donc préalablement s'interroger sur la balance risques/bénéfices !

Chapitre II – Aménagements relatifs à la dissolution et au partage

Section 1 – Modifier les règles relatives aux récompenses ou créances entre époux

A – Les récompenses

Il a toujours été admis, en doctrine comme en jurisprudence, que les dispositions légales relatives aux récompenses ne sont pas impératives. Comme tout aménagement, elle est soumise au formalisme de l'article 1397 du Code civil.

La convention matrimoniale peut dispenser du service de toute récompense celui des époux qui s'enrichirait aux dépens de la communauté. À l'inverse, il est également possible de prévoir que cette dernière ne devra, par principe, aucune récompense, même si elle s'est trouvée augmentée au détriment des propres.

Il est ainsi possible de modifier les règles légales en matière de récompenses dans la convention matrimoniale. On peut donc exclure un ou plusieurs chefs de récompense que ce soit en faveur de la communauté ou de l'un des époux. On parle de dispense de récompense.

Mais on peut également modifier les règles de calcul des récompenses pour s'affranchir de l'article 1469 du Code civil. Il est par exemple possible de prévoir qu'elles seront évaluées au nominal (la dépense faite).



Conseil pratique

Il n'est pas toujours possible de savoir si ces aménagements constitueront un avantage pour l'un ou l'autre des époux mais ils peuvent avoir une vertu simplificatrice pour la liquidation à la fin de l'union.



Illustrations

- Résidence du couple : une clause du contrat de mariage pourrait ainsi valablement écarter toute récompense pour les dépenses afférentes au logement constituant la résidence principale commune des époux, sauf pour les apports en capitaux propres ou remboursements de prêts anticipés effectués avec ces mêmes capitaux.
- Contrats d'assurance-vie : le contrat de mariage peut prévoir une dispense de récompense pour le dénouement du contrat souscrit en adhésion simple au moyen de fonds communs et dont le bénéficiaire est un autre que le conjoint (ou bien prévoir cette dispense si et seulement si le bénéficiaire est un enfant commun, par exemple).
- Communauté universelle : possibilité de prévoir qu'il n'y aura aucune récompense.

B – Les créances entre époux

La convention matrimoniale peut également comporter des clauses modifiant l'existence ou les règles d'évaluation des créances entre époux. La solution se trouve ici confortée par l'article 1479, alinéa 2, du code civil qui ménage expressément la « convention contraire des parties » pour écarter l'application du mode de calcul légal. Le contrat de mariage peut ainsi

exclure toute réévaluation des créances entre époux, ici encore dans un souci de simplification et de pacification des comptes entre ex-époux.

L'évaluation des créances entre époux est très fréquemment aménagée pour pallier la difficulté inhérente au renvoi partiel de l'article 1479 vers l'article 1469 du Code civil (voir nos développements *infra* page 106)

Section 2 – Favoriser le survivant en modifiant la règle de répartition par moitié des biens communs

A – Le préciput

La clause de préciput est prévue par les articles 1515 et suivants du Code civil.

La clause de préciput (du latin « *pre-capere* », c'est-à-dire prendre avant) permet au survivant des époux, de prélever avant le partage, dans le patrimoine commun :

- une certaine somme ;
- certains biens en nature ;
- ou une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.

La clause peut être stipulée au profit du survivant des époux, quel qu'il soit, ou bien au profit seulement de tel époux, s'il survit.

Ajoutons qu'elle peut porter soit sur la pleine propriété soit sur l'usufruit seulement des biens concernés.

Le préciput ne peut viser que des biens dépendant de la communauté.

Le préciput a vocation à porter sur un objet particulier. Cet élément est précisément ce qui le distingue d'une clause de partage inégal (art. 1521 C. civ.), dont l'objet est défini comme étant à titre universel. Ainsi, un « préciput » qui porterait sur l'ensemble des meubles ou l'ensemble des immeubles serait à titre universel. Il constituerait une clause de partage inégal et non un préciput, produisant des effets différents, notamment quant à la charge corrélative du passif. En effet, constituant une stipulation à titre particulier, la clause de préciput ne modifie pas la répartition de la charge du passif entre les époux.

Il s'agit d'un avantage matrimonial puisque l'époux est autorisé à faire ce prélèvement sans contrepartie ni diminution de ses droits sur le solde de la communauté. Ainsi, si l'époux exerce le préciput, il recueillera le bien qui en est l'objet avant tout partage et aura ensuite droit à la moitié de l'actif net restant. Cette clause porte atteinte à l'égalité en valeur du partage, puisque l'époux recevra plus que la moitié de la communauté qu'il aurait dû avoir en l'absence du préciput.

La clause de préciput ne s'impose pas à l'époux bénéficiaire mais lui offre une faculté d'exercer le prélèvement prévu dans la convention matrimoniale (l'art. 1515 C. civ. indique que l'époux « sera autorisé à prélever »)¹.



Conseil pratique : multiplier les choix

Il est possible de prévoir la stipulation de plusieurs clauses de préciput distinctes. Cela permet au survivant de choisir ou non d'exercer le préciput sur chaque objet distinct, préalablement défini dans la convention matrimoniale (exemple : un préciput sur la résidence principale, un sur chaque résidence secondaire ou immobilier locatif, un autre sur les comptes de dépôt à vue, etc).



Conseil pratique : prévoir un délai

La loi ne prévoit aucun délai pour l'exercice du préciput. Il est donc vivement recommandé de le prévoir dans la convention matrimoniale. Par exemple prévoir que les héritiers pourront mettre en demeure le conjoint survivant de prendre parti dans tel délai, que le conjoint devra faire connaître son choix auprès de telle personne et que passé ce délai, sans manifestation de sa part, le conjoint sera réputé avoir renoncé au(x) préciput(s).



Attention

Le préciput ne s'exerce que sur l'actif net, les créanciers conservent le droit de faire vendre le bien sur lequel il porte. Dans ce cas, l'époux bénéficiaire peut demander le paiement d'une valeur équivalente sur le reste des biens communs.

La clause de préciput présente de multiples avantages :

- Le contrat de mariage contenant un préciput sur la résidence principale en pleine propriété constitue un excellent moyen d'assurer au conjoint survivant le maintien de son cadre de vie (logement et meubles meublants). On évite ainsi les problèmes liés à la situation de démembrement ou d'indivision ;
- Limitée à certains biens, elle permet de réaliser un compromis entre l'objectif de protection du conjoint et le souci de respecter les droits des autres héritiers ;
- Le préciput peut être utilement stipulé pour éviter une situation d'indivision successorale sur certains biens communs sensibles (actions, fonds de commerce, etc) ;
- Il permet de régler la question de la distorsion entre l'avoir et le pouvoir pour les biens auxquels on applique la distinction du titre et de la finance
- La clause offre une grande souplesse puisque le préciput peut porter sur la pleine propriété ou uniquement sur l'usufruit des biens.

¹ FLOUR et CHAMPENOIS, *Les régimes matrimoniaux*, Armand Colin, 2^e éd., n°710 ; TERRE et SIMLER, *Les régimes matrimoniaux*, Dalloz, 6^e éd., n°752.



Le contrat d'assurance-vie non dénoué

Le préciput peut également permettre de régler la question de la distorsion entre l'avoir et le pouvoir pour les biens auxquels on applique la distinction du titre et de la finance. C'est notamment le cas du contrat d'assurance-vie non dénoué.

Prenons l'exemple de Sophie et Thierry. Mariés sans contrat en 1975, ils ont souscrit en adhésion simple un contrat d'assurance-vie chacun. Au décès de Thierry, son contrat est dénoué et les capitaux sont versés aux bénéficiaires¹. Mais le contrat de Sophie est toujours en cours. Suivant la jurisprudence Praslicka, sa valeur de rachat est à inscrire à l'actif de communauté. Cela signifie que la moitié de cette valeur de rachat compose la succession de Thierry, et revient à ses héritiers.

Or, la distinction du titre et de la finance permet à Sophie, et ce depuis le jour de la souscription, de gérer seule et de manière exclusive son contrat. Le décès de Thierry ne change rien à la chose. En revanche, la situation est inconfortable pour les héritiers de Thierry, puisque la valeur de rachat (qui leur revient pour moitié), leur échappe complètement.

La stipulation d'une clause de préciput sur la valeur de rachat du ou des contrats souscrits par l'époux survivant peut permettre d'aligner l'avoir sur le pouvoir.

B – La stipulation de parts inégales ou l'attribution intégrale

L'article 1520 du Code civil prévoit qu'il est possible de déroger au principe de partage par moitié de la communauté et cela, suivant deux modalités distinctes :

- la stipulation de parts inégales dans le partage de la communauté,
- l'attribution de la communauté toute entière au survivant.

Elles peuvent porter soit sur la pleine propriété soit sur l'usufruit seulement.

L'une comme l'autre, ne constituent pas des options ou des facultés offertes au survivant. Elles jouent de manière automatique et s'imposent à l'époux bénéficiaire (voir *infra* sur la possibilité de rédiger une clause d'attribution intégrale optionnelle).

Elles ont également en commun de pouvoir être stipulées pour le survivant des époux, quel qu'il soit, ou au profit de l'un d'entre eux seulement s'il survit.

Pour l'une comme pour l'autre, la corrélation entre actif et passif s'impose (C. civ., art. 1521) : le survivant qui bénéficie d'une attribution inégale portant par exemple sur 75% de la communauté devra supporter le passif commun dans les mêmes proportions. Celui qui bénéficie d'une attribution intégrale devra supporter l'intégralité du passif. Il est interdit de déroger à cette proportionnalité.

¹ Ce qui pourra constituer un chef de récompense, voir nos développements page 47 ou suivantes.



Reprise des apports et capitaux

Lorsque les époux ont choisi une communauté élargie comme la communauté universelle, l'efficacité de ces clauses est subordonnée à une autre disposition du contrat de mariage : celle qui écarte le droit de reprise des héritiers du prémourant. En effet, l'article 1525 du Code civil offre aux héritiers de l'époux qui décède en premier la possibilité de faire obstacle à la stipulation de parts inégales ou à l'attribution intégrale. Ce texte leur confère un droit de « reprise » portant sur les biens qui auraient été propres sous le régime légal (notamment les biens présents apportés à la communauté et biens reçus à titre gratuit pendant le mariage).

Lorsqu'il est exercé par les héritiers du prémourant, la communauté se réduit aux acquêts (et aux apports de l'autre époux, le survivant). Les biens repris sont alors soustraits à la clause de partage inégal. Cela limite les effets de la clause, de sorte que l'attribution intégrale ne porte que sur les acquêts (biens communs sous le régime légal). Les biens objets de cette reprise échappent ainsi à l'attribution intégrale et composent la succession du prémourant, pour être dévolus à ses héritiers.

1 – La stipulation de parts inégales

Cette clause stipule que les époux recevront une part inégale des biens communs, suivant l'exemple donné par l'article 1521 du Code civil. On peut en effet prévoir que l'un des époux, le survivant ou les héritiers de l'époux décédé, n'aura qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart. Mais d'autres modalités de partage seraient d'ailleurs possibles, comme l'attribution des meubles à l'un et des immeubles à l'autre. Généralement il est précisé que la clause profite au survivant des époux, qui n'en profitera qu'en cas de dissolution de la communauté par décès.

2 – L'attribution intégrale de communauté

Suivant l'article 1524 du Code civil, il peut être stipulé que l'intégralité de la communauté sera attribuée au survivant, quel qu'il soit, ou à tel époux, s'il survit.

Nous avons déjà indiqué (voir page 82) que l'attribution intégrale est souvent prévue dans un régime de communauté universelle mais cela n'est pas impératif :

- ✓ La communauté universelle peut être adoptée sans attribution intégrale
- ✓ Une clause d'attribution intégrale peut être prévue dans un autre régime communautaire.

En pratique, l'attribution de la communauté entière est souvent stipulée en complément de l'adoption d'un régime de communauté universelle, lorsque l'objectif est la protection du conjoint survivant. La clause est particulièrement intéressante pour les époux âgés et sans descendants ou ceux qui ont déjà organisé la transmission de leur patrimoine à leurs enfants (par donation-partage notamment).

Il convient toutefois de faire attention à l'effet plutôt radical d'une clause d'attribution intégrale.

- Le cantonnement n'est pas applicable en la matière. Le cantonnement est une faculté offerte aux seuls bénéficiaires de dispositions à cause de mort. Elle leur permet de

choisir, parmi les biens légués, ceux qu'ils veulent retenir et donc d'abandonner les autres, dévolus aux héritiers légaux. Les avantages matrimoniaux ne sont pas des dispositions à cause de mort et le cantonnement est donc inapplicable à une clause d'attribution intégrale.

- Et le conjoint ne peut pas refuser totalement ou partiellement l'attribution intégrale dont il bénéficie.

La clause d'attribution intégrale telle que prévue à l'article 1524 du Code civil est une clause de partage inégal de la communauté et constitue un avantage matrimonial qui s'exécute de plein droit au décès du premier des époux. Contrairement au préciput, aucune faculté n'est laissée au survivant quant à la mise en jeu de cet avantage. La clause d'attribution intégrale développe tous ses effets dès la survenance du décès de l'époux et indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du survivant.

C'est la raison pour laquelle toute renonciation totale ou partielle à l'attribution intégrale qui serait faite par le survivant serait translatrice de propriété au profit de ceux appelés à en bénéficier (généralement les enfants) et constitutive d'une mutation à titre gratuit taxable en conséquence.

- Alors, le contrat de mariage peut-il valablement offrir au conjoint une faculté de renonciation ou une clause d'attribution intégrale optionnelle ?

En d'autres termes, la faculté de choix offerte au conjoint doit-elle être limitée aux hypothèses expressément prévues par la loi tel le préciput ?

La doctrine est partagée¹ et, à notre connaissance, la question n'a jamais été soumise à la Cour de cassation.

La position de l'AUREP

Le principe de liberté des conventions matrimoniales (C. civ., art. 1387) devrait permettre de reconnaître la validité d'une clause d'attribution intégrale optionnelle. Rappelons brièvement les principales limites que fixe la loi à ce principe de liberté : le respect des bonnes mœurs, celui des règles d'ordre public (capacité juridique, égalité homme-femme, libertés individuelles comme celle de divorcer, etc), le respect du principe d'irrévocabilité spéciale des donations ou encore celui des règles impératives du régime primaire matrimonial.

En l'espèce, l'on ne voit aucune contravention à ces règles dans la clause proposée.

Reste qu'en l'absence de jurisprudence, le risque civil comme le risque fiscal ne peuvent être écartés.

¹ En faveur de cette possibilité : F. LUCET, Dalloz Action, Droit Patrimonial de la famille, repris par G. BONNET dans l'éd. 2018/2019 n° 151-72. Pour une position contraire : A. BOITELLE, « *L'attribution intégrale de communauté et l'option* », Agora n°32, nov. Déc. 1998. Voir également pour une proposition de formule d'attribution intégrale optionnelle : R. BOUQUILLARD, « *La Clause d'attribution optionnelle de communauté* », JCP N 2002, 1009.



Conseil pratique

En attendant une jurisprudence sur ce point, la stipulation de plusieurs clauses de préciput distinctes demeure aujourd'hui la solution la plus sûre. Cela permet au survivant de choisir ou non d'exercer le préciput sur chaque objet distinct, préalablement défini dans la convention matrimoniale (exemple : un préciput sur la résidence principale, un sur chaque résidence secondaire ou immobilier locatif, un autre sur les comptes de dépôt à vue, etc).

Les époux étaient mariés en communauté universelle avec attribution intégrale, il n'y a pas de succession à régler

Attention aux raccourcis !

Dans cette hypothèse, il est vrai que l'actif successoral laissé par le défunt est réduit à peau de chagrin : le régime matrimonial étant traité avant la succession, tous les biens communs sont attribués au survivant et il ne reste que les biens propres, quasi-inexistants dans ce régime. Pour cette raison d'ailleurs, les legs s'avèrent bien souvent inefficaces.

Mais attention, le règlement de la succession ne se borne pas à répartir les biens que le défunt laisse à son décès !

Avant comme pendant le mariage, l'époux, ou les deux époux, ont pu consentir des libéralités.

La question du rapport successoral et celle du respect de la réserve héréditaire doivent alors se poser. L'attribution intégrale ne dispense pas de faire la liquidation successorale.



Ces principes ont été récemment rappelés par la Cour de cassation (voir nos actu du 7 mai 2019).

Ainsi le rapport des libéralités est dû entre cohéritiers en présence de libéralité(s) en avance de part successorale. Par exemple, si le défunt avait fait donation d'un bien propre avant son changement de régime à l'un de ses deux enfants, l'autre pourra en demander le rapport successoral. Faute d'actif successoral pour servir le deuxième enfant de manière égalitaire, le premier sera contraint de verser une soulte

...

Dans le cas où les deux parents ont fait donation à un enfant commun, la Cour de cassation a rappelé que celle-ci est rapportable pour moitié dans chacune des successions des père et mère, nonobstant l'adoption ultérieure par les parents du régime de la communauté universelle avec attribution intégrale. Le régime matrimonial des époux n'a pas pour effet de dispenser le donataire du rapport successoral au décès du premier des époux (Cass. 1^{re} civ., 17 avr. 2019, n°18-16.577).

De même, en présence d'enfant(s) exclusivement commun(s) et de libéralité(s) hors part successorale, il conviendra de vérifier qu'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire (Cass. 1^{re} civ., 3 avr. 2019, n° 18-13.890). Dans cette hypothèse, la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible est composée, pour l'essentiel, de la réunion fictive des libéralités.

Pour le dire autrement, l'adoption d'une communauté universelle rend les libéralités hors parts successorales plus exposées au risque de réduction.

Section 3 – Favoriser le survivant en le soustrayant à l'aléa du partage

A – Le prélèvement moyennant indemnité

Reconnue d'abord par la jurisprudence, cette clause entre au Code civil aux termes de la loi du 13 juillet 1965, aux articles 1511 à 1514. La clause de prélèvement moyennant indemnité est la clause par laquelle l'un des époux, au moment du partage de la communauté, se fait attribuer, par préférence et en exclusivité, la propriété d'un ou de plusieurs biens communs déterminés, à charge d'en indemniser la communauté.

Il s'agit d'une faculté offerte à l'époux survivant, quel qu'il soit, ou à l'un d'entre eux seulement s'il survit.

A la différence de la clause de préciput qui autorise le prélèvement sans diminution des droits dans le solde de la communauté, la clause de prélèvement moyennant indemnité prévue par l'article 1511 du Code civil, ne porte pas atteinte à l'égalité en valeur du partage. Tout au plus, peut-on considérer qu'elle porte atteinte à l'égalité en nature¹. Ce type de clause s'analyse en une opération de partage, ce qui est d'ailleurs expressément confirmé par l'article 1514 du Code civil.

La clause proposée aux articles 1511 et suivants du code civil est une clause de prélèvement facultatif « moyennant indemnité ». Néanmoins, le prélèvement ne donne lieu à aucun paiement, mais s'impute sur les droits du bénéficiaire dans le partage de la communauté. Si les biens prélevés ont une valeur supérieure aux droits de cet époux, il doit verser une soulte. Selon l'article 1512, le contrat de mariage « peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement de la soulte éventuelle ». Le texte précise : « Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera fixée par le tribunal de grande instance ».

Enfin, si l'article 1511 prévoit que l'indemnisation a lieu suivant la valeur du bien au jour du partage, il est toutefois possible d'assortir la clause de prélèvement moyennant indemnité d'autres modalités d'évaluation de l'indemnité.

Délai pour opter

La loi ne fixe aucun délai au conjoint pour prendre parti. En revanche, une fois passé le délai de trois mois et quarante jours, les héritiers peuvent le contraindre de le faire. À compter du jour de la mise en demeure, l'intéressé a un mois pour se décider. La loi n'impose pas – ni ne suggère – les formes de la notification de sa décision. En tout cas, faute de réponse dans le mois suivant la mise en demeure, la faculté de prélèvement est caduque. Cette règle ne semble pas s'imposer aux époux, qui pourraient donc stipuler tout délai et formalisme applicable.

¹ M.Malaurie et L.Aynès, *Les régimes matrimoniaux*, 3^eéd. Defrénois, n°765

B – La « clause commerciale » : faculté d'attribution ou d'acquisition

Ce type de clause imaginée à l'origine par la pratique et validé par la loi du 13 juillet 1965¹, permet au conjoint survivant d'acquérir ou de se voir attribuer certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession. Le régime de la clause d'acquisition ou d'attribution est régi par les articles 1390 et suivants du Code civil.

La clause était dite commerciale car elle portait très souvent sur le fonds de commerce. Plus largement, elle avait initialement été pensée pour porter sur l'entreprise commerciale, l'exploitation agricole ou encore le logement du couple.

L'article 1390 du Code civil a également consacré la possibilité d'assortir cette clause d'une stipulation accessoire portant sur une promesse de bail. Ainsi, il est possible de prévoir, lorsque la clause commerciale porte sur une entreprise, que les héritiers auront l'obligation de consentir un bail si l'immeuble dans lequel ladite entreprise est exploitée dépend de la succession.



Attention

Cette clause est différente de toutes les autres clauses étudiées car elle ne porte pas sur un bien commun mais sur un bien propre ou personnel.

Elle est juridiquement qualifiée de pacte sur succession future autorisé par la loi (ce qui explique sa place dans le Code civil, à la suite de l'article 1389 énonçant le principe de la prohibition des pactes sur successions futures).

Précisons que la clause offre au conjoint une faculté. S'il ne l'exerce pas, les biens seront dévolus selon les règles ordinaires.

La clause prévue par l'article 1390 offre au conjoint survivant une alternative : acquérir ou se faire attribuer les biens dans le cadre du partage.

La question de savoir s'il exerce une faculté d'acquisition ou d'attribution dépend uniquement de sa situation au regard de l'indivision successorale :

- Si le conjoint est membre de l'indivision : il exercera une faculté d'attribution. Cette dernière s'intègre dans les opérations de partage et la valeur des biens s'impute sur les droits recueillis par le bénéficiaire dans la succession.
- Si en revanche, le conjoint est étranger à l'indivision (par exemple parce qu'il a été exhéredé ou qu'il a renoncé à la succession) : il exercera la faculté d'acquisition à titre onéreux.

¹ Antérieurement à la loi de 1965, la jurisprudence avait condamné ce type de clause comme constituant un pacte sur succession future. (Civ. 11 janv. 1933, DP 1933.1.10, S.1933.1.161 ; Civ 1^{ère} 12 déc. 1961 Bull civ. I n°603, D.1962 Somm.73)



Le mécanisme existe sous d'autres figures

On connaît d'autres possibilités du même type qui peuvent trouver leur source ailleurs que dans le contrat de mariage et qui sont liés au droit de l'indivision :

- ✓ Les attributions préférentielles légales qui trouvent leur source dans le Code civil, par exemple sur la résidence principale
- ✓ Les attributions préférentielles conventionnelles qui trouvent leur source dans un contrat comme lors d'une acquisition indivise, les co-acquéreurs prévoyant réciproquement un droit d'attribution préférentiel au survivant d'entre eux.

Le terme d'attribution vient de la notion d'attribution dans le cadre d'un partage.

Délai pour opter

L'exercice de l'option par le conjoint n'est pas enfermé dans un délai déterminé. Mais, comme en matière de prélèvement moyennant indemnité, passé le délai de trois mois et quarante jours, les héritiers peuvent le contraindre à prendre parti (C. civ., art. 1392). À compter du jour de la mise en demeure, l'intéressé a un mois pour se décider. Faute de réponse dans le mois suivant la mise en demeure, la faculté d'attribution ou d'acquisition est caduque. La qualification de pacte sur succession future limite ici les aménagements.

EXERCICE N°17

Irène et Benjamin souhaitent se marier sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils vous précisent qu'Irène est déjà propriétaire, seule, de leur résidence principale. Les futurs époux voudraient être propriétaires ensemble de leur toit et souhaitent protéger le survivant d'entre eux en lui assurant la propriété exclusive de cette maison.

Questions :

Que pouvez-vous leur conseiller ?

Réponses :

Chapitre III – Quid à la fin du mariage

Section 1 – Notion d'avantage matrimonial et sort des avantages matrimoniaux en cas de dissolution par divorce

A – Notion d'avantage matrimonial

Le Code civil ne contient aucune définition de l'avantage matrimonial.

Suivant la doctrine, ce sont « les enrichissements résultant au profit d'un époux et à l'encontre de l'autre du seul fonctionnement du régime matrimonial adopté ».

- Il s'agit d'un avantage prenant source dans la convention matrimoniale : dans le contrat de mariage initial ou par changement de régime ;
- Il concerne les biens communs ;
- Il s'applique dès le décès, avant le règlement de la succession ;
- Et il n'est pas constitutif d'une libéralité : il permet d'avantager le conjoint au-delà de la quotité disponible spéciale (QDS) sauf en présence d'enfant(s) non commun(s).

B – Sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce

La loi dispose qu'en cas de divorce, les avantages matrimoniaux sont, selon leur nature, maintenus ou au contraire révoqués automatiquement (C. civ., art. 265).

Avantage matrimonial prenant effet pendant le mariage

Un tel avantage matrimonial, comme l'apport à communauté, n'est pas remis en cause par le divorce. Il subsiste donc malgré le divorce.

Cependant une clause spécifique peut être insérée dans la convention matrimoniale pour anticiper cette difficulté, elle est étudiée au paragraphe C ci-après (« clause alsacienne »).

Avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du mariage

Un tel avantage matrimonial, comme une clause de préciput ou d'attribution inégale est automatiquement révoqué en cas de divorce par l'effet de la loi.

Cependant, depuis la loi n° [2024-494](#) du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, entrée en vigueur le 2 juin 2024, le texte prévoit désormais que ces avantages peuvent néanmoins être maintenus par la volonté des époux :

- Constatée dans la convention de divorce ;
- Par le juge lors du prononcé du divorce ;
- Exprimée dans la convention matrimoniale.

C'est ce dernier point qui constitue l'objet de la modification opérée par la loi n° [2024-494](#) du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.

Cette modification est d'une grande importance car elle marque le retour au principe de liberté des conventions matrimoniales. Elle permet de prévoir et sécuriser des conventions matrimoniales très travaillées, personnalisées et prenant beaucoup de liberté vis-à-vis des modèles proposés par le Code civil.

Si les régimes à liquidation alternative avaient pris de l'ampleur, les clauses protégeant le survivant en cas de décès étant très usitées, l'anticipation des effets du divorce sur la liquidation du régime matrimonial s'était limitée à la clause alsacienne dans les régimes

communautaires (et séparation de biens avec société d'acquêts). Les décisions de la Cour de cassation en matière de participation aux acquêts (condamnant les clauses d'exclusion de biens professionnels¹) avaient fait fuir les éventuels candidats à la participation aux acquêts.

Hier en voie de disparition, nous devrions assister à un renouveau de ce régime matrimonial qui peut désormais permettre tout à la fois de protéger le conjoint et de doser, limiter, voire annihiler la créance de participation en cas de divorce.

Cette loi nouvelle étant applicable à compter du 2 juin 2024, elle apporte également une pérennité bienvenue et espérée aux conventions matrimoniales préexistantes qui stipulaient ce type de clauses (si toutefois la procédure de divorce n'avait pas été entamée avant son entrée en vigueur).

C – La clause de reprise ou clause alsacienne

La clause qu'il convient de prévoir dans le contrat est la clause dite « alsacienne » ou clause de reprise des apports.

Cette clause organise une alternative en matière de liquidation du régime matrimonial :

- en cas de décès, l'apport à communauté n'est pas remis en question,
- et en cas de divorce, l'époux apporteur peut exercer la reprise du bien qu'il avait apporté.

Plus largement, cette clause peut concerner tous les biens qui auraient été propres sous le régime légal ou certains d'entre eux seulement, selon la convention des parties.

Généralement, les époux peuvent reprendre tous ces biens. Mais il semble également possible de limiter le champ d'application de la clause à certains biens seulement parmi ceux figurant ci-dessus.

Cette reprise est généralement prévue en nature ou, si les biens ont été aliénés, sur le prix ou la valeur d'aliénation.

Elle peut donc être prévue dans tout régime communautaire : communauté réduite aux acquêts, de meubles et acquêts ou encore communauté universelle. En cas de divorce, elle permettra aux époux de reprendre les biens qui leur auraient été propres sous la communauté légale.

¹ Voir la partie consacrée à ce régime matrimonial.

Pour la petite histoire ...

Ces clauses sont nées dans l'Est de la France. Entre 1900 et la fin de la Première Guerre Mondiale, l'Alsace-Lorraine n'était plus soumise au principe de l'immutabilité des régimes matrimoniaux, inconnue en droit allemand. De plus, le droit allemand instituait une réserve pour le conjoint survivant.

Le 1^{er} juin 1924, la loi d'introduction de la législation française, donna la possibilité aux époux alsaciens-mosellans dont le régime était jusque-là soumis au droit local, d'opter pour l'un des régimes français. À défaut d'option dans le délai d'un an, leur régime serait de plein droit remplacé par le régime français le plus ressemblant. Entre 1924 et 1925, de nombreux époux optèrent pour la communauté universelle dans un but successoral, le statut du conjoint survivant en droit français à cette époque étant très peu protecteur. Ils prévoyaient alors une attribution intégrale de la communauté au survivant et privaient les héritiers du prémourant de la faculté de reprise (vue *supra*).

La génération suivante d'alsaciens-mosellans opta elle aussi pour ce régime *ab initio*. Mais le choix d'une communauté universelle dès le début du mariage doit compter avec le risque d'un divorce. C'est pourquoi la pratique développa les clauses « de sauvegarde » ou « clauses alsaciennes », en référence à la région où elles ont vu le jour.

Ce n'est qu'à la fin des années 1980 que la question de sa validité est soumise à des magistrats.

D'abord invalidée en première instance par les juges strasbourgeois¹, la clause alsacienne sera ensuite reconnue valable par la Cour d'appel de Colmar².

De nouveau discutée sur sa validité au lendemain de la réforme du divorce du 26 mai 2004³, elle sera consacrée à l'occasion de la réforme du droit des successions et libéralités du 23 juin 2006⁴.

Section 2 – En cas de décès : attention à l'action en retranchement des avantages matrimoniaux

A – Définition de l'action en retranchement

Les avantages matrimoniaux « *ne sont points regardés comme des donations* »⁵ et ne sont donc pas réductibles pour atteinte à la réserve ... sauf s'il existe un enfant non commun !

En présence d'enfant(s) exclusivement commun(s), l'utilisation des avantages matrimoniaux ne connaît pas de limite. Cette stratégie est celle qui permet de transmettre le plus au conjoint en s'affranchissant des règles de la réserve héréditaire au premier décès. Les enfants communs ne peuvent utiliser l'action en retranchement et sont donc impuissants face aux avantages conférés au survivant par la voie matrimoniale. Le législateur considère

¹ TGI Strasbourg, 17 sept. 1987, JCP N 1989. II. 109, note Simler – TGI Strasbourg, 24 mars 1992, JCP 1993. II. 22108 [2^e esp.], note Simler.

² CA Colmar, 16 mai 1990, JCP N 1991. II. 17 [1^{re} esp.], note Simler.

³ Rédaction de l'article 265 issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.

⁴ Rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, ajoutant un alinéa à l'article 265 *in fine*.

⁵ C. civ., art. 1527.

(à tort nous semble-t-il) qu'ils feront valoir leurs droits dans la succession de leur deuxième parent.

Ce même argument ne peut valoir pour l'enfant non commun (celui qui est l'enfant du défunt mais non du conjoint survivant). L'enfant non commun peut agir sur le fondement de l'action en retranchement et demander au conjoint survivant qu'il rende compte de ces avantages comme s'ils constituaient des donations, par hypothèse hors part successorale et imputables sur la quotité disponible spéciale du conjoint survivant (C. civ., art. 1094-1).

Si ces avantages excèdent la quotité disponible spéciale, alors l'atteinte à la réserve héréditaire est caractérisée et le conjoint survivant devra s'acquitter d'une indemnité de réduction (C. civ., art. 924). Les enfants reçoivent alors tout ou partie de leur réserve en valeur, par la perception d'une somme d'argent.

L'action en retranchement a donc pour finalité de protéger la réserve des enfants non issus des deux époux, leur permettant d'exercer leur réduction à l'encontre du conjoint survivant bénéficiant d'un avantage matrimonial.

B – Titulaires de l'action en retranchement

La finalité de l'action explique qu'elle ne soit ouverte qu'aux enfants non communs.

Dès lors que le défunt laisse un enfant non issu de son union avec son conjoint survivant, l'action est ouverte à ce descendant.

Le type de filiation est sans incidence sur cette question.

Si le défunt laisse un enfant que l'on pourrait qualifier d'adultérin, mais avec lequel le lien de filiation est légalement établi, ce dernier peut agir en retranchement puisqu'il a la qualité d'héritier réservataire de son auteur.

A l'inverse, l'enfant du défunt, adopté par son conjoint survivant, ne peut pas se prévaloir de l'action en réduction puisqu'en tant qu'adopté, il a la qualité d'héritier réservataire du conjoint survivant adoptant (et ce, que l'adoption soit simple ou plénière)¹.

C – Le calcul de l'action en retranchement

Pour savoir si l'avantage matrimonial est réductible et dans quelle proportion, il convient d'abord d'évaluer ledit avantage pour le réunir fictivement comme une donation (art. 922 C. civ.) puis de l'imputer sur la quotité disponible spéciale conformément à l'article 1527 du Code civil faisant renvoi à l'article 1094-1 du même code.

1 – Évaluer l'avantage matrimonial

Prenons un exemple : s'agissant de l'adoption d'une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale, l'avantage matrimonial² résulte de plusieurs éléments :

¹ CA Orléans, 29 avr. 2002 : JurisData n°2002-183354 ; Cass. Civ. 1re, 7 juin 2006: JurisData n°2006-033849 ; Cass. Civ. 1re, 11 févr. 2009 : JurisData n°046981.

² Nous précisons ici, que même dans l'hypothèse où le droit de reprise n'aurait pas été exclu par la convention matrimoniale et où il aurait été exercé par les enfants, la question de l'action en retranchement se poserait tout de même. En effet, l'avantage matrimonial résulterait dans ce cas uniquement de la clause d'attribution intégrale, à l'exclusion des apports des époux qui, par hypothèse, auraient fait l'objet d'une reprise par les héritiers.

- l'adoption d'une communauté universelle ayant pour effet d'élargir le périmètre de la communauté,
- la clause d'attribution intégrale qui aboutit à ce que la communauté ne se partage pas par moitié mais profite pour le tout au survivant.

La question de l'évaluation de l'avantage matrimonial n'étant pas réglée par les textes, la doctrine a dégagée le principe suivant : pour déterminer les avantages matrimoniaux, il faut comparer les résultats obtenus en liquidant la communauté suivant les stipulations du contrat de mariage et ceux qui seraient obtenus si les époux avaient été soumis au régime légal de la communauté d'acquêts.

La différence entre ces deux liquidations représente l'avantage matrimonial¹.

C'est donc au moment du décès de l'époux qu'il faut se placer pour évaluer l'avantage matrimonial.

2 – L'avantage est-il excessif ?

Les avantages matrimoniaux sont assimilés à des donations pour la constitution de la masse de calcul de la réserve (art. 922 C. civ.) et sont donc d'abord réunis fictivement puis imputés comme tels.

Concernant la réunion fictive, l'évaluation de l'avantage matrimonial se fait au jour de l'ouverture de la succession de l'époux prémourant et d'après l'état des biens à cette date, correspondant, en l'espèce, à la date de dissolution de la communauté².

Quant à l'imputation de l'avantage matrimonial, elle est faite à la date de la convention matrimoniale, date à laquelle il a été concédé. Certes, l'avantage matrimonial prend parfois effet au décès de l'époux, mais il a pour origine le contrat de mariage (ou le changement de régime matrimonial)³.

Enfin, l'avantage matrimonial étant traité comme une libéralité entre époux, son imputation devrait être faite sur la quotité disponible spéciale entre époux, selon la modalité qui a été choisie par le conjoint survivant.

3 – La réduction

Comme nous l'avons dit, l'action dite « en retranchement » n'est rien d'autre qu'une action en réduction.

Dès lors, et conformément à l'article 922 du Code civil, il convient de prendre en compte la valeur des biens à l'époque du décès pour déterminer l'existence d'une atteinte à la réserve. Il s'agit en fait de déterminer la portion excessive de la libéralité : fraction réductible/valeur totale de la libéralité.

¹ FLOUR et CHAMPENOIS, *Les régimes matrimoniaux*, Armand Colin, n°724 ; J. Cl. Civil Code, V° Art. 1527, Fasc. Unique, n°s 22 et s. ; JCP N 1999, « *L'avantage matrimonial : remarques d'ordre pratique sur la communauté universelle* », par M. GRIMALDI. Pour un exemple chiffré : N. LEVILLAIN et M.-C. FORGEARD, *Liquidation des successions*, Dalloz Référence 2013-2014, n°s 314-21 et s.

² F. LUCET, *Des rapports entre régimes matrimoniaux et libéralités entre époux*, thèse, Paris II, 1987, p. 560 ; J. Cl. Civil code, V° Art. 1527, n°33 et s. ; Actes pratiques et stratégie patrimoniale, 2008, art. 11, « *Notion et évaluation des avantages matrimoniaux* », par C. BRENNER ; Defrénois 1998, art. 36859, par F. LUCET.

³ Voir note précédente.

L'indemnité de réduction n'étant due qu'au moment du partage, elle sera alors calculée selon la fraction excessive de la libéralité (ou de l'avantage matrimonial en l'espèce), évaluée au jour du partage (conformément à l'art. 924-2 C. civ.).

L'action en retranchement étant une action en réduction, l'époux survivant peut, comme le « gratifié », opter pour la réduction en nature conformément à l'article 924-1 du Code civil. Lorsque la réduction est opérée en nature, elle peut faire naître, selon la quotité disponible spéciale choisie par l'époux survivant, une indivision en nue-propriété ou en propriété sur l'ensemble des biens entre le conjoint survivant et les enfants (si le conjoint opte pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou pour la quotité disponible ordinaire).

Quoi qu'il en soit, dès lors que la liquidation dressée avec l'accord des parties établit l'existence d'une indemnité de réduction, alors celle-ci sera due.

Comme tout créancier, le créancier de l'indemnité de réduction peut accorder des délais de paiement au débiteur mais également demander la mise en place de toute sûreté conventionnelle, réelle ou personnelle.



A savoir

Précisons enfin une possibilité offerte depuis la loi du 23 juin 2006. S'il existe une entente familiale, il est possible de sécuriser au moins temporairement cette stratégie de protection du conjoint avec la signature, en parallèle de la convention de mariage, d'un acte dans lequel les enfants s'interdisent de contester ces dispositions au décès de leur auteur, reportant leur action en retranchement au décès du survivant des époux (C. civ., art. 1527 al. 3). Les droits des enfants du premier défunt sont alors différés dans le temps et ils agiront contre les héritiers du survivant. La situation est pérennisée pour le survivant sa vie durant.



Quid de la vente d'un bien par le survivant ?

L'article 924-4 du Code civil prévoit que lorsque le débiteur d'une indemnité de réduction est insolvable et qu'il a aliéné le bien reçu à titre gratuit, le créancier peut poursuivre le bien entre les mains du tiers acquéreur.

Ainsi, si le conjoint survivant devait vendre un bien, il conviendrait de distinguer plusieurs situations :

- ✓ La succession du prémourant a été liquidée au plan civil et :
 - Les avantages matrimoniaux n'excédaient pas la quotité disponible spéciale (donc le conjoint n'avait aucune indemnité de réduction à verser)
 - Ou les avantages matrimoniaux excédaient la quotité disponible spéciale, le conjoint était débiteur d'une indemnité de réduction et s'en est acquittéDans ce cas, le conjoint peut vendre le bien et il n'y a rien de particulier.

- ✓ La succession du prémourant :
 - N'a pas été liquidée au plan civil, de sorte que l'on ne sait pas si les avantages matrimoniaux sont « retranchables »
 - Ou a été liquidée au plan civil et a fait ressortir le caractère excédentaire des avantages matrimoniaux, constatant l'existence d'une indemnité de réduction non encore réglée par le conjoint survivant

Dans ce cas, il conviendra d'obtenir le consentement préalable des enfants du défunt, s'interdisant tout recours contre le tiers détenteur (art. 924-4 al. 2 C. civ.) et ce, afin de garantir une propriété pérenne à l'acquéreur. En règle générale, le prix de vente perçu par le conjoint servira alors à régler l'indemnité de réduction.

Ce consentement préalable n'est pas une condition de validité de la vente. En théorie, le conjoint a tous pouvoirs pour passer cet acte seul. Mais en pratique, il est inconcevable de laisser un acquéreur prendre ainsi le risque de se faire évincer !

Section 3 – L'indignité matrimoniale

Alors que le droit successoral déclarait indigne de succéder celui qui est condamné à une peine criminelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ou encore celui qui a commis à son encontre des violences, rien de tel n'existait en matière matrimoniale. Le conjoint, survivant et reconnu coupable du meurtre de son époux, pouvait bénéficier des avantages matrimoniaux prévus par le couple dans la convention matrimoniale, tels qu'une attribution intégrale de la communauté.

Pour mettre enfin un terme à cette incohérence législative, la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 qui avait pour objectif d'assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, a instauré une déchéance des avantages matrimoniaux, largement empreinte de l'indignité successorale. Ces nouvelles dispositions figurent désormais au Code civil sous les articles 1399-1 et suivants.

Ce nouveau dispositif de « déchéance matrimoniale » est donc distinct des notions traditionnelles d'indignité successorale ou d'ingratitude en matière de libéralités. Il est

applicable aux clauses des conventions matrimoniales favorisant un époux lors de la dissolution du régime matrimonial. Ce mécanisme se rapproche cependant de l'indignité, notamment en établissant des cas de déchéance automatiques ou facultatifs selon la gravité des actes (C. civ., art. 1399-1 et s.).

La déchéance automatique s'applique de plein droit en cas de condamnation pénale de l'époux comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner (C. civ., art. 1399-1).

La déchéance facultative pourra s'appliquer, après une demande en justice, au conjoint reconnu coupable de faits de tortures, viol, agressions sexuelles, faux témoignage, entre autres (C. civ., art. 1399-2). Cette décision peut être demandée par un héritier, l'autre époux ou le ministère public dans un délai de six mois, mais la législation exclut les légataires et autres ayants droit du champ des requérants (C. civ., art. 1399-3).

La réforme prévoit des mesures complémentaires, notamment la restitution des fruits et revenus par l'époux déchu (C. civ., art. 1399-4) ou l'établissement d'un inventaire (sans précision sur les frais). Il est également prévu que lorsqu'une clause de la convention matrimoniale stipule l'apport à la communauté de biens propres de l'époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l'époux apporteur (C. civ., art. 1399-5).

Enfin, la loi s'applique aux conventions matrimoniales déjà conclues avant l'entrée en vigueur de la loi et exclut toute faculté de « pardon », pour tenir compte des situations de violence, bien que cette exclusion crée une différence notable avec le régime de l'indignité successorale.

Partie IV – AUTRES RÉGIMES CONVENTIONNELS

Chapitre I – Séparation de biens

Section 1 – Séparation de biens « pure et simple »

A – Le patrimoine des époux

La séparation de biens repose sur le principe d'indépendance entre les époux. Ils n'ont aucun patrimoine commun, sauf dans le cas de l'adjonction d'une société d'acquêts qui sera étudié *infra*. Chaque époux conserve la pleine propriété de ses revenus, de tous les biens existants avant le mariage et de tous ceux acquis par lui pendant le mariage.

1 – Actifs

Les époux détiennent alors deux catégories de biens :

✓ les biens divis

Chaque époux est privativement propriétaire des biens qu'il possède au jour du mariage et des biens qu'il acquiert individuellement au cours du mariage à titre gratuit ou onéreux. A ce titre, il est conseillé de prévoir dans le contrat de mariage des présomptions de propriété, car il est parfois difficile d'apporter des preuves sur la propriété de certains biens dix ou

quinze ans plus tard. A défaut, l'article 1538 du Code civil énonce une présomption de propriété indivise pour moitié entre les époux lorsqu'aucun des époux n'est en mesure d'apporter la preuve d'une propriété exclusive.

✓ les biens indivis

Les époux peuvent réaliser des acquisitions conjointes. Lorsque les époux procèdent ensemble à une acquisition, ils sont juridiquement dans la situation de l'indivision et chaque époux est propriétaire du bien à proportion de la part indiquée dans l'acte d'acquisition. Dans l'hypothèse où les époux n'ont pas mentionné dans l'acte la proportion financée par chacun, ils sont réputés propriétaires chacun pour moitié. Ainsi le logement familial est souvent acquis en indivision.

2 – Passif

Selon l'art. 1536 du Code civil chaque époux reste seul tenu des dettes nées de sa personne. Les créanciers d'un conjoint ne peuvent saisir les biens de l'autre conjoint sauf si ce dernier a accepté par convention d'être solidairement tenu (dans l'hypothèse d'un prêt par exemple).

En outre, certaines dettes sont solidaires en raison de leur nature conformément à l'article 220 du Code civil, c'est-à-dire les dettes d'entretien du ménage et d'éducation des enfants (sous les exceptions déjà étudiées dans le régime primaire, voir page 26).

Par ailleurs, l'époux est engagé par les dettes contractées par son conjoint auquel il a donné mandat de gérer ses biens personnels (mandat qui peut être tacite). Selon la jurisprudence l'exploitation en commun d'une entreprise entraîne l'obligation au passif des deux époux¹.

Séparation de biens et fiscalité : quid des impôts ?

○ Contribution à la dette

Suivant une jurisprudence constante², la dette d'impôt sur le revenu ne constitue pas une charge du mariage de l'article 214 du Code civil. Chacun des époux supporte seul l'impôt dû à raison de ses revenus.

Seule la méthode de calcul de l'impôt soulève une difficulté pratique lorsque les époux ont des revenus peu comparables, et ce du fait du calcul par part et de la progressivité de l'impôt³. Faut-il proportionner l'impôt dû aux revenus de chaque époux ou recalculer l'impôt distinctement pour chacun pour déterminer la part de l'impôt qui constitue une dette personnelle pour chacun ? Il n'existe pas de jurisprudence sur ce point.

○ Obligation à la dette



¹ Cass. 1^{ère} civ., 1^{er} février 1977 : D.1978.309 : une femme exploitant un domaine dont elle était seule propriétaire est tenue d'une dette contractée par son mari dans l'intérêt de ce domaine.

² Civ. 1^{ère} 22 févr. 1978, D. 1978. 602, note D. Martin ; Civ. 1^{ère}, 19 mars 2002, n° 00-11.238 ; Civ. 1^{ère}, 25 juin 2002, n° 98-22.882 ; Civ. 1^{ère}, 30 oct. 2006, n° 03-19.317 ; Cass. civ. 1^{ère}, 5 nov. 2014, n°13-22.605.

³ F. Douet, « Les époux face à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux », Gaz. Pal. 2015, p. 11.



Le droit fiscal pose le principe d'une solidarité fiscale entre les époux (et partenaires de PACS) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et l'impôt sur la Fortune Immobilière¹.

En cas de séparation, les époux peuvent demander une imposition séparée². Ils ont d'ailleurs intérêt à le faire sans tarder s'ils ne veulent plus être solidaires dans le paiement de ces impôts. La solidarité prend fin pour les impôts nés à compter de cette demande. Par exemple, pour les impôts dont le fait générateur s'apprécie au 1^{er} janvier de l'année N, les époux ne seront plus solidaires si leur résidence séparée a pris effet en N-1. Pour l'impôt sur le revenu, ils seront solidairement tenus pour les revenus de l'année N-1 mais plus pour ceux de l'année N.

B – Les pouvoirs sur les biens

Chaque époux gère et dispose librement de ses biens personnels conformément à l'article 1536 du Code civil. Le régime de séparation de biens connaît une seule exception à cette règle, le logement familial et les meubles meublants qui le composent ne peuvent être cédés par l'époux propriétaire sans le concours de son conjoint.

Nous renvoyons sur ce point à nos développements page 28.

S'agissant des biens indivis, leur gestion est prévue aux articles 815 et suivants du Code civil. On distingue :

- Les actes de conservation : Pour maintenir en bon état de conservation les biens indivis, chacun des indivisaires peut prendre, seul, c'est-à-dire sans l'accord de ses coindivisaires, les mesures nécessaires à la conservation des biens même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence (C. civ., art. 815-2 al.1er).
- Les actes d'administration : la remise d'un mandat général d'administration à l'un ou plusieurs indivisaires ou à un tiers, la vente des meubles indivis pour acquitter le passif ou enfin la conclusion ou le renouvellement des baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal sont soumis à la règle de la majorité des deux tiers (C. civ., art. 815-3 al.1er).
- Les actes de disposition : L'unanimité, c'est-à-dire le consentement de tous les indivisaires, est par contre de mise d'une part, pour les actes de disposition et d'autre part, pour ceux qui ne ressortissent pas de l'exploitation normale des biens indivis (C. civ., art. 815-3 al.3).

Enfin, les époux peuvent prévoir une convention d'indivision au sens des articles 1873-1 du Code civil.

¹ En vertu du I de l'art. 1691 *bis* du CGI, les époux et les partenaires de PACS sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune et de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. L'art. 1723 *ter*-OO B prévoit également que les époux et partenaires de PACS sont solidaires pour le paiement de l'IFI.

² Art. 6, 4, b du CGI.

C – La dissolution du régime

Chaque époux conserve la propriété de ses biens personnels. Il n’y a donc en théorie pas de liquidation sauf éventuellement des créances entre époux. Concernant les créances entre époux, nous renvoyons à nos développements page 86.

En réalité, la dissolution implique également la liquidation des indivisions conventionnelles existant entre les époux.

Section 2 – Aménagements divers en séparation de biens

A – Modification des règles relatives aux créances entre époux

Comme en matière de récompenses, les dispositions relatives aux créances entre époux ne sont pas d’ordre public et peuvent librement être aménagées.

On notera bien sûr, l’utilité que peut revêtir une clause renvoyant au régime de l’article 1469 dans son intégralité et non seulement au troisième alinéa comme prévu par l’article 1479 du Code civil.

On sait en effet que lorsque la dépense a permis une opération d’investissement et que le profit subsistant est inférieur à la dépense faite, la créance entre époux se limiterait, compte tenu du renvoi au seul alinéa troisième de l’art. 1469, au profit subsistant et non à la plus faible des deux sommes comme tel serait le cas pour une récompense.

Un renvoi aux règles de l’article 1469 dans son intégralité permet de résoudre la difficulté.

Au contraire, on peut également prévoir une indemnisation au nominal.



Il n’est pas toujours possible de savoir si ces aménagements constitueront un avantage pour l’un ou l’autre des époux mais ils peuvent avoir une vertu simplificatrice pour la liquidation à la fin de l’union.

B – La « clause commerciale » : faculté d’attribution ou d’acquisition

Nous renvoyons à nos développements page 94.

C – La contribution aux charges du mariage

La notion de contribution aux charges du mariage a été étudiée supra page 23.



Attention

Il convient de mettre ici en exergue une difficulté spécifique aux époux mariés en séparation de biens : la question du financement de l’immobilier de jouissance de la famille et la notion de contribution aux charges du mariage.

Pour mieux comprendre, prenons l’hypothèse suivante : un couple, marié en séparation de biens pure et simple, acquiert sa résidence principale dans l’indivision, à concurrence de moitié chacun. En principe, chacun aurait dû financer à concurrence de moitié. Il se trouve qu’à la fin du mariage, lorsque les époux divorcent, c’est Madame qui a intégralement financé en acquittant seule les mensualités de prêt.

La question est de savoir quels sont les droits de Madame.

Le principe : droit à indemnisation pour l'indivisaire qui contribue au-delà de la quote-part lui incombant

Tout d'abord, rappelons que le fait que l'épouse ait financé seule les mensualités du prêt n'affecte pas le titre¹ : le bien est indivis entre les époux pour moitié chacun. Le droit de propriété est donc indépendant du financement.

En revanche, l'épouse ayant contribué au-delà de la part qui lui incombait, elle a droit à indemnisation. Selon la jurisprudence, celle-ci relève des règles de l'indivision (art. 815-13 C. civ.) et non des créances entre époux (art. 1543 C. civ.)².

L'incidence du mariage

L'objet de la contribution aux charges du mariage selon la jurisprudence

L'article 214 du Code civil impose aux époux de contribuer aux charges du mariage.

Le périmètre des charges du mariage est habituellement circonscrit aux dépenses d'entretien du ménage et d'éducation des enfants, incluant la nourriture, le logement (loyer), l'habillement, la santé ou encore les frais de scolarité³.

Mais les dépenses d'investissement (mensualité du prêt souscrit pour l'acquisition du logement) sont depuis quelques années, elles aussi, traitées par la jurisprudence comme des charges du mariage.

La jurisprudence considère que le remboursement du prêt souscrit pour le financement de l'acquisition du logement de la famille constitue une charge du mariage.

En effet, la jurisprudence interprète de manière relativement large la notion de charges du mariage, l'admettant notamment en cas de financement du logement de la famille⁴ ou d'une résidence secondaire des époux⁵. Divers arrêts ont d'ailleurs été rendus à ce sujet en 2013⁶ et ont donné lieu à un certain nombre de commentaires. La Cour de cassation a rendu depuis cette date plusieurs décisions⁷ toujours dans le même sens considérant que le

¹ Même lorsque le financement a été exclusivement assumé par un seul des coacquéreurs, l'indivision existe et l'acquisition est faite par les acquéreurs conjointement et indivisément conformément aux stipulations de l'acte d'acquisition : Cass. Civ. 1re, 17 janvier 1995: Bull3 civ. I, n°35 ; Cass. Civ. 1re, 19 mars 2008: JurisData n°2008-043231. Voir également Rép. Civil Dalloz, V° Indivision, n°120 ; J. Cl. Not. Form., V° Indivision, Fasc. 10, n°38.

² Cass. civ. 1^{re}, 6 févr. 1996, Juris Data 1996-000601 ; Cass. civ. 1^{re}, 14 oct. 2009, pourvoi n°08-17.943.

³ J. Flour et G. Champenois, *Les régimes matrimoniaux*, Armand Colin, 2^e éd., n°62 ; F. Terré et Ph. Simler, *Droit civil, Les régimes matrimoniaux*, Dalloz, 2^e éd., n°51.

⁴ Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, n° 01-15094 ; Cass. Civ. 1re, 14 mars 2006, n° 05-15980.

⁵ Cass. Civ. 1re, 20 mai 1981 ; JCP N n°12 du 20 mars 1998, p. 435 par V. BREMOND ; S. DAVID et A. JAULT, *Liquidation des régimes matrimoniaux*, n° 313-17 et s., Dalloz référence, éd. 2013-2014.

⁶ Civ. 1^{ère}, 15 mai 2013, pourvoi n° 11-26933 : Dr. Fam. 2013, comm. n° 10 par B. BEIGNIER ; RJPF 2013/7-8/19, note F. VAUVILLE, RTD Civ. 2013, 107, note J. REVEL ; AJ Familles 2013, p. 383, note S. BLANC-PELISSIER ; JCP 2013, G, doct. 1323, note G. WIEDERKEHR – Civ. 1^{ère}, 12 juin 2013, pourvoi n° 11-26748 – Civ. 1^{ère} 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21892 : RJPF 2013/12/5, note J. VASSAUX ; D. 2013, p. 2682, note A. MOLIERE ; RTD civ. 2014, p. 697, note VAREILLE ; G. CHAMPENOIS, « Quelques observations sur le financement du logement familial indivis par des époux séparés de biens », in Mél. LE GUIDEDEC, LexisNexis, mars 2014 ; A. KARM, « Financement du logement de la famille et contribution des époux séparés de biens aux charges du mariage », in Mél. LE GUIDEDEC, LexisNexis, mars 2014.

⁷ Plus récemment : Cass. 1^{re} civ., 7 févr. 2018, n°17-13.276 ; Cass. 1^{re} civ., 21 nov. 2018, n°17-26.546 ; Cass. 1^{re} civ., 3 oct. 2018, n°17-25.858 ; Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n°18-14.571.

remboursement du prêt dont l'objet est le financement de la résidence principale constitue une charge du mariage de l'article 214 du Code civil¹. Seul l'immobilier locatif a été exclu².

Or, une telle qualification est d'importance puisqu'en principe elle interdit tout remboursement au titre de ladite dépense, sauf l'hypothèse d'une contribution excédentaire. L'on peut d'ores et déjà noter que le financement du bien n'est plus le corolaire de la quote-part de propriété indivise mais de la faculté contributive de l'époux aux charges du mariage. Pour le dire autrement, le financement n'incombe plus aux époux dans les mêmes proportions :

- chacun devait au départ financer selon sa quote-part indivise dans la propriété
- désormais, suivant ces jurisprudences, chacun doit financer à proportion de ses facultés contributives (généralement les revenus).

La question s'est déplacée sur le terrain de la contribution aux charges du mariage. Il s'agit cette fois de savoir si celui qui a payé plus qu'il n'aurait dû (au regard de ses facultés respectives) peut obtenir un remboursement du trop versé.

La sur-contribution aux charges du mariage et l'impact des clauses du contrat de mariage

La question soulevée est celle d'un recours en sur-contribution. L'époux (ou l'épouse en l'espèce) ayant supporté seul les échéances de prêts peut-il prétendre à répétition partielle de ces sommes au motif qu'il aurait contribué au-delà de ce qui lui incombait ? La réponse est en principe affirmative³ et la difficulté est alors une difficulté pratique qui consiste en l'administration de la preuve. L'époux devra prouver qu'il a cumulativement payé la part de son conjoint et participé aux autres charges quotidiennes du ménage⁴.

Enfin, force est de constater que la rédaction des conventions matrimoniales peut également avoir une lourde incidence sur cette question du recours en sur-contribution. Les clauses relatives à la contribution impactent généralement la charge de la preuve sinon même la possibilité d'obtenir une telle répétition.

Il n'est en effet pas rare que le contrat de séparation de biens comprenne une clause du type de celle qui pouvait être proposée au JurisClasseur⁵ :

«Les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre.»

Une telle clause fait généralement obstacle à l'établissement de comptes entre époux et à plus forte raison s'il était retenu qu'elle constitue non une présomption simple mais une

¹ Par exemple : Cass. civ. 1^{re}, 5 nov. 2014, n°13-23.557 : AJ fam. 2015, p. 61, comm. J. CASEY.

² Cass. 1^{re} civ., 5 oct. 2016, n°15-25.944.

³ Cass. 1^{re} civ., 16 janv. 2019, n°18-10.459.

⁴ Cass. 1^{re} civ., 20 mars 2019, n° 18-14.571.

⁵ J.-Cl. Not. Form., V° *Contrat de mariage*, Fasc. 35 (séparation de biens), Formule 1.

présomption irréfragable¹. Lorsque les magistrats considèrent que la clause constitue une présomption irréfragable, alors l'époux qui a financé seul l'immeuble indivis constituant le logement de la famille n'aurait fait qu'exécuter son obligation de contribution aux charges du mariage et serait privé de tout recours contre son conjoint à ce titre.

En synthèse, ce qu'il faut retenir de l'ensemble de ces jurisprudences :

- Elles concernent tout l'immobilier de jouissance du couple : résidence principale, secondaire, de vacances, etc ;
- L'immobilier locatif n'est pas concerné ;
- Elles concernent également le bien acquis dans l'indivision entre les époux mais encore le bien « mis au seul nom » de l'un d'eux ;
- Les clauses du contrat de mariage peuvent être déterminantes.



Solutions pratiques

✓ Pour les personnes déjà mariées et avec un contrat prévoyant une clause de présomption de contribution aux charges du mariage

La solution ne peut exister que si les époux sont parfaitement d'accord sur la qualification de créance fondée sur l'article 815-13 du Code civil, vous ne pouvez que les inviter à formaliser cet accord dans une convention, ce qui évitera tout litige ultérieur sur ce point.

En effet, selon nous, une telle convention fera obstacle à la qualification de contribution aux charges du mariage et ce, malgré la jurisprudence récente en la matière. Les arrêts en question ne concernent précisément que des affaires où le litige est né du fait, qu'une fois la rupture consommée, les ex-époux ne s'accordaient plus sur la qualification des flux financiers intervenus pendant le mariage.

En conséquence, cette jurisprudence n'exclut pas, selon nous, que les époux règlent en amont la difficulté en régularisant une convention.

Par ailleurs, une telle convention n'obéit à aucune règle de forme puisqu'il ne s'agit pas d'une modification du régime matrimonial mais plutôt d'une interprétation des parties sur les clauses de leur contrat de mariage.

✓ Pour les couples qui souhaitent adopter le régime de la séparation de biens

Le notaire qui reçoit les futurs époux pour la mise en place de leur contrat de mariage doit avertir ses clients de l'existence et des conséquences de ces jurisprudences.

Comme le dénoncent de nombreux commentateurs, c'est l'esprit du régime séparatiste lui-même qui s'en trouve bouleversé.

Aujourd'hui les époux doivent prendre parti sur ce point dès leur convention matrimoniale.

Parce qu'ils ne souhaitent pas que les dépenses d'investissement – même relatives au logement de la famille – soient qualifiées de charges du mariage et tiennent à ce que des comptes soient établis en fin de régime.

¹ En faveur du caractère non irréfragable de la présomption : Cass. Civ. 1^{ère}, 3 mars 2010, n°09-11005. En faveur du caractère irréfragable de la présomption Civ. 1^{ère} 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21892 ; Cass. Civ. 1^{ère}, 16 sept. 2014, n°13-18.935 : AJ fam. 2014, p. 568, note P. HILT ;

Parce qu'ils savent également que la jurisprudence peut évoluer et qu'en contractant aujourd'hui connaissance prise de ces arrêts, ils ne souhaitent pas que le silence de leur convention matrimoniale sur ce point puisse finalement conduire à une solution toute autre le jour venu de la dissolution de l'union.

Se pose alors la question de l'aménagement du régime matrimonial en matière de contribution aux charges du mariage.

Deux possibilités sont envisageables selon la volonté des époux :

- Ils peuvent prévoir l'inclusion des dépenses d'investissement (par exemple la prise en charge du remboursement des mensualités du prêt) dans les charges du mariage, et ce, en le limitant au logement de la famille ou en l'étendant aux autres logements, immobilier de jouissance¹.
- A l'inverse, ils peuvent vouloir exclure ces dépenses de la notion de charges du mariage. Il conviendrait alors de préciser dans le contrat de mariage ce que recouvre la notion de charges du mariage ou plutôt de définir ce qu'elle ne recouvre pas.

Des auteurs² proposent des clauses prévoyant l'inclusion ou l'exclusion des dépenses d'investissement dans les charges du mariage.

Notons toutefois que pour d'autres³, ces clauses restreignant le périmètre des charges du mariage ne peuvent être admises en raison du caractère impératif de l'article 214 du Code civil.

¹ RLDC déc. 2012, « Pour un renouveau des contrats de séparation de biens », par A. Depondt ; JCP N 2014, hors série août 2014, p. 26, « « Financement du logement de la famille et contribution des époux séparés de biens aux charges du mariage », par A. Karm ; RLDC déc. 2014, « L'achat d'un bien immobilier par deux époux séparés de biens », par R. Cabrillac.

² Defrénois avril 2015, p. 367, « *Contrat de mariage, charges du mariage et acquisitions indivises* », par G. Champenois et N. Couzigou-Shuas ; AJ Fam. 2015, p. 332, « *Financement du logement : comment adapter son contrat de mariage ?* », par J. Casey, in dossier « Charges du mariage » ; RTD Civ. 2014, p. 697, chronique « *Régimes matrimoniaux* », par B. Vareille.

³ AJ Fam. 2015, p. 317, « *Le domaine des charges du mariage* », par X. Guedé et F. Letellier, in dossier « Charges du mariage ».

Position de l'AUREP

Ces clauses nous paraissent aussi valables qu'opportunes pour des époux qui, rappelons-le, ont fait le choix d'un régime séparatiste. Ne pas reconnaître la validité de ces clauses serait imposer aux époux séparés de biens plus de « communauté » qu'aux époux mariés en communauté. Rappelons que l'utilisation de deniers propres aux fins d'acquérir un bien commun (en capital ou en revenus par la prise en charge de mensualités de prêt) ouvre légalement droit à récompense au profit de l'époux concerné. Et la jurisprudence n'est à ce jour pas venue étendre son raisonnement à un régime communautaire.

Qui plus est, sur le plan purement technique, si l'on considérait qu'il n'est pas possible d'exclure ces dépenses d'investissement de la notion de charges du mariage, il demeure que la loi autorise clairement toute convention quant à la contribution de chacun. Le principe fixé est celui de la proportionnalité avec les facultés respectives mais la convention contraire est possible, tant qu'aucun des époux ne s'exonère de toute contribution. Ainsi, serait-il possible de considérer que pour ces dépenses d'investissement, si elles devaient implacablement constituer des charges du mariage, l'accord des époux pourrait être interprété comme un accord sur la contribution. Pour ces dépenses, ils ont convenu que chacun devrait contribuer conformément à sa quote-part de propriété.

Section 3 – Séparation avec société d'acquêts

A – Définition et composition de la société d'acquêts

La société d'acquêts actuelle est une création de la pratique notariale qui s'appuie sur une ancienne pratique liée au régime dotal. A l'époque, la société d'acquêts avait un objet très large, semblablement à une communauté d'acquêts actuelle. C'est d'ailleurs pourquoi elle fut délaissée après la réforme de 1965 qui a instauré le régime légal permettant d'obtenir le même résultat.

Aujourd'hui pourtant, l'adjonction d'une société d'acquêts à un régime de séparation de biens peut retrouver son intérêt.

La libre composition de la société d'acquêts est autorisée par le principe de la liberté des conventions matrimoniales résultant de l'article 1387 du Code civil.

Cette société d'acquêts qui peut être plus ou moins restreinte (alors improprement dénommée puisqu'elle n'a plus pour objet les « acquêts »), se trouve régie par les règles de la communauté. Par ce biais, les époux ne seront donc pas propriétaires indivis des immeubles mais les immeubles apportés seront compris dans une société d'acquêts nouvellement créée.

Dans la plupart des cas, les époux aspirant à préserver leur indépendance patrimoniale en choisissant le régime de la séparation de biens, limitent le périmètre de la société d'acquêts. On parle alors de société d'acquêts à objet limité ou restreint. La doctrine a d'ailleurs admis

que la société d'acquêts puisse être valablement limitée à certains biens et la jurisprudence l'a validé dans un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, rendu le 1er juin 1999¹.

Dans les faits, l'objet de la société d'acquêts est très souvent limité au logement de la famille.

Attention

Si cela a l'apparence de la simplicité, il ne faut pourtant pas s'y tromper. Le notaire de la convention matrimoniale devra en effet être très vigilant sur la rédaction de l'acte si l'on ne veut se heurter au principe de l'immutabilité (ou désormais devrait-on dire le principe de « mutabilité contrôlée »).

Il convient d'être vigilant dans la rédaction de la clause de composition, notamment par l'utilisation de la formule « résidence principale ».

En effet, l'adoption de ce régime hybride ne saurait permettre aux époux de modifier de manière potestative la composition de la société d'acquêts sans enfreindre le principe d'immutabilité.

Ainsi, une convention matrimoniale se bornant à indiquer que la société d'acquêts comprend seulement « la résidence principale » au jour de la dissolution, serait, selon nous, contraire au principe d'immutabilité puisqu'elle permettrait aux époux de modifier le régime juridique d'un bien simplement en changeant son affectation². En effet, si la clause prévoit simplement que la société d'acquêts est composée de « la résidence principale », qu'advient-il alors lorsque des époux ayant leur résidence principale à Lyon déménagent à Bordeaux ? Quel est le sort de la propriété de Lyon : sort-elle de la société d'acquêts ?

C'est sur ce point que l'on constate l'atteinte au principe de l'immutabilité car le bien changerait de nature hors la procédure de changement de régime matrimonial.

C'est la raison pour laquelle, il n'est selon nous pas possible d'utiliser simplement la notion de « résidence principale » mais qu'il convient de désigner clairement le bien en cause.

Par ailleurs, il faudrait prévoir que ce bien fait définitivement partie de la société d'acquêts et qu'en cas d'aliénation, les deniers ou bien subrogés demeureraient dans la société d'acquêts.

Les mêmes précautions valent en ce qui concerne les « enveloppes » qui feraient partie de la société d'acquêts telles un PEA ou autre comte-titre ou compte de dépôt.

Attention à la société d'acquêts à géométrie variable

Pour les mêmes raisons, la doctrine majoritaire considère comme contraire au principe d'immutabilité ou de mutabilité contrôlée, la clause permettant aux époux de choisir arbitrairement au fil des acquisitions, si le bien nouveau entrera ou non dans la société d'acquêts.

¹ CA Lyon, 1^{er} juin 1999, Juris Data n°043765 : « Attendu que le recours à la « société d'acquêts », ajoutée à un contrat de séparation de biens, ancienne pratique notariale, est licite ; que les époux peuvent librement délimiter dans leur contrat l'étendue de ladite société d'acquêts et la masse commune, en la limitant à un seul immeuble notamment ».

² CORPECHOT, Rapport du 75^{ème} Congrès des Notaires de La BAULE 1978, t. 1, p. 314 ; PILLEBOUT, JCP N 1993, Doct. p. 141 ; FILLETTE, Defrénois 1996, art. 36369.



Conseil pratique

Lorsque les biens apportés sont financés par un prêt en cours, il convient de s'interroger plus largement sur le financement. Il est généralement préférable de prévoir un apport à la société d'acquêts non seulement de l'actif mais également du passif et alors de prêter attention au financement.

En effet, les règles de la communauté s'appliquent à la société d'acquêts, y compris celles relatives aux récompenses. Il peut donc être utile d'écarter les récompenses en ce qui concerne l'acquisition ou les travaux d'amélioration sur le bien dépendant de la société d'acquêts, dont le financement aurait lieu au moyen de revenus professionnels. Il ne faut pas omettre que très souvent cette petite communauté conventionnelle est privée de revenus. Les revenus professionnels demeurent propres/personnels s'il n'est pas spécifiquement prévu qu'ils font partie de la société d'acquêts.

B – Aménagements relatifs à cette société d'acquêts

La société d'acquêts étant un îlot communautaire conventionnellement défini, elle permet aux époux d'accéder à la technique des avantages matrimoniaux. L'on peut ainsi prévoir les clauses déjà étudiées comme le préciput, prélèvement moyennant indemnité, partage inégal, attribution intégrale etc ...

Comme en régime communautaire, on peut pareillement prévoir une clause alsacienne.

Nous renvoyons ici à nos développements du Chapitre 2 de la Partie 3 (page 86 et suivantes).

EXERCICE N°18

Monsieur A et Madame B, 43 et 35 ans, vivent en concubinage depuis plusieurs années. Monsieur n'a pas d'enfant. Madame a une fille d'une précédente union. Monsieur est propriétaire de leur résidence principale, acquise pour partie par succession et le surplus au moyen d'un prêt toujours en cours de remboursement.

Chacun dispose d'un patrimoine personnel relativement conséquent et exerce une activité libérale.

Ils ont décidé de se marier et d'assurer au survivant la propriété du logement commun. Ils vous précisent que le financement n'est pas conforme au titre : Madame finance 60% des mensualités du prêt et Monsieur 40%. En revanche, Monsieur cèdera prochainement un immeuble de rapport, et remboursera par anticipation à due concurrence une partie du capital restant dû.

Ils souhaitent que Madame ait des droits en propriété sur le bien et que le survivant d'eux soit seul propriétaire du bien. Ils veulent également qu'aucun compte ne soit établi quant au financement.

En revanche, le bien étant d'origine familiale, Monsieur souhaite qu'en cas de divorce Madame n'ait aucun droit dessus.

Question :

Que pouvez-vous leur conseiller ?

Réponse :

Chapitre II – Participation aux acquêts

Section 1 – Modèle proposé par le Code civil français

Ce régime est généralement défini comme un régime « hybride » permettant à la fois une indépendance patrimoniale entre les époux, comme en séparation de biens, et un partage de l'enrichissement à la fin de l'union, se rapprochant alors de l'esprit de la communauté légale. Protecteur (en termes de passifs) et équitable à la fois (en termes de liquidation), le régime de participation aux acquêts est souvent présenté comme un régime séparatiste mais il embrasse finalement davantage l'esprit communautaire en prévoyant un partage des richesses. En ce sens, il apparaît souvent plus fidèle à l'esprit du mariage qu'une séparation de biens pure et simple.

La participation aux acquêts a été adoptée comme régime légal par l'Allemagne et la Suède notamment. Certains préconisaient de l'adopter pour régime légal en France lors de la réforme de 1965 mais l'opinion française restait en faveur d'un régime communautaire. Ainsi ce régime n'a été introduit en 1965 qu'au titre des régimes conventionnels. Il est aujourd'hui prévu aux articles 1569 à 1581 du Code civil. Il tente de combiner les avantages de la communauté et ceux de la séparation de biens.

A – Le patrimoine des époux

Comme en séparation de biens, chaque époux est seul propriétaire de ses biens et l'on retrouve généralement dans le patrimoine des biens divis et des biens indivis entre les époux (voir les développements sur le régime de la séparation de biens page 103).

B – Les pouvoirs sur les biens

Chaque époux gère et dispose librement de ses biens personnels conformément à l'article 1569 du Code civil. Le régime de séparation de biens connaît une seule exception à cette règle, le logement familial et les meubles meublants qui le composent ne peuvent être cédés par l'époux propriétaire sans le concours de son conjoint.

Nous renvoyons sur ce point à nos développements page 28.

S'agissant des biens indivis, leur gestion est prévue aux articles 815 et suivants du Code civil (voir les développements sur le régime de la séparation de biens page 105).

Attention



L'article 1573 du Code civil prévoit que pour le calcul de la créance, les biens donnés entre vifs sans le consentement du conjoint et ceux qui ont été aliénés en fraude de ses droits doivent être considérés comme faisant toujours partie du patrimoine de l'époux donateur. Il ne s'agit pas d'une règle de pouvoirs, chacun étant parfaitement en mesure d'aliéner à titre gratuit ou onéreux les biens dont il est propriétaire seul, mais d'une règle relative au calcul de la créance de participation.

Mais en pratique, elle a pour conséquence l'intervention du conjoint lors de la donation.

C – La dissolution du régime

Le partage de l'enrichissement se fait à la dissolution du régime et se traduit par le calcul et le règlement de la créance de participation.

1 – Calcul de la créance de participation

Cette créance se détermine par comparaison entre le patrimoine final et le patrimoine originaire.

a – Patrimoine originaire : composition et évaluation

Le patrimoine originaire de chaque époux comprend :

- les biens (et dettes) qui appartenaient à chaque époux au jour du mariage ;
- biens reçus par donation ou succession ;
- ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté, sont des biens propres par nature sans donner lieu à récompense.

En réalité, sont compris dans le patrimoine originaire tous ces biens ou les biens qui ont été subrogés.

La subrogation a lieu de manière automatique, elle joue de plein droit et nécessite donc aucune formalité.

En revanche la subrogation soulève des difficultés pratiques et probatoires non négligeables. Nous les évoquerons ci-après en matière d'évaluation du patrimoine originaire.

Quant aux fruits des biens originaires, ils n'ont pas à être pris en compte dans le patrimoine originaire. Ils seront donc pris en compte dans la mesure de l'enrichissement et profiteront *in fine* aux deux époux à travers la créance de participation.

L'évaluation des biens figurant au patrimoine originaire n'est pas constituée des valeurs « historiques ».

Chaque bien est porté au patrimoine originaire pour sa valeur au jour de la liquidation selon son état au jour du mariage (art. 1571 C. civ.), c'est-à-dire notamment, sans tenir compte des améliorations qui auraient été apportées pendant le mariage.

Comme nous l'avons indiqué, la subrogation a lieu de plein droit. Si le bien a été aliéné et le prix de vente réinvesti, alors il conviendra de tenir compte de la valeur du nouveau bien, à la date de la dissolution. En l'absence de subrogation, le bien originaire aliéné doit figurer pour sa valeur au jour de la vente.

Quid des comptes bancaires ?

En ce qui concerne un compte bancaire détenu avant le mariage, dès lors que le compte a été abondé ou prélevé pendant le régime, la doctrine considère que l'on ne peut considérer qu'on le trouve *en nature* dans le patrimoine de l'époux au jour de la liquidation. Dès lors, il conviendrait de faire apparaître son équivalent au patrimoine originaire pour le montant nominal du compte à l'époque du mariage¹.



¹ J.-F. Pillebout, *La participation aux acquêts*, Litec, n°162 ; S. David-A. Jault, *Liquidation des régimes matrimoniaux*, Dalloz Référence, 2016-2017, n°412.44.

Plus largement la difficulté tient dans l'établissement de la preuve de la subrogation chaque fois que des fonds du patrimoine originaire (avoirs financiers détenus au jour du mariage et fonds provenant de la vente des biens originaires) sont utilisés.

Ce mécanisme de subrogation implique d'avoir à retracer toutes les opérations et constitue le principal écueil du régime de la participation aux acquêts de notre Code civil. Nous verrons que c'est une des raisons qui peuvent conduire les époux à choisir le modèle franco-allemand.

b – Patrimoine final : composition et évaluation

Le patrimoine final comprend tous les biens existant à la dissolution.

Sont également fictivement réunis les biens aliénés frauduleusement ou donnés pendant le mariage sans le consentement du conjoint sauf s'il s'agissait de biens originaires.

Quant à l'évaluation, chaque bien est porté au patrimoine final pour sa valeur au jour de la liquidation du régime (art. 1574 C. civ.).

2 – Montant de la créance de participation

Sont ainsi déterminés les « acquêts nets » de chaque époux par différence entre le patrimoine final et le patrimoine originaire.

Celui des époux qui s'est le plus enrichi est débiteur de la créance de participation.

Celle-ci est évaluée à la moitié de la différence entre les « acquêts nets » de chacun.



Attention

Le législateur utilise le terme « d'acquêts » mais il n'existe aucune communauté. La notion « d'acquêt » doit ici s'entendre comme la traduction matérielle de l'enrichissement advenu pendant le mariage.



Quid en cas d'appauvrissement ?

Si l'un des époux s'est appauvri, il supporte seul cet appauvrissement.

C'est ici une différence majeure avec le régime de la communauté réduite aux acquêts qui fait ressortir pour partie le caractère séparatiste du régime mais également sa dénomination de participation « aux acquêts » et non aux pertes.



Conseil pratique

On l'aura compris, en raison du fonctionnement de la participation aux acquêts, il est plus que recommandé de faire établir un inventaire (exhaustif) au début du régime.

3 – Règlement de la créance de participation

La créance de participation devra être payée en argent dès la clôture de la liquidation (sauf à demander un délai en justice qui ne pourrait dépasser 5 ans) ou en nature par l'attribution d'un bien.

Le paiement en nature peut exister à titre exceptionnel (C. civ., art 1576 et 1581).

En cas de désaccord sur la liquidation du régime, les époux ou l'un d'eux peut saisir le tribunal pour qu'il y soit procédé en justice (C. civ., art. 1578). Dans cette hypothèse, l'action en liquidation se prescrit par trois ans.

Section 2 – Modèle franco-allemand

Depuis le 1^{er} mai 2013, les époux peuvent adopter le régime optionnel franco-allemand de la participation aux acquêts.

Ce régime franco-allemand est donc largement inspiré de nos régimes respectifs de participation aux acquêts.

Nos deux pays connaissent en effet la participation aux acquêts :

- ✓ la France, sous la forme d'un régime conventionnel
- ✓ l'Allemagne puisqu'il constitue le régime légal (aussi appelé « communauté différée des augmentations »).

Après plusieurs années de travaux conduits par une commission restreinte, ce régime matrimonial a vu le jour aux termes d'un accord du 4 février 2010, ratifié par la France par la loi n°2013-98 du 28 janvier 2013.

La définition de ce régime ne figure pas dans le Code civil français mais dans le décret de ratification n°2013-488 du 10 juin 2013.

A – Champ d'application

Ce régime matrimonial peut être adopté depuis 1^{er} mai 2013.

S'il a naturellement vocation à être plébiscité par les couples franco-allemands, son champ d'application est en réalité beaucoup plus vaste.

Il peut parfaitement être adopté par les couples français, les couples allemands, ou encore tout couple dont la résidence habituelle se trouve en France ou en Allemagne en application du règlement européen sur les régimes matrimoniaux.¹

S'agissant d'un régime conventionnel, il est nécessaire de réaliser un contrat de mariage ou une convention de modification de régime pour l'adopter.

B – Principales différences avec la participation aux acquêts du Code civil français

Ersatz de régime primaire

Le régime franco-allemand prévoit quelques règles s'approchant de notre régime primaire, inconnu en tant que tel du droit allemand. Par exemple, l'article 5 prévoit notamment que

¹ Depuis le 29 janvier 2019, date d'entrée en application du règlement du règlement européen (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016, dont l'art. 22 prévoit que les époux ou futurs époux peuvent choisir :

- la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention ;
- la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention.

« les actes de disposition d'objets du ménage ou de droits par lequel est assuré le logement de la famille passé par un époux sans le consentement de l'autre sont nuls ».

Précisons que, quoi qu'il en soit, pour les couples relevant de la loi française, le régime primaire du Code civil français est applicable.

1 – Composition et évaluation du patrimoine originaire

Le patrimoine originaire comprend :

- ✓ Les biens composant le patrimoine de chaque époux au jour du mariage ;
- ✓ Les biens reçus ultérieurement par donation ou succession et les dettes y afférentes ;
- ✓ Les indemnités perçues en réparation d'un dommage corporel ou moral.

Un inventaire doit être établi lors de la conclusion du mariage. Cet inventaire est présumé exact si les deux époux l'ont signé. À défaut d'inventaire, le patrimoine originaire est présumé nul.

En matière d'évaluation, les règles du droit français ont été écartées au profit des règles du droit allemand.

Le patrimoine est pris en compte dans son état initial (au jour du mariage) tant pour sa composition que son évaluation.

En principe, les biens sont estimés suivant leur valeur initiale :

- ✓ Valeur au jour du mariage pour les biens dont ils étaient déjà propriétaires ;
- ✓ Valeur au jour d'entrée dans le patrimoine pour les biens reçus par donation ou succession pendant le mariage ou les indemnités perçues en réparation d'un dommage corporel ou moral.

La même solution est retenue pour les dettes.

Les montants retenus font l'objet d'une indexation à compter du jour de leur entrée dans le patrimoine originaire. L'article 9 prévoit en effet que ces valeurs sont indexées sur la variation moyenne de l'indice général des prix à la consommation.

Il évite ainsi le principal écueil du régime français de la participation aux acquêts tenant aux difficultés liées au mécanisme subrogatoire et notamment aux difficultés probatoires en la matière.

Suivant ces règles, nul de besoin de rechercher ce que sont devenus les biens.

Toutefois, concernant les biens immobiliers et droits réels immobiliers autres que l'usufruit ou le droit d'usage et d'habitation, l'article 9 prévoit de retenir :

- ✓ Si le bien est encore dans le patrimoine au jour de la dissolution, sa valeur à cette date
- ✓ Si le bien a été aliéné ou remplacé au cours du mariage, la valeur d'aliénation ou de « remplacement » indexée à compter de cette date
- ✓ Le tout sans tenir compte des modifications d'état entreprises au cours du mariage

2 – Donation de biens acquis pendant le mariage

La réunion fictive au patrimoine final des biens donnés par un époux pendant le mariage est reprise dans le régime franco-allemand mais les conditions sont substantiellement différentes ainsi qu'en dispose l'article 10 :

« Est ajoutée au patrimoine final la valeur des biens qu'un époux :

1. a donnés, sauf :

a) si la donation n'est pas excessive eu égard au train de vie des époux ou

b) la donation porte sur un bien du patrimoine originaire donné à des parents en ligne directe. Toutefois, la plus-value apportée par les améliorations réalisées sur ce bien, pendant la durée du régime matrimonial, avec des deniers ne dépendant pas du patrimoine originaire, est ajoutée au patrimoine final. »

De surcroît, cette réunion fictive ne peut concerner que les actes passés il y a moins de 10 ans ou ceux réalisés sans le consentement du conjoint.

3 – Plafonnement de la créance de participation

L'article 14 du régime franco-allemand prévoit un plafonnement de la créance de participation, qui n'existe ni en droit français ni en droit allemand.

Ainsi, le montant de la créance de participation est limité à la moitié de la valeur du patrimoine de l'époux débiteur, tel qu'il existe, après déduction des dettes.



Conseil pratique

Pour résumer, ce régime franco-allemand se veut plus pragmatique et donc plus simple dans sa liquidation.

Il est sans doute à préférer à notre modèle du Code civil.

Section 3 – Liquidation alternative en régime de participation aux acquêts

Le régime de participation aux acquêts peut également faire l'objet d'aménagements.

Tout d'abord, comme en régime de séparation de biens, il est possible de prévoir :

- ✓ Des modifications des règles relatives aux créances entre époux
- ✓ Une clause commerciale (faculté d'acquisition ou d'attribution)

Ensuite, il est également possible de prévoir des modifications des règles de calcul de la créance de participation et son paiement. Elles peuvent prendre diverses formes :

- ✓ Modifications relatives au patrimoine originaire :
 - évaluer les biens originaux pour zéro ou déclarer que tous les biens originaux sont qualifiés d'acquêts ;
 - évaluer les biens originaux pour leur valeur au jour du mariage ;
 - comme en régime franco-allemand : prévoir, pour les biens non immobiliers, une indexation, pour faciliter la liquidation ;
- ✓ Modifications relatives au patrimoine final :
 - Exclure certains biens (comme la clause d'exclusion des biens professionnels)

- Modification des règles d'évaluation des biens (réévaluation des passifs notamment)
- ✓ Modification du montant de la créance de participation :
 - Plafonnement de la créance
 - Minoration de la créance par pondération
 - Attribution intégrale des acquêts nets
 - Exclusion de la créance
- ✓ Paiement de la créance en nature

Parmi ces aménagements, certains permettent de protéger le conjoint survivant en l'avantageant dans la liquidation comme l'attribution intégrale des acquêts nets. Au décès du premier époux, le survivant sera créancier de tous les acquêts nets (soit de 100% de l'enrichissement du prémourant). À cet aménagement, peut être combiné un paiement en nature. De la sorte, on se rapproche du résultat atteint par un régime de communauté réduite aux acquêts avec attribution intégrale de la communauté au survivant. L'on pourrait même ajouter une clause prescrivant d'évaluer les biens du patrimoine originaire pour zéro. Alors, le résultat ressemble de très près à une communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au survivant.

A l'inverse, d'autres clauses ont pour finalité une protection en cas de divorce, comme la clause d'exclusion de la créance de participation. Il s'agit alors de liquider le régime suivant les règles classiques si le mariage se termine par la survenance d'un décès (calcul de créance de participation) et comme une séparation de biens pure et simple en cas de divorce en stipulant que la créance de participation sera exclue dans cette hypothèse.

On retrouve ici la notion de liquidation alternative : le régime matrimonial sera liquidé différemment selon la cause de la dissolution (décès ou divorce). L'idée est d'aménager dès le mariage les conséquences d'un divorce et améliorer la situation du conjoint survivant en cas de dissolution par décès.

Or, nous rappelons que l'article 265 du Code civil prévoit le sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce :

- les avantages matrimoniaux ayant pris effet au cours du mariage sont maintenus ;
- ceux prenant effet à la dissolution sont révoqués de plein droit.

En régime de participation aux acquêts, les aménagements visent à modifier le calcul de la créance de participation. La créance de participation se calcule à la fin de l'union. Par syllogisme, ces aménagements déploient donc leurs effets à la dissolution du mariage.

Pour les aménagements visant à protéger le survivant lorsque le mariage prend fin par un décès, il n'y a pas de difficulté. Si finalement le mariage s'achève par un divorce, il est bien normal que ces stipulations ne puissent produire effet. Ces gains de survie sont voulus pour le conjoint survivant et non pour l'ex-conjoint survivant.

La question était tout autre pour les aménagements relatifs à la dissolution par divorce.

Fort heureusement, la loi n° [2024-494](#) du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille est venue mettre un terme aux difficultés existantes en la matière et consacre désormais l'efficacité des aménagements matrimoniaux prévus pour l'hypothèse d'une dissolution par divorce. Cette loi a notamment modifié la rédaction de l'article 265 du Code civil, qui prévoit toujours une révocation automatique des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution mais ajoute que leur maintien peut être prévu dans la convention matrimoniale, ce qui n'était pas le cas antérieurement, le maintien devait être manifesté au moment du divorce.

Cette loi est entrée en vigueur le 2 juin 2024, les dispositions de l'article 265 nouveau étant applicables dès cette date.

Quid avant cette modification de l'article 265 du Code civil ?

Les aménagements relatifs à l'hypothèse de dissolution par divorce, comme la clause d'exclusion des biens professionnels, avaient divisé la doctrine quant à leur qualification. Constituaient-elles des avantages matrimoniaux ? Dans l'affirmative, de telles clauses auraient pu se trouver dépourvues d'effet au moment du divorce en raison des dispositions de l'article 265 du Code civil (dans sa rédaction antérieure).

La difficulté tient à ce qu'il n'existe aucune définition de la notion d'avantage matrimonial, de telle sorte que la qualification d'avantage matrimonial soulève de nombreuses questions.

Une partie de la doctrine¹ considérait qu'il ne s'agissait pas d'un avantage matrimonial car la clause conduisait à limiter la participation aux acquêts, de telle sorte que la clause pourrait déployer ses effets en cas de divorce.

Pour d'autres auteurs en revanche la clause d'exclusion des biens professionnels constituait nécessairement un avantage pour l'époux dont les biens étaient exclus du calcul², de sorte qu'elle était automatiquement révoquée par l'effet du divorce.

Parmi eux néanmoins, certains s'interrogeaient sur la possibilité de prévoir dès le contrat de mariage, le maintien d'un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime et notamment en cas de divorce. Autrement dit, la question se posait de savoir si les dispositions du deuxième alinéa de l'article 265 précité étaient seulement supplétives lorsqu'elles prescrivaient que le maintien d'un tel avantage matrimonial devait être constaté par le juge « *au moment du prononcé du divorce* ». Le caractère supplétif du texte était

¹ N. Duchange, « Un inconvénient patrimonial n'est pas un avantage matrimonial », Defr. 2010 art. 39117, et « Quelques précisions sur l'évaluation des avantages matrimoniaux à propos d'une formule de la participation aux acquêts », Defr. 1993, art. 35618 ; F. Letellier, « La clause d'exclusion des biens professionnels sous le régime de la participation des acquêts à l'épreuve du divorce – quelques éléments de réponse à une question angoissante », JCP N 2008, 1150 ; M.-P. Murat-Sempietro, « Les avantages matrimoniaux et les libéralités conjugales à l'épreuve du divorce », Mémoire DSN – 23 avril 2007.

² F. Lucet, « Des rapports entre régime matrimonial et libéralités entre époux », thèse, p.583 n°421 ; J.P. Storck, « Avantages matrimoniaux et participation aux acquêts... », JCP N 1981, I, p.355 n°23 et s. ; G. Morin, « Brèves remarques sur deux études relatives au contrat de mariage du chef d'entreprise ... », Defr. 1987 art. 34054 n°7 ; Flour et Champenois, Les régimes matrimoniaux, A. Colin, n°797 ; Droit Patrimonial de la Famille, Dalloz Action 2008/2009, sous la direction de M. Grimaldi, n°172.73 ; plus nuancé J.F. Pillebout, La participation aux acquêts – Formules commentées de contrat de mariage, Litec, n°284 ; C. Brenner, « Avantage matrimonial et participation aux acquêts – Le sort de la clause d'exclusion des biens professionnels dans le divorce », APSP oct.-nov.-déc. 2015. M.-P. Murat-Sempietro et V. Trambouze, Le divorce après la loi du 26 mai 2004, éd. Litec, n° 578 ; F.Sauvage, « Des conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux », Defr. 2004, art. 38038.

soutenu par une partie de la doctrine¹ qui tirait argument du recul de l'ordre public matrimonial, de la conventionnalisation du divorce et de la liberté des conventions matrimoniales. D'autres auteurs prêtaient, en revanche, un caractère d'ordre public à ce texte².

La Cour de cassation s'était prononcée sur l'application des dispositions de l'article 265 à une clause d'exclusion des biens professionnels en régime de participation aux acquêts dans un arrêt 18 décembre 2019³. Dans cette affaire, l'époux était directeur de laboratoire et l'épouse pharmacienne. Ils avaient adopté un régime de participation aux acquêts avec exclusion des biens professionnels. A l'heure du divorce, Monsieur avait sollicité la révocation de cette disposition. La Cour de cassation avait retenu un raisonnement par syllogisme :

- **La clause d'exclusion des biens professionnels constitue un avantage matrimonial** car elle « conduit à avantager celui d'entre eux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint »
- Les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux **prenant effet à la dissolution du régime matrimonial**
- **Donc la clause d'exclusion des biens professionnels est révoquée de plein droit par application des dispositions de l'article 265 du Code civil.**

Cet arrêt avait ainsi sonné le glas des aménagements relatifs à la liquidation en cas de divorce (sauf pour la clause alsacienne dans les régimes communautaires car expressément visée par ce même article 265). Ces aménagements étaient devenus parfaitement inefficaces sauf volonté des époux de les maintenir, volonté qui doit être exprimée au moment du divorce

Cette solution avait été réitérée dans un arrêt du 31 mars 2021⁴.

Depuis le 2 juin 2024

Dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 juin 2024, si l'article 265 du Code civil a toujours pour effet d'emporter révocation automatique des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, il prévoit désormais que ces avantages peuvent néanmoins être maintenus par la volonté des époux :

- Constatée dans la convention de divorce ;
- Par le juge lors du prononcé du divorce ;
- Exprimée dans la convention matrimoniale.

¹ J. Hauser et Ph. Delmas Saint-Hilaire, Juris. Civ. Code, art. 263 à 265-2, fasc. 20, n° 34 et s. ; J.-L. Puygauthier, art. préc. ; A. Delfosse et J.-F. Péniguel, « *Libéralités entre époux, avantages matrimoniaux et réforme du divorce* », JCP N 2004, 1588 ; Ph. Simler, « *La validité de la clause de liquidation alternative de communauté universelle menacée par le nouvel article 265 du Code civil* », JCP N 2005, 1264 ; C. Brenner, « *Avantage matrimonial et participation aux acquêts- Le sort de la clause d'exclusion des biens professionnels dans le divorce* », APSP oct.-nov.-déc. 2015.

² F. Sauvage, « Des conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux », Defr. 2004 art. 38038.

³ Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n°[18-26.337](#).

⁴ Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n°[19-25.903](#).

C'est ce dernier point qui constitue l'objet de la modification opérée par la loi n° [2024-494](#) du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.

Cette modification est d'une grande importance car elle marque le retour au principe de liberté des conventions matrimoniales. Elle permet de prévoir et sécuriser des conventions matrimoniales très travaillées, personnalisées et prenant beaucoup de liberté vis-à-vis des modèles proposés par le Code civil.

Si les régimes à liquidation alternative avaient pris de l'ampleur, les clauses protégeant le survivant en cas de décès étant très usitées, l'anticipation des effets du divorce sur la liquidation du régime matrimonial s'était limitée à la clause alsacienne dans les régimes communautaires (et séparation de biens avec société d'acquêts). Les décisions précitées (de 2019 et 2021) avaient fait fuir les éventuels candidats à la participation aux acquêts.

Hier en voie de disparition, nous devrions assister à un renouveau de ce régime matrimonial qui peut désormais permettre tout à la fois de protéger le conjoint et de doser, limiter, voire annihiler la créance de participation en cas de divorce.

Cette loi nouvelle étant applicable à compter du 2 juin 2024, elle apporte également une pérennité bienvenue et espérée aux conventions matrimoniales préexistantes qui stipulaient ce type de clauses (si toutefois la procédure de divorce n'avait pas été entamée avant son entrée en vigueur).

EXERCICE N°19

Monsieur Labaurentin et Madame Kaire se sont mariés à l'âge de 25 ans alors qu'ils terminaient leurs études et n'avait aucun patrimoine personnel.

Ils se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts.

Voici leur situation patrimoniale 30 ans plus tard.

Madame Kaire est pharmacienne. Elle est propriétaire de l'officine dans laquelle elle exerce. Celle-ci n'est pas exploitée en société mais directement détenue par Madame. Elle est évaluée à 900.000 €. Elle est exploitée dans les locaux appartenant à la SCI dont Madame détient 95 % des parts, évaluées à 500.000 €.

Par ailleurs, Madame Kaire est propriétaire des droits et biens suivants :

- la moitié indivise de la résidence principale du couple, une maison à Chamalières évaluée 620.000 €
- la moitié indivise d'un appartement à Sète, constituant une résidence secondaire, évalué à 330.000 €
- un appartement locatif à Villeurbanne : 250.000 €
- un PEA : 130.000 €
- une maison dans le Cantal (reçue par donation de ses père et mère) : 210.000 €
- des comptes de dépôts, livrets et épargnes divers : 50.000 €

Monsieur Labaurentin est directeur d'un laboratoire d'analyses médicales dont il est salarié. Son patrimoine se compose des droits et biens suivants :

- la moitié indivise de la résidence principale du couple, une maison à Chamalières évaluée 620.000 €
- la moitié indivise d'un appartement à Sète, constituant une résidence secondaire, évalué à 330.000 €

- un appartement à Arcachon (reçu dans la succession de sa mère) : 400.000 €
- deux appartements locatifs à Lyon dans le même immeuble, évalués ensemble à : 550.000 €
- un PEA : 140.000 €
- des comptes de dépôts, livrets et épargnes divers : 90.000 €

Questions :

Vous liquiderez leur régime matrimonial selon chacune des hypothèses retenues ci-après :

- 1/ Décès ou divorce, sans aménagement matrimonial spécifique (le contrat de mariage reprend exclusivement les règles du Code civil).
- 2/ Décès de Monsieur, le contrat de mariage prévoyant l'attribution des acquêts nets du prémourant au survivant en nature.
- 3/ Divorce, le contrat de mariage comportant une clause d'exclusion des biens professionnels (tant sur l'entreprise que sur les locaux ou parts sociales représentatives des locaux dans lesquels l'activité est exercée).
- 4/ Divorce, le contrat de mariage prévoyant un plafonnement de la créance de participation à la moitié du patrimoine final non professionnel.
- 5/ Divorce, le contrat de mariage prévoyant une minoration de la créance de participation à un quart.

Corrigés des exercices

CORRIGE EXERCICE N°1–PAGE 17

Cette clause ne serait pas valable puisqu'il n'est pas possible de déroger aux règles relatives à l'autorité parentale et à l'administration légale.

CORRIGE EXERCICE N°2–PAGE 18

Il n'est pas possible de procéder au règlement d'une récompense pendant le mariage.
L'épargne salariale de Marion a la nature de bien commun et ne pourra donc pas devenir propre à Stéphane même s'ils sont d'accord sur le fait que c'est un remboursement. Aucune solution pratique ne peut être apportée.

CORRIGE EXERCICE N°3–PAGE 24

Le sport automobile est un loisir. Quand bien même François a engagé des dépenses importantes, il s'agit de charges du mariage ! Sa future ex-épouse ne peut donc rien réclamer à ce titre.

CORRIGE EXERCICE N°4–PAGE 26

Il est probable que s'agissant d'un équipement de confort et d'agrément pour la famille qui ne paraît pas excessif au regard du train de vie de la famille, il entre dans les dettes ménagères de l'article 220 du Code civil.
Autrement dit, Marine serait tenu solidairement de cette dette même si elle n'a rien signé. Elle aurait alors tout intérêt à régler ce passif avant que la situation ne s'aggrave.

CORRIGE EXERCICE N°5 –PAGE 28

Il n'est pas possible de déroger de cette manière aux règles de pouvoirs.
Concernant les biens propres, le régime primaire interdit toute clause en ce sens.
Au mieux, les époux pourront prévoir un mandat de droit commun.

CORRIGE EXERCICE N° 6–PAGE 50

Nature de la quote-part indivise : propre par origine – bien reçu par succession (art. 1405 C. civ.)
Nature du bien acquis : propre – bien acquis par licitation/partage (art. 1408 C. civ.)
Nature des loyers perçus : communs – revenus de biens propres (art. 1401 C. civ.)
Récompense ?
A défaut de précision, les économies de l'époux sont présumées communes = présomption de communauté (art. 1402 C. civ.)
Appauvrissement du patrimoine commun au profit du patrimoine propre de l'époux → récompense due par Monsieur à la communauté
Evaluation selon le profit subsistant car dépense d'acquisition et le bien se trouve encore dans le patrimoine emprunteur
 $2/3 \times 600.000 = 400.000$

CORRIGE EXERCICE N° 7–PAGE 51

Nature du fonds : bien propre car ouvert au public avant le mariage
Nature de l'immeuble : propre par origine
Nature des parts sociales rémunérant les apports :

- Apports en nature (fonds de commerce et immeuble) → subrogation réelle → parts propres
- Apport en numéraire :
 - Avec déclaration de remploi → parts propres
 - Sans déclaration de remploi → parts communes

CORRIGE EXERCICE N° 8–PAGE 61

Obligation :

Le créancier ne peut saisir que les biens propres et les revenus de son débiteur (art. 1415 C. civ.).

Les salaires de l'autre époux ne peuvent être saisis que si la dette concerne l'entretien du ménage et l'éducation des enfants (art. 1414 C. civ.).

Contribution :

La dette souscrite par un époux seul pendant le mariage doit par principe être considérée comme ayant été contractée dans l'intérêt de la communauté, de sorte qu'elle devra être inscrite au passif.

CORRIGE EXERCICE N°9–PAGE 61

Obligation :

Les deux époux ont signé l'acte de prêt. Le banquier peut poursuivre le paiement de sa créance sur les biens propres de chacun et les biens communs.

Contribution :

La dette relative à un bien propre de Monsieur n'incombait qu'à titre provisoire à la communauté. La communauté a droit à récompense pour les échéances remboursées pendant le mariage, et le solde de l'emprunt sera inscrit au passif propre de Monsieur.

CORRIGE EXERCICE N°10–PAGE 62

Obligation :

Les dettes professionnelles nées pendant le mariage engagent tous les biens du couple : biens propres de l'époux concerné et biens communs.

Cependant, si les dettes sont nées de l'activité professionnelle de Monsieur, ayant le statut d'entrepreneur individuel (dettes nées à compter de l'entrée en vigueur de ce statut), l'application de l'article L 526-22 du Code de commerce exclut du droit de gage des créanciers professionnels les biens qui ne sont pas utiles à cette activité. Seuls les biens professionnels, propres à Monsieur ou communs, constituent le droit de gage des créanciers professionnels.

Contribution :

Les dettes professionnelles nées pendant le mariage incombent définitivement à la communauté.

CORRIGE EXERCICE N° 11– PAGE 66

Il n'est pas possible de déroger de cette manière aux règles de pouvoirs.

Concernant les biens communs, la convention matrimoniale ne peut pas exclure la gestion conjointe (ou cogestion) prévue par la loi.

Au mieux, les époux pourront prévoir un mandat de droit commun.

Sinon, il faudra utiliser la mise en société pour dissocier l'avoir et le pouvoir.

CORRIGE EXERCICE N°12–PAGE 69

A défaut de deniers propres et de déclaration de remploi faite par Amélie lorsqu'elle a versé les fonds en compte courant, la créance de compte courant est un actif de communauté.

En revanche, le remboursement d'un compte courant ne peut être demandé que par celui qui a la qualité d'associé. En raison de la distinction du titre et de la finance, la demande de Sébastien restera lettre morte... N'étant pas associé, il n'a aucun pouvoir pour faire cette demande.

CORRIGE EXERCICE N°13–PAGE 71

La maison héritée est un propre de Caroline. Le prix de vente de cette maison est propre par le jeu de la subrogation réelle automatique. Ces deniers propres ont permis l'acquisition d'une villa qui est commune, en l'absence de déclaration de remploi.

Il y a donc appauvrissement du patrimoine propre de Caroline au profit de la communauté, ce qui génère une récompense au profit de Caroline.

S'agissant d'une dépense d'acquisition, la récompense est égale au profit subsistant, soit à la valeur de la maison au jour de la liquidation, dans son état au jour de l'acquisition. Il ne faut donc pas tenir compte de la piscine (laquelle ne donne pas lieu à récompense, car c'est une amélioration d'un bien commun au moyen de deniers communs – les économies réalisées sur les salaires des époux étant communes). La récompense due par la communauté à Caroline est donc de 360.000 euros.

CORRIGE EXERCICE N°14–PAGE 72

Le prix de vente de la maison reçue par donation est propre par subrogation réelle automatique.

Mais Pierre a utilisé cette somme sans faire de déclaration de remploi. L'appartement acquis est donc commun.

Toutefois, une partie du financement a été assurée par des deniers propres à Pierre, il a donc droit à récompense. Pierre a droit à récompense pour sa contribution à l'acquisition d'un bien commun (article 1433 du code civil).

La communauté a contribué à l'acquisition à hauteur de 50 000 euros (les économies réalisées sur les revenus sont des fonds communs – article 1401 du code civil). Il y a donc une double contribution, propre pour 2/3 (100 000/150 000) et commune pour 1/3 (50 000/150 000).

La récompense est égale au profit subsistant (dépense d'acquisition, article 1469, alinéa 3, du Code civil). Elle se calcule comme suit :

Récompense = $100.000/150.000 \times 360.000 = 240\ 000$ euros

CORRIGE EXERCICE N°15–PAGE 74

Le terrain est un propre à Leslie (par origine–donation) et, en vertu de la théorie de l'accession, l'ensemble immobilier bâti a la nature de propre.

A défaut de précision, la construction a été financée par la communauté. Elle a droit à récompense et comme elle a amélioré un bien se trouvant dans le patrimoine emprunteur, ladite récompense sera calculée selon la règle du profit subsistant (C. civ., art. 1469, al. 3). En l'espèce, la mesure de l'enrichissement se fait par différence entre la valeur actuelle de la propriété bâtie et la valeur actuelle qu'aurait le terrain s'il était resté nu.

Récompense = $360.000 - 110.000 = 250.000$

CORRIGE EXERCICE N°16–PAGE 83

Que pouvez-vous leur dire sur les conséquences d'un mariage sans contrat eu égard à leur résidence principale ?

Ludovic demeure seul propriétaire de la maison à titre de bien propre

La communauté est créancière d'une récompense au titre des mensualités payées pendant le mariage (part en capital)

Marie est créancière de Ludovic au titre du droit commun

Pourrait-on leur conseiller des aménagements pour améliorer cette situation, tout en conservant un régime communautaire ?

Il serait opportun de leur conseiller de faire un contrat de mariage en choisissant le régime de la communauté réduite aux acquêts avec les aménagements suivants :

- Apport du bien par Ludovic à la communauté
- Apport du passif restant dû par Ludovic (le solde du prêt) afin d'éviter que son remboursement ne constitue un chef de récompense
- Apport par Marie et Ludovic de la créance/dette existant entre eux pour les travaux, afin de les éteindre.

CORRIGE EXERCICE N°17-PAGE 95

Il faut leur conseiller de ne pas se contenter du régime légal mais de faire un contrat de mariage en choisissant le régime de la communauté réduite aux acquêts et en prévoyant les clauses suivantes :

- Clause d'ameublement (mise en communauté du bien, auparavant propre car acquis avant le mariage)
- Et, au choix (ou les deux sous forme d'alternatives) :
 - Une clause de préciput concernant cette résidence principale
 - Ou une clause de prélèvement moyennant indemnité sur cette résidence principale

Dans le cas d'un préciput, le survivant pourra prélever le bien avant tout partage puis aura droit à la moitié du restant de la communauté.

Dans le cas d'un prélèvement moyennant indemnité, le prélèvement de la maison s'imputera sur la part de moitié de la communauté du survivant.

CORRIGE EXERCICE N°18-PAGE 113

On peut conseiller aux futurs époux d'adopter le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts.

On peut prévoir l'apport à la société d'acquêts du bien immobilier ainsi que du passif : prêt restant à rembourser et éventuelles créances de Madame/dettes de Monsieur.

On prévoira l'exclusion de récompense à raison du financement de l'acquisition et des travaux payés au moyen de revenus professionnels et/ou provenant de la cession d'un bien personnel.

On prévoira un préciput ou une attribution intégrale.

On prévoira également une clause alsacienne. Sur ce point, on précisera le mode d'indemnisation au profit de la société d'acquêts qui aura assumé un passif relatif à un actif dont elle se trouve privée par la mise en œuvre de la clause de reprise.

CORRIGE EXERCICE N°19-PAGE 124

1/ Décès ou divorce, sans aménagement matrimonial spécifique (le contrat de mariage reprend exclusivement les règles du le Code civil).

MADAME KAIRE

Patrimoine originaire	
Biens au jour du mariage : néant	
Maison de famille dans le Cantal	210 000 €
Total	210 000 €

Patrimoine final	
Officine de pharmacie	900 000 €
Parts de SCI (locaux pharmacie)	500 000 €
Moitié indivise de la maison à Chamalières	310 000 €
Moitié indivise de l'appartement à Sète	165 000 €
Appartement locatif à Villeurbanne	250 000 €
Maison de famille dans le Cantal	210 000 €
PEA	130 000 €
Comptes de dépôt et livrets	50 000 €
Total	2 515 000 €

ACQUETS NETS 2 305 000 €

MONSIEUR LABAURENTIN

Patrimoine originaire	
Biens au jour du mariage : néant	
Appartement de famille à Arcachon	400 000 €
Total	400 000 €

Patrimoine final	
Moitié indivise de la maison à Chamalières	310 000 €
Moitié indivise de l'appartement à Sète	165 000 €
Appartement de famille à Arcachon	400 000 €
Deux appartements locatifs à Lyon	550 000 €
PEA	140 000 €
Comptes de dépôt et livrets	90 000 €
Total	1 655 000 €

ACQUETS NETS 1 255 000 €

Débiteur de la créance de participation : celui dont les acquêts nets sont supérieurs,

Soit : MADAME KAIRE

Montant de la créance de participation : (acquêts nets supérieurs – acquêts nets inférieurs) / 2

Soit : 525 000 €

2/ Décès de Monsieur, le contrat de mariage prévoyant l'attribution des acquêts nets du prémourant au survivant en nature.

MONSIEUR LABAURENTIN

Patrimoine originaire	
Biens au jour du mariage : néant	
Appartement de famille à Arcachon	400 000 €
Total	400 000 €

Patrimoine final	
Moitié indivise de la maison à Chamalières	310 000 €
Moitié indivise de l'appartement à Sète	165 000 €
Appartement de famille à Arcachon	400 000 €
Deux appartements locatifs à Lyon	550 000 €
PEA	140 000 €
Comptes de dépôt et livrets	90 000 €
Total	1 655 000 €

ACQUETS NETS 1 255 000 €

Madame KAIRE devient attributaire des acquêts nets de Monsieur LABAURENTIN, soit l'ensemble des biens figurant à son patrimoine final à l'exclusion de ceux constituant le patrimoine originaire.

Sont attribués à Madame KAIRE en nature au titre de la liquidation du régime matrimonial :

Moitié indivise de la maison à Chamalières	310 000 €
Moitié indivise de l'appartement à Sète	165 000 €
Deux appartements locatifs à Lyon	550 000 €
PEA	140 000 €
Comptes de dépôt et livrets	90 000 €
Total	1 255 000 €

3/ Divorce, le contrat de mariage comportant une clause d'exclusion des biens professionnels (tant sur l'entreprise que sur les locaux ou parts sociales représentatives des locaux dans lesquels l'activité est exercée).

MADAME KAIRE

MADAME NAIRE	
	Patrimoine originaire
Biens au jour du mariage : néant	
Maison de famille dans le Cantal	210 000 €
Total	210 000 €

Patrimoine final	
Officine de pharmacie	
Parts de SCI (locaux pharmacie)	
Moitié indivise de la maison à Chamalières	310 000 €
Moitié indivise de l'appartement à Sète	165 000 €
Appartement locatif à Villeurbanne	250 000 €
Maison de famille dans le Cantal	210 000 €
PEA	130 000 €
Comptes de dépôt et livrets	50 000 €
Total	1 115 000 €

ACQUETS NETS 905 000 €

MONSIEUR LABAURENTIN

MONSIEUR LABAURENTIN	
Patrimoine originaire	
Biens au jour du mariage : néant	
Appartement de famille à Arcachon	400 000 €
Total	400 000 €

Patrimoine final	
Moitié indivise de la maison à Chamalières	310 000 €
Moitié indivise de l'appartement à Sète	165 000 €
Appartement de famille à Arcachon	400 000 €
Deux appartements locatifs à Lyon	550 000 €
PEA	140 000 €
Comptes de dépôt et livrets	90 000 €
Total	1 655 000 €

ACQUETS NETS 1 255 000 €

Débiteur de la créance de participation : celui dont les acquêts nets sont supérieurs

Soit: MONSIEUR LABAURENTIN

Montant de la créance de participation : $(\text{acquêts nets supérieurs} - \text{acquêts nets inférieurs}) / 2$

Sojt: 175 000 €

4/ Divorce, le contrat de mariage prévoyant un plafonnement de la créance de participation.

MADAME KAIRE

MADAME NAIRE	
	Patrimoine originaire
Biens au jour du mariage : néant	
Maison de famille dans le Cantal	210 000 €
Total	210 000 €

Patrimoine final	
Officine de pharmacie	900 000 €
Parts de SCI (locaux pharmacie)	500 000 €
Moitié indivise de la maison à Chamalières	310 000 €
Moitié indivise de l'appartement à Sète	165 000 €
Appartement locatif à Villeurbanne	250 000 €
Maison de famille dans le Cantal	210 000 €
PEA	130 000 €
Comptes de dépôt et livrets	50 000 €
Total	2 515 000 €

ACQUETS NETS 2 305 000 €

MONSIEUR LABAURENTIN

MONSIEUR LABAURENTIN	
Patrimoine originaire	
Biens au jour du mariage : néant	
Appartement de famille à Arcachon	400 000 €
Total	400 000 €

Patrimoine final	
Moitié indivise de la maison à Chamalières	310 000 €
Moitié indivise de l'appartement à Sète	165 000 €
Appartement de famille à Arcachon	400 000 €
Deux appartements locatifs à Lyon	550 000 €
PEA	140 000 €
Comptes de dépôt et livrets	90 000 €
Total	1 655 000 €

ACQUETS NETS 1 255 000 €

Débiteur de la créance de participation : celui dont les acquêts nets sont supérieurs

Soit : MADAME KAIRE

Montant de la créance de participation : $(\text{acquêts nets supérieurs} - \text{acquêts nets inférieurs}) / 2$

Soit : 525 000 €

Plafond de la créance : la moitié des acquêts non professionnels

452 500 €

5/ Divorce, le contrat de mariage prévoyant une minoration de la créance de participation à un quart.

MADAME KAIRE

MADAME NAIRE	
Patrimoine originaire	
Biens au jour du mariage : néant	
Maison de famille dans le Cantal	210 000 €
Total	210 000 €

Patrimoine final	
Officine de pharmacie	900 000 €
Parts de SCI (locaux pharmacie)	500 000 €
Moitié indivise de la maison à Chamalières	310 000 €
Moitié indivise de l'appartement à Sète	165 000 €
Appartement locatif à Villeurbanne	250 000 €
Maison de famille dans le Cantal	210 000 €
PEA	130 000 €
Comptes de dépôt et livrets	50 000 €
Total	2 515 000 €

ACQUETS NETS 2 305 000 €

MONSIEUR LABAURENTIN

MONSIEUR LABAURENTIN	
Patrimoine originaire	
Biens au jour du mariage : néant	
Appartement de famille à Arcachon	400 000 €
Total	400 000 €

Patrimoine final	
Moitié indivise de la maison à Chamalières	310 000 €
Moitié indivise de l'appartement à Sète	165 000 €
Appartement de famille à Arcachon	400 000 €
Deux appartements locatifs à Lyon	550 000 €
PEA	140 000 €
Comptes de dépôt et livrets	90 000 €
Total	1 655 000 €

ACQUETS NETS 1 255 000 €

Débiteur de la créance de participation : celui dont les acquêts nets sont supérieurs

Soit : MADAME KAIRE

Montant de la créance de participation : $(\text{acquêts nets supérieurs} - \text{acquêts nets inférieurs}) / 2$

Soit : 525 000 €

Minoration de la créance à un quart : créance déterminée selon la loi $x \times 1/4$

soit : 131 250 €